

研 究 報 告 書

第58輯(2010. 4)

# 재개발·재건축사업 관련 조세제도에 대한 연구

韓國稅務士會 附設

韓 國 租 稅 研 究 所

연구기관 : 한국조세연구포럼

◆ 研究責任者 ◆

---

정 지 선 (건양대학교 교수 · 세무학박사)

◆ 共同研究者 ◆

---

장 근 호 (홍익대학교 교수 · 경제학박사)

## 목 차

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 제1장 서 론 .....                  | 1  |
| 제1절 연구의 목적 .....               | 1  |
| 제2절 연구의 방법과 범위 .....           | 4  |
| 제2장 주택재개발사업과 재건축사업의 내용 .....   | 7  |
| 제1절 의의 및 목적 .....              | 10 |
| 제2절 기본계획의 수립과 정비구역의 지정 .....   | 10 |
| 1. 도시·주거환경정비 기본계획의 수립 .....    | 10 |
| 2. 정비구역의 지정 .....              | 12 |
| 제3절 주택재개발·재건축조합의 설립과 인가 .....  | 14 |
| 1. 조합의 설립 및 추진위원회의 구성 .....    | 14 |
| 2. 추진위원회의 기능 .....             | 15 |
| 3. 추진위원회의 조직 및 운영 .....        | 16 |
| 4. 조합의 설립인가 등 .....            | 17 |
| 5. 조합의 법인격 등 .....             | 18 |
| 6. 조합원의 자격 등 .....             | 18 |
| 7. 정관의 작성 및 변경 .....           | 20 |
| 8. 조합의 임원과 임원의 직무 및 해임 등 ..... | 21 |
| 9. 총회와 대의원회의 및 주민대표회의 .....    | 22 |
| 제4절 사업시행계획의 작성과 인가 .....       | 25 |
| 1. 사업시행인가 .....                | 25 |
| 2. 사업시행계획서의 작성 .....           | 26 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 제5절 관리처분계획의 작성과 인가 .....                 | 27 |
| 1. 분양공고 및 분양신청 .....                     | 27 |
| 2. 분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치 .....         | 28 |
| 3. 관리처분계획의 인가 .....                      | 28 |
| 4. 관리처분계획의 공람 및 인가절차 .....               | 30 |
| 제6절 이전고시와 청산금의 부과처분 .....                | 30 |
| 1. 이전고시 .....                            | 30 |
| 2. 청산금의 징수방법 등 .....                     | 31 |
| <br>제3장 주택재개발·재건축의 효과와 관련 조세제도의 현황 ..... | 33 |
| <br>제1절 재개발·재건축의 효과와 문제점 .....           | 33 |
| 1. 재개발·재건축 사업에 관한 인식 .....               | 33 |
| 2. 재개발·재건축 사업의 효과 .....                  | 34 |
| 3. 소 결 .....                             | 55 |
| 제2절 주택 재개발·재건축 관련 조세제도의 현황 .....         | 58 |
| 1. 양도소득세 .....                           | 59 |
| 2. 법인세 .....                             | 69 |
| 3. 부가가치세 .....                           | 71 |
| <br>제4장 정비사업조합의 법적 성격 .....              | 72 |
| <br>제1절 문제의 제기 .....                     | 72 |
| 제2절 정비사업조합의 법적 성격 .....                  | 74 |
| 1. 조합으로서의 성격 .....                       | 74 |
| 2. 정비사업조합이 영리법인인지의 여부 .....              | 75 |

제5장 양도소득세 과세문제 ..... 81

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 제1절 정비사업조합에 대한 조합원 출자 등에 대한 양도<br>소득세의 과세여부 ..... | 81  |
| 1. 양도의 의미 .....                                   | 81  |
| 2. 양도의 해당 여부 .....                                | 83  |
| 제2절 조합원입주권의 양도소득세 과세대상의 구분 .....                  | 87  |
| 1. 양도소득세 과세대상 .....                               | 87  |
| 2. 조합원입주권의 양도소득세 과세대상 구분 .....                    | 89  |
| 제3절 조합원입주권 양도에 있어서 1세대1주택 비과세 특례<br>적용의 문제 .....  | 94  |
| 1. 1세대 1주택 비과세 규정의 입법취지와 내용 .....                 | 94  |
| 2. 조합원입주권 양도에 대한 1세대1주택 비과세특례 적용 ....             | 105 |
| 제4절 재건축부담금과 양도소득세의 이중과세 문제 .....                  | 109 |
| 1. 현행 소득세법상의 규정 .....                             | 109 |
| 2. 현행 규정의 문제점 및 개선방안 .....                        | 110 |
| 제5절 조합원입주권의 양도와 장기보유특별공제의 적용여부 .....              | 112 |
| 1. 장기보유특별공제제도의 의의 및 취지 .....                      | 112 |
| 2. 조합원입주권에 대한 장기보유특별공제제도의 적용여부 ....               | 113 |
| 제6절 양도소득세 중과세의 문제점과 개선방안 .....                    | 115 |
| 1. 양도소득세 중과세율제도의 문제점 .....                        | 115 |
| 2. 양도소득세 중과세율제도의 개선방안 .....                       | 118 |

제6장 소득세와 법인세 및 부가가치세의 과세문제 ..... 120

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 제1절 소득세 과세의 문제점과 개선방안 ..... | 120 |
| 1. 소득세의 일반 .....            | 120 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 2. 재건축 관련 소득세 과세의 문제점과 개선방안 .....               | 121 |
| 제2절 법인세 과세의 문제점과 개선방안 .....                     | 123 |
| 1. 법인세 과세의 일반 .....                             | 123 |
| 2. 재개발·재건축조합에 대한 법인세 과세의 문제점과<br>개선방안 .....     | 123 |
| 제3절 부가가치세 과세의 문제점과 개선방안 .....                   | 128 |
| 1. 토지와 주택의 공급에 대한 부가가치세 과세의 일반 .....            | 121 |
| 2. 조합원에 대한 주택의 공급의 부가가치세 과세의<br>문제점과 개선방안 ..... | 129 |
| 제7장 취득세와 재산세의 과세문제 .....                        | 135 |
| 제1절 취득세의 과세에 있어서 문제점과 개선방안 .....                | 135 |
| 1. 취득세의 의의와 성격 .....                            | 135 |
| 2. 주택건설업자가 분양용으로 취득한 공동주택의 취득세<br>납세의무 .....    | 137 |
| 3. 주택재개발사업에 있어서 취득세 과세의 문제점과 개선<br>방안 .....     | 142 |
| 4. 주택재건축사업에 있어서 취득세 과세의 문제점과 개선<br>방안 .....     | 146 |
| 제2절 재산세의 과세에 있어서 문제점과 개선방안 .....                | 164 |
| 1. 재산세의 일반론 .....                               | 164 |
| 2. 재개발·재건축 관련 재산세 과세상의 문제점과 개선방안 .....          | 165 |
| 제8장 요약 및 결론 .....                               | 170 |
| □ 참 고 문 헌 □ .....                               | 175 |

## 제1장 서론

### 제1절 연구의 목적

1970년대 이후 우리나라의 산업화 및 도시화에 따라 대량으로 공급된 주택이 시간이 경과함에 따라 노후화되었으며, 국민들의 생활수준의 향상에 따른 주거에 대한 개선의 욕구가 커지면서 주택의 재개발 및 재건축 사업은 한정된 도시의 공간 속에서 새로운 주거공간의 창출에 핵심적인 역할을 수행하여 왔다.

재개발(Redvelopment)사업이란 정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위하여 시행하는 사업을 의미한다<sup>1)</sup>. 즉, 재개발사업이란 도시인구의 증가 및 산업기술의 발달 등 도시의 사회적·경제적 변화에 의하여 기존시설을 충분히 활용할 수 없게 되어 개인의 안전과 위생, 그리고 사회복지 및 도시기능상 장애를 초래하고 도시를 쇠퇴화시킬 우려가 있을 때 공권력으로 기존의 도시환경을 변화시키는 도시계획사업이라고 할 수 있다<sup>2)</sup>. 부연하면, 주택재개발사업이란 재개발구역 내에서 토지의 합리적이고 효율적인 고도이용과 도시기능을 회복하기 위하여 시행하는 건축물 및 그 부지의 정비와 대지의 조성 및 공공시설의 정비에 관한 사업과 이에 부대되는 사업을 말한다. 이러한 재개발사업을 통하여 정비구역안에 소재하는 토지 또는 건축물의 소유자 등은 보다 나은 주거환경 및 도시환경이 주어질 것이며, 이는 바로 경제적 이익으로 환산될 수 있을 것이다.

---

1) 도시및주거환경정비법 제2조.

2) 양은열, “재개발·재건축 규제와 재산권 보장에 관한 법적 연구”, 서울시립대학교 대학원 박사학위논문, 2009.2, p.5.

## 2 1. 연구의 목적

재건축(Reconstruction)이란 건물의 건축 후 상당한 기간이 경과되어 건물이 훼손 또는 일부 멸실되거나 그 밖의 사정에 의하여 건물의 가격에 비하여 과다한 수선·복구비나 관리비용이 소요되는 경우에 당해 건물을 철거하고 새로운 건물을 신축하는 사업을 의미한다<sup>3)</sup>. 이러한 재건축은 재산가치의 증대 및 주거환경을 개선하려는 노후·불량주택 소유자와 자본제공을 통해 개발이익에 참여하려는 건설회사 및 도시기능의 회복, 미관의 개선, 주택공급의 증대 등을 꾀하는 정부의 3자 의도가 맞아떨어져 활성화되었다<sup>4)</sup>. 결과적으로, 주택재건축사업이란 정비기반시설은 양호하지만 노후 또는 불량 건축물이 밀집한 지역에서 주거환경을 개선하기 위해서 시행하는 사업을 말한다. 즉, 정비기반시설의 양호여부에 따라서 양호한 경우에는 주택재건축사업이, 열악한 경우에는 주택재개발사업이 이루어지게 된다.

이러한 재개발과 재건축은 자신의 주거가 노후화, 불량화 되었을 경우 이를 효율적으로 개량하여 자신의 주거생활의 질을 높이는 데 이바지하는 제도로써 개인의 행복추구권, 재산권, 주거의 자유 등의 헌법상 기본권을 실현시키는 중요한 수단이다. 따라서 재개발·재건축에 대한 정책을 조합원 당사자와 사회적·경제적·주택적 부분을 고려하여 서로 간에 자유와 권리를 충족시켜줄 필요성이 있다<sup>5)</sup>.

한편, 재개발사업과 재건축사업은 그 대상지역과 목적물에 따라서 여러 가지로 구분할 수 있지만, 주로 이용되는 것은 주택에 대한 재개발과 재건축이다.

이러한 주택재개발 또는 주택재건축사업은 정비사업조합과 조

3) 집합건물의소유및관리에관한법률 제47조 제1항 참조.

4) 김명섭, “주택재건축 관련 취득세 논의”, 「사법논집」 제42집, 법원도서관, 2006.12, p.233.

5) 양은열, “재개발·재건축 규제와 재산권 보장에 관한 법적 연구”, 서울시립대학교 대학원 박사학위논문, 2009.2, p.1.



합원 모두에게 복잡한 세무상의 문제를 불러일으키고 있다. 주택 재개발 또는 주택재건축사업은 조합원의 정비사업조합에 대한 토지 등의 현물출자와 청산금의 납부, 정비사업조합의 공동주택 또는 건축물과 그 부속토지의 취득, 정비사업조합의 조합원 또는 일반수요자에 대한 공동주택 또는 건축물과 그 부속토지의 공급, 조합원의 조합원입주권 및 분양받은 주택의 양도 등과 관련하여 법인세·부가가치세·소득세·취득세 및 재산세 등과 같은 많은 조세와 관련을 맺고 있으며, 이로 인한 분쟁이 끊이지 않고 있다<sup>6)</sup>. 즉, 주택의 재개발 및 재건축 과정에서 조세문제는 매우 중요함에도 불구하고, 일반적으로 초기에는 이러한 조세문제를 간과하다가 막상 문제가 되었을 때에 그에 대한 명확한 조세제도와 이에 대한 명확한 해석이 부족하여 납세의무자와 과세관청 사이에 분쟁이 끊이지 않고 있는 것이다.

또한, 재개발사업은 개인이 아니라 정비구역의 다수의 토지 및 건축물의 소유자 등을 대상으로 하는 사업에 해당하기 때문에 동일한 목적을 가진 개인이 모여 단체를 이루게 되며, 그 단체가 재개발사업의 주도적인 절차진행을 맡고 그 사업이 종료되면 사업과 관련된 권리와 의무를 다시 개인에게 돌려주게 된다. 이러한 단체가 재개발조합이며 개인의 담세력의 증가나 소유자의 변경에 따른 과세문제 말고 재개발조합 자체의 과세문제, 재개발조합과의 거래에서 조합원의 과세문제도 고려할 필요가 있다<sup>7)</sup>.

이에 본 연구에서는 주택 재개발 및 재건축 관련 조세제도의 문제점과 그에 대한 합리적인 개선방안을 모색하는 것을 목적으로 하고자 한다. 구체적으로 주택 재개발 및 재건축 관련 조세제

6) 김완석, “재건축에 대한 조세법적 검토”, 「토지공법연구」 제33집, 한국토지공법학회, 2006.11, p.42.

7) 박훈, “재개발조합의 과세문제”, 「조세와 법」 제1권 제2호, 서울시립대학교 법학연구소·지방세연구소, 2008.12, p.211.

#### 4 2. 연구의 방법과 범위

도 중에서 특히 문제가 되는 양도소득세와 취득세를 중심으로 하여 현행 규정의 해석상 논란이 되는 부분에 대한 해석론과 더불어 입법상 미비점에 대한 입법론을 제시하고자 한다. 또한 법인세·소득세·부가가치세 및 재산세에 있어서도 주택의 재개발 및 재건축과 관련하여 해석상 논란이 되는 부분이 있기 때문에 이에 대한 문제점과 개선방안도 모색하고자 한다. 한편, 주택재개발 또는 재건축은 조합이 시행하는데, 이러한 정비사업조합의 법적 성격에 대하여도 아울러 살펴보하고자 한다.

### 제2절 연구의 방법과 범위

본 연구는 연구의 특성상 문헌연구의 방법에 의하고자 한다. 즉, 단행본과 학술논문 및 연구보고서 등을 참조하고자 한다. 그리고, 주택의 재개발 및 재건축과 관련된 법령의 해석상 논점을 파악하기 위해서 관련된 헌법재판소와 대법원의 판례 등을 참조하고자 한다.

이와 같이 문헌연구의 방법에 의하여 현행 조세법상 재개발 및 재건축과 관련된 조세제도 중에서 해석상 논란이 되고 있는 부분을 명확하게 함과 동시에 입법론을 제시하고자 한다.

한편, 재개발 및 재건축과 관련된 외국의 조세제도는 우리나라의 경우와 달리, 거의 없는 상황이다. 따라서, 외국의 제도에 대한 고찰은 생략하기로 한다.

본 연구는 다음과 같은 순서로 진행하고자 한다.

제2장에서는 주택재개발사업과 재건축사업의 내용에 대하여 살펴본다. 주택의 재개발사업과 재건축사업의 내용은 도시및주거환경정비법에 구체적으로 규정되어 있다. 즉, 2002년 12월 30일 도시및주거환경정비법이 제정되기 전에는 주택의 재개발사업은 도

시재개발법에 규정되었으며, 주택재건축사업은 주택건설촉진법에 규정되어 있었다. 이 경우 주택개발사업은 공법적인 규제가 강하게 미치는 도시계획사업의 일환으로 시행되었지만, 주택재건축사업은 민간에 의하여 자율적으로 추진되었다. 부연하면, 주택재개발사업과 재건축사업은 도시기능의 회복이라는 유사한 기능을 수행함에도 불구하고 상호간의 관련성을 간과할 채 혼란스럽게 시행되었던 것이다. 이에 도시및주거환경정비법을 제정하여 각 개별법에 의하여 시행된 주택재개발사업과 재건축사업을 전체적인 도시관리의 차원에서 체계적으로 추진하고, 주택재건축사업의 공법적인 통제를 강화하기 위한 목적으로 제정되었다.

한편, 도시및주거환경정비법에 주택의 재개발과 재건축에 관하여 규정하고 있는데, 기본계획의 수립, 정비구역의 지정, 주택재개발·재건축조합의 설립과 인가, 사업시행계획의 작성과 인가, 관리처분계획의 작성과 인가, 이전고시와 청산 등의 순서로 진행된다.

제3장에서는 주택재개발·재건축의 효과와 문제점 및 관련 조세제도의 현황에 대하여 살펴본다. 구체적으로는 주택재개발·재건축의 효과와 관련해서는 재개발·재건축 사업에 대한 인식, 효과 및 부동산세제의 특성에 대하여 살펴보고, 조세제도 중에서는 주택재개발·재건축과 관련하여 논란이 되고 있는 양도소득세, 법인세, 부가가치세 및 지방세에 대하여 살펴보고자 한다. 지방세 중에서는 재개발·재건축과 관련된 취득세와 재산세의 규정에 대하여 살펴보고자 한다.

제4장에서는 정비사업조합의 법적 성격에 대하여 살펴보고자 한다. 과거에는 재건축조합이 법인에 해당하는지의 여부에 대하여 논란이 있었지만, 도시및주거환경정비법 제18조에서는 당해 조합을 법인으로 규정하고 있는바, 이러한 조합이 영리법인인지 또는

## 6 2. 연구의 방법과 범위

비영리법인인지에 대하여 살펴보고자 한다.

제5장에서는 재개발·재건축 관련 양도소득세의 문제에 대하여 살펴보고자 한다. 구체적으로는 정비사업조합에 대한 조합원 출자 등에 대한 양도소득세의 과세여부, 조합원입주권의 양도소득세 과세대상의 구분, 조합원입주권 양도에 있어서 1세대1주택 비과세특례적용의 문제, 재건축부담금과 양도소득세의 이중과세 문제, 조합원입주권의 양도에 대한 장기보유특별공제의 적용여부 및 양도소득세 중과세의 문제점과 개선방안에 대하여 살펴보고자 한다.

제6장에서는 재개발·재건축 관련 소득세와 법인세 및 부가가치세의 과세문제에 대하여 살펴보고자 한다. 즉, 소득세의 과세에 있어서는 과세대상의 구분, 법인세 과세의 타당성 여부 및 조합원에 대한 주택의 공급이 부가가치세법상 재화의 공급에 해당하는지의 여부에 대하여 살펴보고자 한다.

제7장에서는 재개발·재건축 관련 취득세와 재산세의 과세문제에 대하여 살펴보고자 한다. 먼저, 취득세의 과세에 있어서는 주택재개발사업에 있어서의 취득세 과세문제를 현물출자단계에 있어서의 취득세 과세문제와 조합이 신축한 공동주택을 분양하는 단계에 있어서의 취득세 과세문제에 대하여 살펴보고자 한다. 그리고, 주택재건축사업에 있어서의 취득세 과세문제를 현물출자단계에 있어서의 취득세 과세문제와 조합이 신축한 공동주택을 분양하는 단계에 있어서의 취득세 과세문제로 구분하여 살펴보고자 한다. 또한, 주택건설업자가 분양용으로 취득한 공동주택의 취득세 납세의무에 대하여도 추가적으로 살펴보고자 한다.

한편, 재산세의 과세에 있어서는 재개발·재건축과 관련한 재산세 과세대상과 납세의무자 규정의 문제점과 개선방안에 대하여 살펴보고자 한다.

제8장에서는 지금까지의 내용을 요약하고 결론을 맺고자 한다.

## 제2장 주택재개발사업과 재건축사업의 내용

주택의 재개발사업과 재건축사업의 내용은 도시및주거환경정비법(Urban and Residential Environment Improvement Law)에 구체적으로 규정되어 있다. 따라서 이하에서는 도시및주거환경정비법의 내용을 중심으로 하여 주택 재개발과 재건축사업의 내용에 대하여 개략적으로 살펴보기로 한다.

### 제1절 의의 및 목적

도시및주거환경정비법이 시행되기 전에는 구 도시재개발법에 의하여 진행되는 재개발사업과 구 주택건설촉진법 등에 의하여 시행되는 재건축사업으로 제도가 이원화되어 있었다. 그러나, 도시및주거환경정비법의 시행에 따라 비교적 자율적으로 시행되던 재건축사업의 경우에도 재개발사업과 유사한 공법적인 규제가 가해지게 되었으며, 재건축과 재개발에 관련된 규정이 하나의 법률로 통합되었다.

도시및주거환경정비법이 시행되기 전에는 주택재개발사업과 재건축사업은 모두 노후·불량건축물을 정비하여 도시환경을 개선하기 위한 목적을 가지고 있었지만, 상호 연관성 없이 추진되어 효율성이 떨어졌다. 특히, 주택재건축사업의 경우 공공성의 측면을 도외시하고 민간에 맡겨두어 도시의 과밀화, 교통 및 환경, 주택가격의 투기적인 상승 등 많은 문제점을 야기하였다는 비판을 받았다. 또한, 주택재건축사업 과정에서 발생한 조합의 임원 등의 각종 비리도 공법적인 규제가 느슨한 데서 기인한 바가 컸다고 할 것이다. 도시및주거환경정비법은 주택재개발사업과 재건축사업을 일원화하여 주택정비사업의 효율성을 기하는 것 이외에 민간

## 8 1. 의의 및 목적

에 일임되어 있던 주택재건축사업에 대한 공법적인 규율을 강화하는 것도 중요한 목적이라고 할 수 있는 것이다<sup>8)</sup>.

즉, 2002년 12월 30일에 제정되어 2003년 7월 1일부터 시행되고 있는 도시및주거환경정비법은 개별법으로 운영되던 주택재정비사업의 통합 및 조합관리로 사업의 일관성과 선계획·후개발에 입각한 도시관리를 도모하고, 재개발·재건축 등 주택재정비사업의 제도운영상 나타났던 문제점을 보완하기 위하여 제정되었으며, 도시저소득주민의 주거환경개선을 위한 임시조치법에 의한 주거환경개선사업, 주택건축촉진법에 의한 재건축사업 등이 정비사업으로 통일적으로 관리되게 되었다<sup>9)</sup>.

이와 같이 도시및주거환경정비법의 시행으로 주택재개발사업과 재건축사업을 공법적인 통제라는 관점에서 상당히 접근하였지만, 사업의 성격상 여전히 다음과 같은 점에서 차이가 있다. 이는 주택재건축사업의 공법적인 통제가 강화되기는 하였지만, 주택재개발사업에 비하여 상대적으로 공공성이 약하다는 것을 의미한다고 할 것이다<sup>10)</sup>.

첫째, 주택재개발조합은 강제가입제도를 채택하고 있지만, 주택재건축조합은 임의가입제도를 채택하고 있다. 따라서 주택재개발구역 내의 토지 등의 소유자는 당연히 조합원이 되는 반면에, 주택재건축구역 내의 토지 등의 소유자는 조합의 설립에 동의한 자만이 조합원이 되는 것이다.

둘째, 주택재개발사업은 정비기반시설이 열악한 지역을 대상으로 하는 반면에, 주택재건축사업은 정비기간시설이 양호한 지역에

---

8) 이종교, “주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구”, 「공법연구」 제37집 제1-2호, 한국공법학회, 2008.10, p.363.

9) 김남진·김연태, 「행정법」Ⅱ, 법문사, 2007, p.593; 김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2, p.16.

10) 이종교, “주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구”, 「공법연구」 제37집 제1-2호, 한국공법학회, 2008.10, p.364.

서 시행된다.

셋째, 주택재개발조합은 주택재개발사업을 시행하기 위하여 필요한 경우 사업에 반대하는 토지 등의 소유자를 상대로 수용권을 행사하여 토지를 확보할 수 있다. 그러나, 주택재건축조합은 천재지변 그 밖의 불가치한 사유로 인하여 긴급히 정비사업을 시행할 필요가 있다고 인정되는 경우를 제외하고는 원칙적으로 수용권이 인정되지 않는다. 그 대신 주택재건축조합은 재건축사업에 반대하는 토지 등 소유자를 상대로 매도청구권을 행사하여 사업에 필요한 토지를 확보할 수 있다.

한편, 도시정비사업의 일원화는 원래 공공사업으로서 공법적 법률관계로 규율되던 주거환경개선사업과 도시재개발사업의 절차를 개선·보완한다는 측면도 있지만, 사법상의 법률관계로 규율되던 주택재건축사업을 공법적 법률관계의 영역으로 끌어들여 재건축사업과 관련하여 발생한 각종 분쟁 및 비리를 규율하고자 하는 의의가 더 크다. 즉, 재건축 조합과 재개발 조합은 정비사업조합이라는 하나의 명칭 하에 통합되었으며, 구법상의 재개발사업과 유사한 틀이 정비사업 일반에 마련되었다. 특히 관리처분계획과 이전고시(분양처분)제도가 재건축사업에도 마련됨으로써 권리의 배분을 둘러싼 각종 이권이 하나의 행정처분으로 해결되는 효율성이 확보되었다<sup>11)</sup>. 또한 과거 재건축조합의 법적 성격에 대한 논의가 분분했지만 재건축조합과 재개발조합이 모두 정비사업조합이라는 하나의 법인 개념으로 통합됨으로써 과세문제를 통일적으로 해결할 수 있는 기초가 마련되었다<sup>12)</sup>.

11) 도시및주거환경정비법에서는 도시기능의 회복이 필요하거나 주거환경이 불량한 지역을 계획적으로 정비하고 노후·불량건축물을 효율적으로 개량하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높이는 데 이바지함을 목적으로 한다고 규정하고 있다(도시및주거환경정비법 제1조).

12) 홍성욱, “주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 2006.2, pp.4-5.

## 10 2. 기본계획의 수립과 정비구역의 지정

그러나, 근본적으로 도시재개발에 관한 법제에 뿌리를 둔 현행 도시및주거환경정비법은 정부주도의 주택재개발사업 등에 어울리는 법률이고, 민간주도의 주택재건축사업과는 조화되기 어려운 점이 있다. 즉, 성격이 서로 상이한 주택재개발사업 등과 주택재건축사업을 하나의 법률에 규정한 결과 납세의무 주체의 성격을 모호하게 하였고, 조세법률관계는 물론이고 일반법률관계에서도 혼란을 야기하고 있다.

도시및주거환경정비법은 주택재건축사업의 근거법률이기 때문에 그 법률의 내용은 관련 과세제도에 중대한 영향을 미치게 된다. 따라서 현행 도시및주거환경정비법 중 주택 재건축사업에 관한 규정들은 별도의 법률로 입법하는 것이 과세상 혼란을 제거할 뿐만 아니라, 주택재건축정비사업조합의 일반 법률관계에서도 공법관계 또는 사법관계 여부를 판단하는데 원칙을 확립할 수 있을 것이다<sup>13)</sup>.

도시및주거환경정비법의 시행으로 주택의 재개발과 재건축은 기본계획의 수립, 정비구역의 지정, 주택재개발·재건축조합의 설립과 인가, 사업시행계획의 작성과 인가, 관리처분계획의 작성과 인가, 이전고시와 청산 등의 순서로 진행된다. 이하에서는 이러한 내용에 대하여 도시및주거환경정비법의 내용을 중심으로 하여 살펴보기로 한다.

## 제2절 기본계획의 수립과 정비구역의 지정

### 1. 도시·주거환경정비 기본계획의 수립

---

13) 김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2, p.132.



특별시장·광역시장 또는 시장은 다음의 사항이 포함된 도시·주거환경정비기본계획 (이하 “기본계획”이라 한다)을 10년 단위로 수립하여야 한다. 다만, 지방자치법 제175조에 따른 서울특별시와 광역시를 제외한 인구 50만 이상 대도시(이하 “대도시”라 한다)가 아닌 경우 도지사가 기본계획의 수립이 필요하다고 인정하는 시를 제외하고 기본계획을 수립하지 아니할 수 있다<sup>14)</sup>.

- ① 정비사업의 기본방향
- ② 정비사업의 계획기간
- ③ 인구·건축물·토지이용·정비기반시설·지형 및 환경 등의 현황
- ④ 주거지 관리계획
- ⑤ 토지이용계획·정비기반시설계획·공동이용시설설치계획 및 교통계획
- ⑥ 녹지·조경·에너지공급·폐기물처리 등에 관한 환경계획
- ⑦ 사회복지시설 및 주민문화시설 등의 설치계획
- ⑧ 도시의 광역적 재정비를 위한 기본방향
- ⑨ 도시및주거환경정비법 제4조에 따라 정비구역으로 지정할 예정인 구역(이하 “정비예정구역”이라 한다)의 개략적 범위
- ⑩ 단계별 정비사업추진계획(정비예정구역별 정비계획의 수립 시기를 포함하여야 한다)
- ⑪ 건폐율·용적률 등에 관한 건축물의 밀도계획
- ⑫ 세입자에 대한 주거안정대책
- ⑬ 그 밖에 주거환경 등을 개선하기 위하여 필요한 사항으로서 대통령령이 정하는 사항

이 경우 특별시장·광역시장 또는 시장은 기본계획에 대하여 5년마다 그 타당성 여부를 검토하여 그 결과를 기본계획에 반영하여야 하며, 특별시장·광역시장 또는 시장은 기본계획을 수립 또는

14) 도시및주거환경정비법 제3조 제1항.

## 12 2. 기본계획의 수립과 정비구역의 지정

변경하고자 하는 때에는 14일 이상 주민에게 공람하고 지방의회의 의견을 들은 후(이 경우 지방의회는 특별시장·광역시장 또는 시장이 기본계획을 통지한 날부터 60일 이내에 의견을 제시하여야 하며, 의견제시 없이 60일이 도과한 경우 이의가 없는 것으로 본다) 국토의계획및이용에관한법률 제113조 제1항 및 제2항에 따른 지방도시계획위원회(이하 "지방도시계획위원회"라 한다)의 심의(대도시의 시장이 아닌 시장이 기본계획을 수립 또는 변경하는 경우에는 제외한다)를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령이 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다<sup>15)</sup>.

한편, 특별시장·광역시장 또는 시장은 기본계획이 수립 또는 변경된 때에는 이를 지체없이 당해 지방자치단체의 공보에 고시하여야 하며, 특별시장·광역시장 또는 시장은 기본계획을 수립하거나 변경한 때에는 국토해양부령이 정하는 방법 및 절차에 따라 국토해양부장관에게 보고하여야 한다<sup>16)</sup>.

## 2. 정비구역의 지정

시장·군수는 기본계획에 적합한 범위 안에서 노후·불량건축물이 밀집하는 등 대통령령이 정하는 요건에 해당하는 구역에 대하여 다음의 사항이 포함된 정비계획을 수립하여 주민설명회 및 30일 이상 주민에게 공람하고 지방의회의 의견을 들은 후(이 경우 지방의회는 시장·군수가 정비계획을 통지한 날부터 60일 이내에 의견을 제시하여야 하며, 의견제시 없이 60일이 도과한 경우 이의가 없는 것으로 본다) 이를 첨부하여 시·도지사에게 정비구역지정을 신청하여야 하며, 정비계획의 내용을 변경할 필요가 있을 때에는

---

15) 도시및주거환경정비법 제3조 제2항 및 제3항.

16) 도시및주거환경정비법 제3조 제6항 및 제7항.

같은 절차를 거쳐 변경지정을 신청하여야 한다. 다만, 대통령령이 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 주민설명회·주민공람 및 지방의회의 의견청취절차를 거치지 아니할 수 있다<sup>17)</sup>. 다만, 대도시의 시장은 시·도지사에게 정비구역지정을 신청하지 아니하고 직접 정비구역을 지정한다<sup>18)</sup>.

- ① 정비사업의 명칭
- ② 정비구역 및 그 면적
- ③ 국토의계획및이용에관한법률 제2조제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치에 관한 계획
- ④ 공동이용시설 설치계획
- ⑤ 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획
- ⑥ 환경보전 및 재난방지에 관한 계획
- ⑦ 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획
- ⑧ 정비사업시행 예정시기
- ⑨ 국토의계획및이용에관한법률 제52조 제1항 각 호의 사항에 관한 계획(필요한 경우에 한한다)
- ⑩ 그 밖에 정비사업의 시행을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령이 정하는 사항

한편, 토지등 소유자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 시장·군수에게 정비계획의 입안을 제안할 수 있으며, 이 경우 정비계획의 제안을 위한 토지등 소유자의 동의, 제안서의 처리 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다<sup>19)</sup>

- ① 제3조 제1항 제9호에 따른 단계별 정비사업추진계획상 정비계획의 수립시기가 1년(시·도 조례가 그 이상의 연수로 정하는 경우에는 그 연수로 한다) 이상 경과하였음에도 불구하고 정비계획

17) 도시및주거환경정비법 제4조 제1항.

18) 도시및주거환경정비법 제4조 제2항.

19) 도시및주거환경정비법 제4조 제3항.

## 14 3. 주택재개발·재건축조합의 설립과 인가

이 수립되지 아니한 경우

② 토지등소유자가 제8조제4항에 따라 주택공사 등을 사업시행자로 요청하고자 하는 경우

③ 대도시가 아닌 시 또는 군으로서 시·도 조례로 정하는 경우

### 제3절 주택재개발·재건축조합의 설립과 인가

#### 1. 조합의 설립 및 추진위원회의 구성

시장·군수 또는 주택공사 등이 아닌 자가 정비사업을 시행하고자 하는 경우에는 토지등 소유자로 구성된 조합을 설립하여야 한다. 다만, 제8조 제3항에 따라 도시환경정비사업을 토지등 소유자가 시행하고자 하는 경우에는 그러하지 아니하다<sup>20)</sup>.

조합을 설립하고자 하는 경우에는 제4조에 따른 정비구역지정고시(정비구역이 아닌 구역에서의 주택재건축사업의 경우에는 제12조제5항에 따른 주택재건축사업의 시행결정을 말한다) 후 위원장을 포함한 5인 이상의 위원 및 제15조 제2항에 따른 운영규정에 대한 토지등 소유자 과반수의 동의를 얻어 조합설립을 위한 추진위원회를 구성하여 국토해양부령으로 정하는 방법과 절차에 따라 시장·군수의 승인을 얻어야 한다. 그리고, 추진위원회의 구성에 동의한 토지등 소유자(이하 “추진위원회 동의자”라 한다)는 제16조 제1항부터 제3항까지에 따른 조합의 설립에 동의한 것으로 본다. 다만, 제16조에 따른 조합설립인가 신청 전에 시장·군수 및 추진위원회에 조합설립에 대한 반대의 의사표시를 한 추진위원회 동의자의 경우에는 그러하지 아니하다.

종전에는 조합설립추진위원회의 설립에 관한 법적인 근거가 없

---

20) 도시및주거환경정비법 제13조 제1항.

어서 재개발·재건축사업을 추진하고자 하는 주민들이 사업추진에 따른 이권 등으로 주도권을 잡기 위해서 다수의 조합설립추진위원회를 임의로 설치함으로써 분쟁이 빈발하고, 결과적으로 사업자체가 지지부진하게 된 경우가 많았는데, 주민 과반수의 동의를 얻어 구성토록 함으로써 무분별한 난립을 막고 사업을 원활하게 진행할 수 있도록 한 것이다<sup>21)</sup>.

한편, 시장·군수는 제2항의 규정에 의한 승인을 함에 있어 주택재건축사업이 제30조의2 제1항의 규정에 의한 재건축임대주택 공급의무가 있는 것으로서 정비구역이 아닌 구역에서 시행되는 경우에는 재건축임대주택의 규모 등 재건축임대주택에 관한 사항을 인수자와 미리 협의하여 추진위원회에 통보하여야 한다<sup>22)</sup>.

## 2. 추진위원회의 기능

추진위원회는 다음의 업무를 수행할 수 있다. 다만, 추진위원회가 수행하는 업무의 내용이 토지등 소유자의 비용부담을 수반하는 것이거나 권리와 의무에 변동을 발생시키는 경우로서 대통령령으로 정하는 사항에 대하여는 그 업무를 수행하기 전에 대통령령이 정하는 비율 이상의 토지등소유자의 동의를 얻어야 한다<sup>23)</sup>.

- ① 제69조의 규정에 의한 정비사업전문관리업자(이하 "정비사업전문관리업자"라 한다)의 선정
- ② 개략적인 정비사업 시행계획서의 작성
- ③ 조합의 설립인가를 받기 위한 준비업무
- ④ 그 밖에 조합설립의 추진을 위하여 필요한 업무로서 대통령

21) 홍성욱, "주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구", 서울대학교 대학원, 2006.2, p.6.

22) 도시및주거환경정비법 제13조 제6항.

23) 도시및주거환경정비법 제14조 제1항 및 제4항.

## 16 3. 주택재개발·재건축조합의 설립과 인가

령이 정하는 업무

한편, 추진위원회가 정비사업전문관리업자를 선정하고자 하는 경우에는 제13조에 따라 시장·군수의 추진위원회 승인을 얻은 후 국토해양부장관이 정하는 경쟁입찰의 방법으로 선정하여야 한다.

### 3. 추진위원회의 조직 및 운영

추진위원회는 추진위원회를 대표하는 위원장 1인과 감사를 두어야 하며, 그 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 그리고, 국토해양부장관은 추진위원회의 공정한 운영을 위하여 다음의 내용을 포함한 추진위원회의 운영규정을 정하여 관보에 고시하여야 한다<sup>24)</sup>.

- ① 추진위원회 위원의 선임방법 및 변경에 관한 사항
- ② 추진위원회 위원의 권리·의무에 관한 사항
- ③ 추진위원회의 업무범위에 관한 사항
- ④ 추진위원회의 운영방법에 관한 사항
- ⑤ 토지등 소유자의 운영경비 납부에 관한 사항
- ⑥ 추진위원회 운영자금의 차입에 관한 사항
- ⑦ 그 밖에 추진위원회의 운영에 필요한 사항으로서 대통령령이 정하는 사항

추진위원회는 운영규정에 따라 운영하여야 하며, 토지등 소유자는 운영에 필요한 경비를 운영규정이 정하는 바에 따라 납부하여야 한다. 그리고, 추진위원회는 추진위원회가 행한 업무를 총회에 보고하여야 하며, 추진위원회가 행한 업무와 관련된 권리와 의무는 조합이 포괄승계한다.

조합이 설립되면 조합설립추진위원회가 조합설립과 관련하여

---

24) 도시및주거환경정비법 제15조 제1항 및 제2항.

한 행위로 인한 권리의무가 포괄적으로 승계되므로 일정한 경우 동의를 요구한다. 따라서, 조합설립 또는 법령상 규정된 재건축사업 준비를 위한 업무와 관계없는 행위이거나 토지 등 소유자의 동의를 받지 않고 임의로 행한 업무로 인한 권리의무를 승계되지 않는다고 보아야 할 것이다<sup>25)</sup>.

한편, 추진위원회는 사용경비를 기재한 회계장부 및 관련서류를 조합 설립의 인가일부터 30일 이내에 조합에 인계하여야 하며, 토지등 소유자는 추진위원회의 운영규정이 정하는 바에 따라 추진위원회에 추진위원회 위원의 교체 및 해임을 요구할 수 있다.

#### 4. 조합의 설립인가 등

주택재개발사업 및 도시환경정비사업의 추진위원회가 조합을 설립하고자 하는 때에는 토지등 소유자의 3/4 이상 및 토지면적의 1/2 이상의 토지소유자의 동의를 얻어 정관 및 국토해양부령이 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수의 인가를 받아야 한다. 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에도 또한 같다. 다만, 대통령령이 정하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 때에는 조합원의 동의 없이 시장·군수에게 신고하고 변경할 수 있다<sup>26)</sup>.

그리고, 주택재건축사업의 추진위원회가 조합을 설립하고자 하는 때에는 집합건물의소유및관리에관한법률 제47조 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 주택단지안의 공동주택의 각 동(복리시설의 경우에는 주택단지안의 복리시설 전체를 하나의 동으로 본다)별 구분소유자의 2/3 이상 및 토지면적의 1/2 이상의 토지소유자의 동의(공동주택의 각 동별 구분소유자가 5 이하인 경우는 제외

25) 홍성욱, “주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 2006.2, p.7.

26) 도시및주거환경정비법 제16조 제1항.

### 18 3. 주택재개발·재건축조합의 설립과 인가

한다)와 주택단지 안의 전체 구분소유자의 3/4 이상 및 토지면적의 3/4 이상의 토지소유자의 동의를 얻어 정관 및 국토해양부령이 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수의 인가를 받아야 한다. 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에도 또한 같다. 다만, 제1항 단서의 규정에 의한 경미한 사항을 변경하고자 하는 때에는 조합원의 동의 없이 시장·군수에게 신고하고 변경할 수 있다.

한편, 주택단지가 아닌 지역이 정비구역에 포함된 때에는 주택단지가 아닌 지역안의 토지 또는 건축물 소유자의 3/4 이상 및 토지면적의 2/3 이상의 토지소유자의 동의를 얻어야 한다.

조합이 이 법에 의한 정비사업을 시행하는 경우 주택법 제38조의 규정을 적용함에 있어서는 조합을 동법 제2조 제5호의 규정에 의한 사업주체로 보며, 조합설립인가일부터 동법 제9조의 규정에 의한 주택건설사업 등의 등록을 한 것으로 본다.

## 5. 조합의 법인격 등

조합은 법인으로 한다. 조합은 조합 설립의 인가를 받은 날부터 30일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 대통령령이 정하는 사항을 등기함으로써 성립한다.

이 경우 조합은 그 명칭 중에 정비사업조합이라는 문자를 사용하여야 한다<sup>27)</sup>.

## 6. 조합원의 자격 등

정비사업(시장·군수 또는 주택공사 등이 시행하는 정비사업을 제외한다)의 조합원은 토지등 소유자(주택재건축사업의 경우에는

---

27) 도시및주거환경정비법 제18조.



주택재건축사업에 동의한 자에 한한다)로 하되, 다음 중 어느 하나에 해당하는 때에는 그 수인을 대표하는 1인을 조합원으로 본다<sup>28)</sup>.

① 토지 또는 건축물의 소유권과 지상권이 수인의 공유에 속하는 때

② 수인의 토지등 소유자가 1세대에 속하는 때(이 경우 동일한 세대별 주민등록표 상에 등재되어 있지 아니한 배우자 및 미혼인 20세 미만의 직계비속은 1세대로 보며, 1세대로 구성된 수인의 토지등소유자가 조합설립인가 후 세대를 분리하여 동일한 세대에 속하지 아니하는 때에도 이혼 및 20세 이상 자녀의 분가를 제외하고는 1세대로 본다)

③ 조합설립인가 후 1인의 토지등 소유자로부터 토지 또는 건축물의 소유권이나 지상권을 양수하여 수인이 소유하게 된 때

다만, 주택법 제41조 제1항의 규정에 의한 투기과열지구로 지정된 지역 안에서의 주택재건축사업의 경우 조합설립인가 후 당해 정비사업의 건축물 또는 토지를 양수(매매·증여 그 밖의 권리의 변동을 수반하는 일체의 행위를 포함하되, 상속·이혼으로 인한 양도·양수의 경우를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)한 자는 위의 규정에 불구하고 조합원이 될 수 없다. 다만, 양도자가 다음 중 하나에 해당하는 경우 그 양도자로부터 그 건축물 또는 토지를 양수한 자는 그러하지 아니하다<sup>29)</sup>.

① 세대원(세대주가 포함된 세대의 구성원을 말한다)의 근무 또는 생업상의 사정이나 질병치료·취학·결혼으로 인하여 세대원 전원이 당해 사업구역이 위치하지 아니한 특별시·광역시·시 또는 군으로 이전하는 경우

28) 도시및주거환경정비법 제19조 제1항.

29) 도시및주거환경정비법 제19조 제2항.

## 20 3. 주택재개발·재건축조합의 설립과 인가

- ② 상속에 의하여 취득한 주택으로 세대원 전원이 이전하는 경우
- ③ 세대원 전원이 해외로 이주하거나 세대원 전원이 2년 이상의 기간 동안 해외에 체류하고자 하는 경우
- ④ 그 밖에 불가피한 사정으로 양도하는 경우로서 대통령령이 정하는 경우

## 7. 정관의 작성 및 변경

조합은 조합의 명칭 및 주소, 조합원의 자격에 관한 사항, 조합원의 제명·탈퇴 및 교체에 관한 사항, 정비사업 예정구역의 위치 및 면적, 조합임원의 수 및 업무의 범위, 조합임원의 권리·의무·보수·선임방법·변경 및 해임에 관한 사항, 대의원의 수·의결방법·선임방법 및 선임절차, 조합의 비용부담 및 조합의 회계, 정비사업의 시행연도 및 시행방법, 총회의 소집절차·시기 및 의결방법, 총회의 개최 및 조합원의 총회소집요구에 관한 사항, 정비사업비의 부담시기 및 절차, 정비사업이 종결된 때의 청산절차, 청산금의 징수·지급의 방법 및 절차, 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용, 정관의 변경절차, 그 밖에 정비사업의 추진 및 조합의 운영을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령이 정하는 사항이 포함된 정관을 작성하여야 한다<sup>30)</sup>.

한편, 국토해양부장관은 위의 내용이 포함된 표준정관을 작성하여 보급할 수 있으며, 조합이 정관을 변경하고자 하는 경우에는 총회를 개최하여 조합원 과반수(조합원의 자격에 관한 사항, 조합원의 제명·탈퇴 및 교체에 관한 사항, 정비사업 예정구역의 위치 및 면적, 조합의 비용부담 및 조합의 회계, 정비사업비의 부담시

30) 도시및주거환경정비법 제20조 제1항.

기 및 절차 또는 시공자·설계자의 선정 및 계약서에 포함될 내용의 경우에는 3분의 2이상을 말한다)의 동의를 얻어 시장·군수의 인가를 받아야 한다. 다만, 대통령령이 정하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 때에는 이 법 또는 정관으로 정하는 방법에 따라 변경하고 시장·군수에게 신고하여야 한다<sup>31)</sup>.

## 8. 조합의 임원과 임원의 직무 및 해임 등

### 가. 조합의 임원

조합은 조합장 1인, 이사 및 감사의 임원을 둔다. 이 경우 이사와 감사의 수에 관하여 필요한 사항은 대통령령이 정하는 범위 안에서 정관으로 정한다<sup>32)</sup>.

### 나. 조합임원의 직무 등

조합장은 조합을 대표하고, 그 사무를 총괄하며, 총회 또는 대원회의 의장이 된다. 한편, 조합장 또는 이사의 자기를 위한 조합과의 계약이나 소송에 관하여는 감사가 조합을 대표하며, 조합임원은 같은 목적의 정비사업을 하는 다른 조합의 임원 또는 직원을 겸할 수 없다<sup>33)</sup>.

### 다. 조합임원의 결격사유 및 해임

다음 중 어느 하나에 해당하는 자는 조합의 임원이 될 수 없으

31) 도시및주거환경정비법 제20조 제2항 및 제3항.

32) 도시및주거환경정비법 제21조.

33) 도시및주거환경정비법 제22조.

## 22 3. 주택재개발·재건축조합의 설립과 인가

며, 조합임원이 다음 중 어느 하나에 해당하게 되거나 선임 당시 그에 해당하는 자이었음이 판명된 때에는 당연 퇴임하지만, 퇴임된 임원이 퇴임전에 관여한 행위는 그 효력을 잃지 아니한다<sup>34)</sup>.

① 미성년자·금치산자 또는 한정치산자

② 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자

③ 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료(종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 경과되지 아니한 자

④ 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간중에 있는 자

⑤ 이 법을 위반하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받고 5년이 지나지 아니한 자

또한, 조합임원의 해임은 조합원 10분의 1 이상의 발의로 소집된 총회에서 조합원 과반수의 출석과 출석 조합원 과반수의 동의를 얻어 할 수 있다. 이 경우 발의자 대표로 선출된 자가 해임 총회의 소집 및 진행에 있어 조합장의 권한을 대행한다.

## 9. 총회와 대의원회의 및 주민대표회의

### 가. 총회개최 및 의결사항

조합에 조합원으로 구성되는 총회를 두고, 총회는 제23조 제4항의 경우를 제외하고는 조합장의 직권 또는 조합원 1/5 이상 또는 대의원 2/3 이상의 요구로 조합장이 소집하며, 다음의 사항은 총회의 의결을 거쳐야 한다<sup>35)</sup>.

---

34) 도시및주거환경정비법 제23조.

35) 도시및주거환경정비법 제24조.

① 정관의 변경(제20조 제3항 단서의 규정에 의한 경미한 사항의 변경의 경우 이 법 또는 정관에서 총회의결사항으로 정한 경우에 한한다)

② 자금의 차입과 그 방법·이율 및 상환방법

③ 제61조의 규정에 의한 비용의 금액 및 징수방법

④ 정비사업비의 사용

⑤ 예산으로 정한 사항 외에 조합원의 부담이 될 계약

⑥ 철거업자·시공자·설계자 또는 감정평가업자(주택재개발사업은 제외한다)의 선정 및 변경. 다만, 감정평가업자 선정 및 변경은 총회 의결을 거쳐 시장·군수에게 위탁할 수 있다.

⑦ 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경

⑧ 조합임원의 선임 및 해임

⑨ 정비사업비의 조합원별 분담내역

⑩ 제30조에 따른 사업시행계획서의 수립 및 변경(제28조제1항에 따른 정비사업의 중지 또는 폐지에 관한 사항을 포함하며, 같은 항 단서에 따른 경미한 변경은 제외한다)

⑪ 제48조의 규정에 의한 관리처분계획의 수립 및 변경(제48조제1항 단서의 규정에 의한 경미한 변경을 제외한다)

⑫ 제57조의 규정에 의한 청산금의 징수·지급(분할징수·분할지급을 포함한다)과 조합 해산시의 회계보고

⑬ 그 밖에 조합원에게 경제적 부담을 주는 사항 등 주요한 사항을 결정하기 위하여 필요한 사항으로서 대통령령 또는 정관이 정하는 사항

한편, 총회의 소집절차·시기 및 의결방법 등에 관하여는 정관으로 정한다.

## 24 3. 주택재개발·재건축조합의 설립과 인가

### 나. 대의원회의

조합원의 수가 100인 이상인 조합은 대의원회의를 두어야 하고, 대의원회의는 조합원의 10분의 1 이상으로 하되 조합원의 10분의 1 이 100인을 넘는 경우에는 조합원의 10분의 1 범위 안에서 100인 이상으로 구성할 수 있으며, 총회의 의결사항 중 대통령령이 정하는 사항을 제외하고는 총회의 권한을 대행할 수 있다.

이 경우 조합장이 아닌 조합임원은 대의원이 될 수 없으며, 대의원의 수·의결방법·선임방법 및 선임절차 등에 관하여는 대통령령이 정하는 범위 안에서 정관으로 정한다<sup>36)</sup>.

### 다. 주민대표회의

정비구역안[제2조제9호나목(2)에 따라 정비구역이 아닌 구역에서 주택재건축사업을 시행하는 경우 그 구역을 포함한다]의 토지등 소유자가 시장·군수 또는 주택공사 등의 사업시행을 원하는 경우 사업시행을 원활하게 하기 위한 주민대표기구(이하 “주민대표회의”라 한다)를 정비구역지정 고시 후 구성하여야 한다. 이 경우 주민대표회의는 5인 이상 25인 이하로 한다<sup>37)</sup>.

주민대표회의는 토지등 소유자의 과반수의 동의를 얻어서 구성하며, 이를 구성한 때에는 국토해양부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 시장·군수의 승인을 얻어야 한다.

한편, 주민대표회의는 사업시행자가 다음의 사항에 관하여 제30조 제8호의 규정에 의한 시행규정을 정하는 때에 의견을 제시할 수 있다.

---

36) 도시및주거환경정비법 제25조.

37) 도시및주거환경정비법 제26조.

- ① 건축물의 철거에 관한 사항
- ② 주민이주에 관한 사항
- ③ 토지 및 건축물의 보상에 관한 사항
- ④ 정비사업비의 부담에 관한 사항
- ⑤ 그 밖에 정비사업의 시행을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령이 정하는 사항

## 제4절 사업시행계획의 작성과 인가

### 1. 사업시행인가

사업시행자는 정비사업을 시행하고자 하는 경우에는 사업시행계획서에 정관 등과 그 밖에 국토해양부령이 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수에게 제출하고 사업시행인가를 받아야 한다. 인가 받은 내용을 변경하거나 정비사업을 중지 또는 폐지하고자 하는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령이 정하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 때에는 시장·군수에게 이를 신고하여야 한다<sup>38)</sup>. 시장·군수는 사업시행인가를 하고자 하는 경우 정비구역으로부터 200미터 이내에 교육시설이 설치되어 있는 때에는 해당 지방자치단체의 교육감 또는 교육장과 협의하여야 한다.

시장·군수는 사업시행인가(시장·군수가 사업시행계획서를 작성한 경우를 포함한다)를 하거나 그 정비사업을 변경·중지 또는 폐지하는 경우에는 국토해양부령이 정하는 방법 및 절차에 의하여 그 내용을 당해 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다. 다만, 경미한 사항을 변경하고자 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이 경우 사업시행자(시장·군수 또는 주택공사 등을 제외한다)는

38) 도시및주거환경정비법 제28조.

## 26 4. 사업시행계획의 작성과 인가

사업시행인가를 신청(인가받은 내용을 변경하거나 정비사업을 중지 또는 폐지하고자 하는 경우를 포함한다)하기 전에 미리 총회를 개최하여 조합원 과반수의 동의를 얻어야 한다. 다만, 사업시행자가 지정개발자인 경우에는 정비구역 안의 토지면적 50퍼센트 이상 토지소유자의 동의와 토지등소유자 과반수의 동의를 각각 얻어야 하며, 제1항 단서에 따른 경미한 변경인 경우에는 총회 의결을 필요로 하지 아니한다.

한편, 시장·군수는 제4조 제1항의 규정에 의한 정비구역이 아닌 구역에서 시행하는 주택재건축사업의 사업시행인가를 하고자 하는 경우에는 건축물의 높이·층수·용적률 등 대통령령이 정하는 사항에 대하여 건축법 제4조의 규정에 의하여 시·군·구에 설치하는 건축위원회의 심의를 거쳐야 한다.

## 2. 사업시행계획서의 작성

사업시행자는 제4조 제5항에 따라 고시된 정비계획에 따라 다음의 사항을 포함하여 사업시행계획서를 작성하여야 한다. 다만, 도시환경정비사업(기존건축물에 주택이 포함되어 있는 사업을 제외한다)의 사업시행계획서를 작성하고자 하는 때에는 ③ 내지 ⑤의 내용을 포함하지 아니할 수 있다<sup>39)</sup>.

- ① 토지이용계획(건축물배치계획을 포함한다)
- ② 정비기반시설 및 공동이용시설의 설치계획
- ③ 임시수용시설을 포함한 주민이주대책
- ④ 세입자의 주거대책
- ⑤ 임대주택의 건설계획(주택재건축사업의 경우 제30조의3제2항에 따른 재건축소형주택의 건설계획을 말한다)

---

39) 도시및주거환경정비법 제30조.



- ⑥ 건축물의 높이 및 용적률 등에 관한 건축계획
- ⑦ 정비사업의 시행과정에서 발생하는 폐기물의 처리계획
- ⑧ 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획(정비구역으로부터 200미터 이내에 교육시설이 설치되어 있는 경우에 한한다)
- ⑨ 시행규정(시장·군수 또는 주택공사 등이 단독으로 시행하는 정비사업에 한한다)
- ⑩ 그 밖에 사업시행을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도 조례가 정하는 사항

## 제5절 관리처분계획의 작성과 인가

### 1. 분양공고 및 분양신청

사업시행자는 제28조 제4항의 규정에 의한 사업시행인가의 고시가 있는 날(사업시행인가 이후 시공자를 선정한 경우에는 시공자와 계약을 체결한 날)부터 60일 이내에 개략적인 부담금내역 및 분양신청기간 그 밖에 대통령령이 정하는 사항을 토지등 소유자에게 통지하고 분양의 대상이 되는 대지 또는 건축물의 내역 등 대통령령이 정하는 사항을 해당 지역에서 발간되는 일간신문에 공고하여야 한다. 이 경우 분양신청기간은 그 통지한 날부터 30일 이상 60일 이내로 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 제48조 제1항의 규정에 의한 관리처분계획의 수립에 지장이 없다고 판단되는 경우에는 분양신청기간을 20일의 범위 이내에서 연장할 수 있다.

대지 또는 건축물에 대한 분양을 받고자 하는 토지등 소유자는 위의 규정에 의한 분양신청기간 이내에 사업시행자에게 대지 또는 건축물에 대한 분양신청을 하여야 한다.<sup>40)</sup>

## 2. 분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치

사업시행자는 토지등소유자가 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 해당하게 된 날부터 150일 이내에 토지·건축물 또는 그 밖의 권리에 대하여 현금으로 청산하여야 한다<sup>41)</sup>.

- ① 분양신청을 하지 아니한 자
- ② 분양신청을 철회한 자
- ③ 인가된 관리처분계획에 의하여 분양대상에서 제외된 자

## 3. 관리처분계획의 인가

사업시행자(주거환경개선사업을 제외한다)는 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청의 현황을 기초로 다음의 사항이 포함된 관리처분계획을 수립하여 시장·군수의 인가를 받아야 하며, 관리처분계획을 변경·중지 또는 폐지하고자 하는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령이 정하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 때에는 시장·군수에게 신고하여야 한다<sup>42)</sup>.

- ① 분양설계
- ② 분양대상자의 주소 및 성명
- ③ 분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액
- ④ 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 사업시행인가의 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격(사업시행인가 전에 제48조의2제2항에 따라 철거된 건축물의 경우에는 시장·군수에게 허가 받은 날을 기준으로 한 가격)
- ⑤ 정비사업비의 추산액(주택재건축사업의 경우에는 재건축초

---

40) 도시및주거환경정비법 제46조.

41) 도시및주거환경정비법 제47조.

42) 도시및주거환경정비법 제48조.

과이익환수에 관한 법률에 따른 재건축부담금에 관한 사항을 포함한다) 및 그에 따른 조합원 부담규모 및 부담시기

⑥ 분양대상자의 종전의 토지 또는 건축물에 관한 소유권 외의 권리명세

⑦ 그 밖에 정비사업과 관련한 권리 등에 대하여 대통령령이 정하는 사항

이 경우 관리처분계획의 내용은 다음의 기준에 의한다.

① 종전의 토지 또는 건축물의 면적·이용상황·환경 그 밖의 사항을 종합적으로 고려하여 대지 또는 건축물이 균형있게 분양신청자에게 배분되고 합리적으로 이용되도록 한다.

② 지나치게 좁거나 넓은 토지 또는 건축물에 대하여 필요한 경우에는 이를 증가하거나 감소시켜 대지 또는 건축물이 적정 규모가 되도록 한다.

③ 너무 좁은 토지 또는 건축물이나 정비구역 지정후 분할된 토지를 취득한 자에 대하여는 현금으로 청산할 수 있다.

④ 재해 또는 위생상의 위해를 방지하기 위하여 토지의 규모를 조정할 특별한 필요가 있는 때에는 너무 좁은 토지를 증가시키거나 토지에 갈음하여 보상을 하거나 건축물의 일부와 그 건축물이 있는 대지의 공유지분을 교부할 수 있다.

⑤ 분양설계에 관한 계획은 제46조의 규정에 의한 분양신청기간이 만료되는 날을 기준으로 하여 수립한다.

⑥ 1세대 또는 1인이 1 이상의 주택 또는 토지를 소유한 경우 1주택을 공급하고, 같은 세대에 속하지 아니하는 2인 이상이 1주택 또는 1토지를 공유한 경우에는 1주택만 공급한다. 다만, 2인 이상이 1토지를 공유한 경우로서 시·도 조례로 주택공급에 관하여 따로 정하고 있는 경우에는 시·도 조례로 정하는 바에 따라 주택을 공급할 수 있고, 다음 중 어느 하나에 해당하는 토지등소

## 30 6. 이전고시와 청산금의 부과처분

유자에 대하여는 소유한 주택수만큼 공급할 수 있다.

㉠ 투기과열지구안에 위치하지 아니하는 주택재건축사업의 토지등소유자

㉡ 근로자(공무원인 근로자를 포함한다)숙소·기숙사 용도로 주택을 소유하고 있는 토지등소유자

㉢ 국가, 지방자치단체 및 주택공사 등

### 4. 관리처분계획의 공람 및 인가절차

사업시행자는 관리처분계획의 인가를 신청하기 전에 관계서류의 사본을 30일 이상 토지등 소유자에게 공람하게 하고 의견을 들어야 한다. 다만, 경미한 사항을 변경하고자 하는 경우에는 토지등소유자의 공람 및 의견청취절차를 거치지 아니할 수 있다<sup>43)</sup>.

시장·군수는 사업시행자의 관리처분계획의 인가신청이 있는 날부터 30일 이내에 인가여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 하며, 관리처분계획을 인가하는 때에는 그 내용을 당해 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다.

이러한 고시가 있는 때에는 종전의 토지 또는 건축물의 소유자·지상권자·전세권자·임차권자 등 권리자는 이전의 고시가 있는 날까지 종전의 토지 또는 건축물에 대하여 이를 사용하거나 수익할 수 없다. 다만, 사업시행자의 동의를 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.

## 제6절 이전고시와 청산금의 부과처분

### 1. 이전고시

---

43) 도시및주거환경정비법 제49조.

사업시행자는 제52조 제3항 및 제4항의 규정에 의한 고시가 있는 때에는 지체없이 대지확정측량을 하고 토지의 분할절차를 거쳐 관리처분계획에 정한 사항을 분양을 받을 자에게 통지하고 대지 또는 건축물의 소유권을 이전하여야 한다. 다만, 정비사업의 효율적인 추진을 위하여 필요한 경우에는 당해 정비사업에 관한 공사가 전부 완료되기 전에 완공된 부분에 대하여 준공인가를 받아 대지 또는 건축물별로 이를 분양받을 자에게 그 소유권을 이전할 수 있다<sup>44)</sup>.

사업시행자는 위의 규정에 의하여 대지 및 건축물의 소유권을 이전하고자 하는 때에는 그 내용을 당해 지방자치단체의 공보에 고시한 후 이를 시장·군수에게 보고하여야 한다. 이 경우 대지 또는 건축물을 분양받을 자는 고시가 있는 날의 다음 날에 그 대지 또는 건축물에 대한 소유권을 취득한다.

## 2. 청산금의 징수방법 등

### 가. 청산금 등

대지 또는 건축물을 분양받은 자가 종전에 소유하고 있던 토지 또는 건축물의 가격과 분양받은 대지 또는 건축물의 가격사이에 차이가 있는 경우에는 사업시행자는 제54조 제2항의 규정에 의한 이전의 고시가 있는 후에 그 차액에 상당하는 금액(이하 "청산금"이라 한다)을 분양받은 자로부터 징수하거나 분양받은 자에게 지급하여야 한다. 다만, 정관 등에서 분할징수 및 분할지급에 대하여 정하고 있거나 총회의 의결을 거쳐 따로 정한 경우에는 관리처분계획인가후부터 제54조제2항의 규정에 의한 이전의 고시일까

44) 도시및주거환경정비법 제54조.

## 32 6. 이전고시와 청산금의 부과처분

지 일정기간별로 분할징수하거나 분할지급할 수 있다<sup>45)</sup>.

위의 규정을 적용함에 있어서 종전에 소유하고 있던 토지 또는 건축물의 가격과 분양받은 대지 또는 건축물의 가격은 그 토지 또는 건축물의 규모·위치·용도·이용상황·정비사업비 등을 참작하여 평가하여야 한다.

### 나. 청산금의 징수방법 등

청산금을 납부할 자가 이를 납부하지 아니하는 경우에는 시장·군수인 사업시행자는 지방세체납처분의 예에 의하여 이를 징수(분할징수를 포함한다)할 수 있으며, 시장·군수가 아닌 사업시행자는 시장·군수에게 청산금의 징수를 위탁할 수 있다<sup>46)</sup>.

한편, 청산금을 지급받을 자가 이를 받을 수 없거나 거부한 때에는 사업시행자는 그 청산금을 공탁할 수 있으며, 청산금을 지급(분할지급을 포함한다)받을 권리 또는 이를 징수할 권리는 이전의 고시일 다음 날부터 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸한다.

---

45) 도시및주거환경정비법 제57조.

46) 도시및주거환경정비법 제58조.

## 제3장 주택재개발·재건축의 효과와 관련 조세제도의 현황

### 제1절 재개발·재건축의 효과와 문제점

#### 1. 재개발·재건축 사업에 관한 인식

전술한대로 1970년대 이후 대량으로 공급된 주택이 점차 노후화되면서 동시에 소득 향상에 따른 주거수준 개선 욕구가 증대되면서 재개발·재건축사업이 도시의 주거 공간 창출에 중요한 역할을 수행하였다<sup>47)</sup>. 특히 택지가 부족한 대도시에서 주택공급 확대를 위한 중요한 수단으로 활용되면서 대량의 공동주택 공급을 통한 장기적 가격안정과 토지와 공간 이용의 효율성에 기여해 왔다. 요컨대 부동산 가격상승과 주거환경 개선을 꾀하는 주택 소유자와 개발이익을 창출하려는 건설회사 그리고 주택공급 증대와 도시기능 개선 및 도시경제 활성화를 추구하는 정부의 의도가 맞아 떨어지면서 재개발·재건축사업이 활성화되었다.

기본적으로 재개발·재건축 사업이 개인재산을 활용하여 투자와 소비 욕구를 충족한다는 측면에서 시장질서에 부합하고 헌법상의 주거권 향상에 도움이 된다. 더욱이 주택 보유가 다양한 긍정적인 외부효과를 유발한다는 측면에서 우리나라를 포함한 대다수 국가들이 주택을 특별히 취급하는 경향이 있다. 문제는 도시재개발·재건축이 기존 주택을 포함한 공동체 구조와 밀도뿐만 아니라 주변 지역사회에 상당한 영향을 미칠 수 있으므로 대부분 국가에서 이해관계가 균형을 이루고 나아가 지역사회에 도움이

47) 재건축의 경우 1987년 주택건설 촉진법으로 법적 근거가 마련되었다.

## 34 1. 재개발·재건축의 효과와 문제점

될 수 있도록 재개발·재건축 사업을 규제한다.

특히 우리나라 재개발·재건축 사업은 양적 공급을 강조하는 등 개발이익에 초점을 맞춘 방식으로 진행되어 기존 공동체를 해체하고 주변 환경에 피해가 되는 경우가 다수 발생한 바 있다. 즉, 원주민이나 소외계층의 이해가 제대로 반영되지 않은 재개발·재건축은 항상 끊임없는 분란을 유발해왔고 최근에는 용산참사가 발생하게 된 원인이 되었다. 더욱이 정부는 용적률과 건폐율 완화를 통하여 상당한 개발이익을 보장하면서 재개발·재건축을 비정상적인 투자대상으로 인식하게끔 하였다. 이는 물론 도시발전에 대한 기본적인 철학과 체계적인 계획 없이 상황에 따라 대응하거나 경기부양이라는 명분하에 업체 로비에 휘둘려 왔던 정부에게 잘못이 있다.

돌이켜보면 재개발·재건축이 지역주민에게 쾌적한 공간을 확보하기는커녕 난개발로 인한 갈등과 분란의 소지가 된 사례가 많다. 또한 도심 개발에 따라 영세민이 변방지역으로 이전하여 발생하는 지역 문제는 국가 차원에서 전혀 고려되지 않고 있다. 이러한 우리나라의 특수한 상황은 재개발·재건축 사업의 긍정적인 측면에도 불구하고 바람직하지 않은 인상을 국민에게 주었고 이에 따라 재개발·재건축에 대한 과세도 영향을 받기에 이르렀다. 이러한 상황에서 본 절에서는 주택재개발·재건축을 둘러싼 논쟁에 대하여 논의하고 개선방향을 검토함으로써 향후 과세방향을 정리하는데 일조하고자 한다.

## 2. 재개발·재건축 사업의 효과

### 가. 주택보유로 인한 사회적 혜택



재개발·재건축을 논의하기 앞서서 주택의 본질적 특성을 생각해볼 필요가 있다. 주택은 일반적 재화와 달리 소비재이면서 투자재이다. 즉, 주택은 가구의 소비, 복지, 생산이 발생하는 공간으로 사유재인 동시에 생산과 경제활동에 간접적인 영향을 미치는 자본재적 성격이 있다.

또한 주택은 지역적 위치가 고정되어 있는 재화이며 이를 통하여 외부효과 즉 사회적 연대가 이루어지는 재화라는 측면에서 다른 재화와 확연히 구분되는 특성을 갖는다. 즉, 주택의 물리적 고정성은 학군, 교통, 지역 환경 등 주변여건에 따라 가격이 변화함을 의미하고 주택 소비와 공급행태가 주택을 포함한 주변 지역에 영향을 준다(neighborhood effect)<sup>48)</sup>. 환언하면 주택은 지역 공동체를 형성하는 기본단위가 된다는 측면에서 공공재에 영향을 준다. 이에 비하면 주택 공급에 긴 시간이 소요되고 가격의 등락이 주기적으로 발생하고 다른 재화와 달리 감가상각 보다는 가격 상승이 발생한다. 이에 따라 강도의 차이는 있지만 많은 국가에서 부동산 불패신화가 성립할 때 투자의 확실한 수단으로 자리 매김하는 경향을 보인다.

특히 우리나라는 다른 나라에 비하여 부동산이 가계자산이나 국부에서 차지하는 비중이 매우 높다. 일부 연구에 의하면 부동산이 가계자산에서 차지하는 비중이 미국 34%, 일본 42%인데 비하여 우리나라는 무려 88%에 달한다는 연구가 있다(김경환(2008)). 통계청 국부조사에 의하면 2006년 현재 우리나라 자산총액에서 토지가 차지하는 비중은 51%, 주거용 건물과 비주거용 건물이 각각 11%와 10%를 차지하고 있어 전체 부동산이 자산총액에서 차지하는 비중은 72%에 달하는데 비하여 자본설비가 차지하는 비

48) Coulson, N. Edward, Seok-Joon Hwang, and Susumu Imai, "The Value of Owner Occupations in Neighborhoods", *Journal of Housing Research* 13(2), 2003, p.153-174.

중은 19%에 불과하여 부동산에 대한 과잉투자에 비하면 고정산업설비 투자에는 인색하다. 나아가 가계대출의 상당 부분이 주택을 담보로 하여 금융시장에 시사하는 바가 크다.

그러나 주택 보유는 주택 소유자와 사회 전체에 다양한 혜택을 제공한다. 주택보유율이 높을수록 성취감과 만족도가 높고 가정이 안정되는 효과가 있다. 또한 지역주민의 사회 공동체 참여율과 범죄 감소율이 증가하고 자녀의 학업 성취율이 높고 환경개선효과도 있다. 주택이라는 자산 가치를 보호하기 위하여 주택 소유자는 지역사회에 적극적으로 참여하는 경향을 보이기 때문이다. 이는 교육과 소득수준 그리고 혼인관계 등 각종 개인적 특성을 통제한 상황에서 발생하여 주택보유 자체가 사회적으로 바람직한 효과를 유발함을 보여준다. 이와 같은 이유로 대부분 국가에서 1가구 1주택 비과세나 주택 대출금 이자공제 등 주택 소유에 대한 과세상 혜택을 부여하고 있음은 주지의 사실이다.

주택을 구성하는 핵심 요소인 토지는 그러나 한정된 공급으로 사회적 문제를 유발하는 요인이 된다. 즉, 토지공급의 제한성은 일반적 수요공급이론을 적용하기 어려운 상황을 유발한다. 또한 토지는 생산요소의 일원이고 주택소비에 근원이 되지만 공급이 일정하고 재생산이 불가능하기 때문에 이에 대한 과도한 투자는 국가경제에 심각한 피해를 유발하고 불로소득을 창출하는 요인이 된다.

한편 주택공급에 시간이 소요된다는 사실은 주택가격의 급등과 불안정성을 초래하는 원인이 된다. 주택이 사회복지에 미치는 영향과 국가경제 특히 생계비에서 차지하는 비중을 고려하면 주택가격의 급등은 물가상승을 유발하고 부동산에 대한 비생산적 경제활동을 부추겨 국가경쟁력에 심각한 피해를 줄 수 있다. 부동산 거품이 문제가 되는 이유는 금융자본의 과도한 투자 이외에도 인

력 등 여타 국가자원이 낭비되는 반면 임금과 임대료 등 생산비용의 상승으로 여타 산업이 피해를 입기 때문에 인위적인 인플레이션 이상으로 국가경제에 해가 되기 때문이다. 더욱이 전술한대로 주택 보유가 유발하는 사회적 혜택을 감안하면 주택가격 급등은 무주택자의 근로욕구를 저하하고 사회적 갈등을 유발하는 등 지속적인 경제성장에서 중요하게 지목받고 있는 사회적 자본(social capital)을 저해하는 요인이 된다.

이처럼 주택과 토지가 국가경제와 사회복지에 미치는 영향을 고려할 때 공익적 개념이 부동산시장에 적용되어야 한다는 주장이 제기될 수 있다. 한 예로 토지 공개념의 일환으로 사유재산제를 근간으로 토지규제, 세제 혹은 제한적 수용을 통하여 부동산 거품을 미리 차단하고 시장기능의 취약점을 보완할 필요가 있다. 이러한 토지의 공익개념 논란을 떠나 한 가지 분명한 것은 일정 지역에서 토지공급이 제한될 수 있지만 용적률과 용도제한 등 규제를 완화할 경우 주택 등의 공급은 상당히 증대될 수 있기 때문에 부동산과 관련하여 암묵적이던 아니던 상관없이 정부가 일정한 역할을 하고 있다는 사실이다.

#### 나. 우리나라 토지개발정책의 변천

우리나라는 1960년대에 도입된 도시계획법과 토지구획정리사업법 등 각종 택지개발에 관한 법률을 배경으로 지방자치단체를 중심으로 토지구획정리사업이 이루어지고 민간업체에 의한 개발이 진행되었다. 그러나, 1970년대 공동주택 활성화로 새로운 거주문화가 도입되면서 계획적이지 않은 개발로 지가가 상승하여 투기가 발생하자 정부는 1980년에 택지개발촉진법을 제정하여 택지개발지역을 지정하고 공공부문이 토지를 매수하여 주택을 조성하는

공영개발방식을 도입하였다.

이를 통하여 택지개발로 발생하는 개발이익을 정부가 흡수하고, 조성된 용지를 원가수준에서 저렴한 가격으로 공급하며 주민편익 시설을 미리 완비할 수 있었다. 또한 이러한 대규모 공영개발방식으로 공동주택 90% 이상을 공급하여 안정적인 주택가격을 유지하였고 특히 주택분양가격 규제<sup>49)</sup>를 통하여 주택 구입자가 큰 혜택을 입었다. 또한 1990년대 초 부동산가격이 급등하자 수도권 신도시를 중심으로 주택 200만호를 건설하였다. 이 밖에도 정부의 국토이용계획은 선보전후개발 원칙에 입각하여 규제가 적용되었으며 주택시장에서 정부의 역할이 압도적이었다.

그러나, 택지와 공장용지가 부족하다는 목소리가 높아지자 정부는 토지수급 불균형을 해소한다는 명목 하에 1993년 국토이용계획을 전면 개편하여 10개 용도지역을 5개 용도지역으로 단순화하고 준농림지역을 지정하여 농어촌 지역에서도 토지개발이 이루어질 수 있도록 토지규제를 완화하였다. 준농림지역이 도입되기 이전에는 공공개발자 이외에는 공동주택 단지를 건설할 수 없었으나, 이제는 환경오염이나 고밀도 개발을 제외하면 준농림지역을 준도시지역으로 변경하여 주택이나 공장 건설 등 대부분 개발행위가 가능해졌다.

준도시지역의 경우 용적률이 150%로 제한되었으나 주변경관에 문제가 없으면 250% 용적률까지 허용되었다. 그 결과, 용인 등 수도권지역에 도시계획이나 기반시설 없이 고층의 민간 공동주택이 대량으로 조성된 바 있다. 이후 1999년 난개발을 방지하고 선

---

49) 공영개발제와 함께 우리나라 주택정책의 또다른 한축인 주택분양가 규제는 1977년 사업계획서 승인을 통하여 처음 도입되었고 그 후 1980년대에 전용면적을 기준한 평당 가격상한제 그리고 신도시 건설에서는 적정이윤을 보장하는 원가연동제가 도입되었다가 1998년 외환위기 이후 건설경기 부양을 위하여 전국적으로 분양가가 자율화되었다.

계획·후개발 원칙을 준수하기 위하여 국토이용관리법과 도시계획법으로 이원화된 국토 이용체계를 통합하는 국토계획법(국토의 계획 및 이용에 관한 법률)이 도입되었다. 국토계획법에서는 문제가 되었던 준도시지역과 준농림지역을 관리지역으로 통합하는 등 용도지역 개편과 제2종지구단위계획제<sup>50)</sup>, 개발행위허가제와 기반시설연동제 개념이 도입되었다. 이후 2003년에는 개별 법령에 따라 진행되었던 도시정비, 개발과 재건축을 계획적으로 입안하고 정비하기 위하여 이를 통합한 도시 및 주거환경 정비법을 도입하였다<sup>51)</sup>.

#### 다. 재개발·재건축의 혜택

재개발·재건축 사업은 노후 또는 낙후주택 개량과 도로 등 취약한 공공시설 정비 그리고 토지와 공간의 효율적 이용 등 도시계획적 측면과 함께 부족한 거주공간 확보와 주거복지 향상 등 주택의 공급적 측면을 동시에 내포하고 있다.<sup>52)</sup> 즉, 관리가 제대로 안된 노후 불량주택은 본인뿐만 아니라 인근 지역에도 피해가 되고 도시환경과 미관을 보호하며 토지이용의 효율화를 위하여

50) 개발수요가 많은 비도시지역에 대하여 개발제한을 완화하는 대신 사전에 계획을 수립하여 체계적인 토지이용, 기반시설 설립과 환경보존을 추구하는 제도이다.

51) 인구 50만 이상의 도시는 주거환경정비기본계획을 수립하고 이에 따라 도시정비지역을 개발과 보존지구로 나누어 개발밀도, 교통 및 기반시설계획을 확보하도록 하고 재개발·재건축사업을 통합하여 사업진행요건을 더 엄격하게 하였다. 한 예로 단독주택지를 공동주택지로 전환 재건축하려면 20년 이상 노후화된 주택이 2/3 이상이고 안전진단을 거쳐 도시계획위원회 심의를 거쳐야 한다.

52) 한 예로 재건축의 경우 20년 이상 경과하고 도시미관, 토지이용도 혹은 구조적 결함으로 재건축이 불가피한 경우 재건축이 가능한데 재건축이 부동산 투기대상이 되면서 요건이 강화되어 도시정비법상 도시주거환경정비기본계획에 의거하여 사업이 지정되어야 한다.

#### 40 1. 재개발·재건축의 효과와 문제점

개발 잠재력이 충분한 노후지역에 대해서는 지역을 입체적으로 개발하고 기반시설을 공급함으로써 효율적인 토지 이용을 도모할 필요가 있다. 이 과정에서 물론 지역 공동체 보존과 함께 영세민을 보호하기 위한 사회 복지적 측면을 고려하여 개발계획을 수립해야 한다.

그러나, 실제로는 재개발·재건축사업이 주택 소유자와 개발업자 입장에서 개발이익을 극대화하고 정부 입장에서는 주택공급 증대와 경기부양 목적으로 시행되면서 끊임없는 논란과 분쟁이 발생하고 있다. 특히 정부와 개발업체(가옥주) 사이에는 용적률과 기반시설 부담 문제가 논란이 되고 개발업체(가옥주)와 세입자 사이에는 보상 즉, 개발이익의 분배문제가 분쟁으로 비화된다. 이에 비하면 조화롭고 체계적인 도시건설과 적절한 도시경관은 구호로 끝나는 경향이 많다.

그 결과 주거의 질은 낮았지만 부담 가능한 주거 공간이 줄어들고 교통, 학교, 녹지 확보 등 주변 여건은 고려하지 않은 채 지나친 고층·고밀도 개발로 도시공간 배분이 왜곡되는 경향이 있다<sup>53)</sup>. 과거 재개발사업은 그나마 고시 계획사업이므로 개발단계에서 미흡하나마 공공편익시설을 배려하고 있지만, 재건축사업은 민간사업으로 그럴 필요가 없었다.

한 예로 분당이나 일산처럼 처음에는 체계적인 계획에 따라 건설된 신도시도 나중에는 주변의 난개발로 무질서한 밀집현상을 보여 선진국과 같은 도시경관을 유지하기 어려워 보인다. 이는 주택의 개보축마저도 지역사회의 심의를 거쳐 허가를 받는 등 용도제한 구역계획(zoning)을 통하여 같은 공동체내에서 주택의 동질성을 유지하는 선진국과는 상당히 다른 우리나라만의 현상이다.

---

53) 1991년 건축법 완화로 일반주거지역 용적률이 250%에서 350%로 상승하면서 28~30층 공동주택 건축이 허용되었다.

즉, 선진국 주택규제는 토지이용 규제를 보수적으로 운영하고 지역 동질성을 보호함으로써 주택가격 하락을 방지하는 효과가 있는 반면 우리나라는 반대로 고밀도 고층 공동주택 건설로 주택서비스 향상과 가격인상을 기대한다는 측면에서 다르다.

이러한 현상이 발생하게 된 근저에는 물론 수도권 집중에 따른 주택부족 현상으로 말미암아 재개발·재건축 사업의 궁극적 목적이 주택공급 확충에 있었기 때문이다. 즉, 개발방식이 개발밀도에 대한 사회적 합의 없이 주택 잉여분을 주택 수요자에게 분양하여 주택건설비용을 조달하는 방식으로 주민 부담이 없어 개발계획에 따른 기대감이 팽배하여 부동산 거품 형성을 자극하였다.

정부는 주택공급을 늘이기 위하여 관대한 용적률을 보장하고 주택 소유자는 이를 통하여 상당한 개발이익을 향유하는 이해관계의 상승작용이 있었다. 또한 기초자치단체는 도시 전체의 미래를 고려한 점진적이고 체계적인 정비정책을 통하여 공간을 확보하고 공공시설을 조성하며 과도한 가격상승을 통제하지 않고, 재개발·재건축을 부추겨서 더욱 문제가 되기도 한다<sup>54)</sup>. 결국 재개발·재건축사업이 주택공급에는 기여할지 몰라도 주택가격 안정이나 도시민 주거 안정에 기여한다고는 보기 어렵다<sup>55)</sup>.

세입자나 재개발 이후 실제 거주자에 대한 이익은 무시되는 경향을 보여 분쟁이 발생하고 공원이나 학교, 교통여건 등 개발 이

54) 이러한 문제점으로 정부는 2001년 도시 및 주거환경 정비법을 통하여 도시주거지역의 계획적 정비를 목표로 주거환경개선사업, 주택재개발사업, 주택재건축사업을 통합 3개의 독립된 법률로 각각 다른 방식으로 진행되던 주거정비사업을 통합한 바 있다.

55) 세입자 문제는 당사자 사이의 임대차계약이나 재건축조합과 세입자 사이의 협의로 해결하도록 방지하여 앞으로도 용산사태와 같은 분쟁이 발생할 소지가 있다. 이외 과밀화로 인한 도로부족으로 인한 교통 등 환경평가가 미흡하고 일조권이나 시계제한 등 기존 주민에게 불이익이 발생하고 안전진단 기준이 모호하거나 상이한 문제점이 있다. 후자의 경우 주택이 조기에 멸실되어 자원이 낭비될 우려가 있다.

## 42 1. 재개발·재건축의 효과와 문제점

후 각종 기반시설 부족으로 인한 논란이 계속되고 있다. 특히 세입자가 해당 지역에서 누렸던 영업권을 인정하려는 인식이 부족하다. 한편 재건축 저밀도 공동주택이 투자대상으로 인식되면서 재건축 공동주택 가격이 급격히 상승하고 주변 지역으로 대기수요가 확산되면서 주기적으로 주택시장 과열현상이 나타나고 있다. 그러나 현재 고층으로 건설된 공동주택의 수명이 다할 경우 이를 둘러싼 논란이 사회 문제가 될 수 있다.

이처럼 우리나라 재개발·재건축에서는 물리적 개발만 있고 사회적 공동체 형성이라는 개념이 존재하지 않는다. 보다 본질적으로는 우리나라에서 지방자치에 대한 역사적 경험이 일천한 사실도 이러한 성격의 개발을 촉진하는 측면이 있다. 나아가 중앙정부도 재개발·재건축 사업을 경제적 논리 아래 주택공급 증대와 경기부양을 위한 사업으로만 보는 측면이 이러한 경향에 일조한 바 있다. 특히 재개발·재건축과는 별도로 기존 주택의 개보수와 공공시설 정비가 주목적인 주거환경 개선사업이 지역공동체를 보존하는 효과가 있지만 정부지원 부족으로 지지부진하면서 우리나라 주거환경 개선사업은 재개발·재건축사업만 있는 것으로 인식되고 있다.

물론 현실적 입장에서 수요는 많으나 개발여력이 없는 서울 등의 지역에서 재개발·재건축이 주택공급과 가격안정에 긍정적인 역할을 할 수 있다. 즉, 서울공화국으로 불릴 만큼 서울 중심의 경제성장으로 서울과 주변지역에 개발 가능한 토지는 절대적으로 부족하며, 재개발과 재건축만이 경제발전과 수도권 인구증대에 따른 주택수요 확대를 충족할 수 있는 유일한 방안이다. 한 예로 1980년~2005년 사이에 우리나라의 국민 실질소득은 약 4배, 1인당 주거면적은 2배, 가구당 주거면적은 50% 가까이 증가한 바 있다<sup>56)</sup>.



재개발·재건축은 불확실성이 높은 사업으로 사후적으로 수익률이 높다는 이유로 제약을 하는 규제는 바람직하지 않다<sup>57)</sup>. 즉, 복잡한 재개발절차와 그 과정에서의 이해관계 조정은 결국 높은 기대 수익률이 보장되어야 재개발 및 재건축 사업이 추진될 수 있음을 의미한다. 이러한 개발 성격을 무시하고 투기방지의 목적으로 재개발·재건축을 억제할 경우 고품질의 주택공급 부족이 오히려 주택가격 급등의 진원지가 될 수 있다. 특히 주택가격 상승을 강남 등 특정 지역으로 한정할 수 없다면 그 부작용은 심각할 수 있다.

재개발을 옹호하는 주장을 보면 도시 순환의 성숙기에 이르러 발생하는 재개발·재건축은 오히려 토지와 공간의 효율적 이용을 제고하고 교통비용 등 각종 사회적 비용을 감축하는 방안이 될 수 있다(이창무(2008)). 수요와 공급이라는 시장의 작동원리에 따라 자연스럽게 진행되는 이들 사업은 정부 차원에서 더욱 활성화할 필요가 있다. 교외 지역의 개발보다는 도심개발이 각종 사회·경제행위의 시간, 교통, 이행비용을 줄이고 효율성을 증대하는 효과가 있기 때문이다. 특히 뉴타운사업 등 재건축에 비하여 사회기반시설이 부족하거나 낙후지역을 대상으로 하는 재개발의 경우 사업 활성화를 위해 정부의 직간접 지원이 필요하다.

이러한 측면에서 볼 때 재개발·재건축을 둘러싼 각종 규제나 개발이익 환수장치는 적정 수익률 확보를 저해함으로써 사회적으로도 바람직하지 않을 수 있다. 개발 부담금, 소형 및 임대주택공급비율, 분양가 규제, 1가구 다주택 소유자 중과세 등이 이에 해

56) 이창무(2008), “주택시장 정상화 방안”, 부동산 시장 정상화 방안 모색을 위한 정책토론회, 한국재정학회

57) 재개발이익에 영향을 주는 요인은 사업을 전후한 주택가격, 용적률, 철거비용, 공사비, 세입자 이주비, 이자율, 개발 부담금, 부동산세 세율 등이 있을 수 있다.

#### 44 1. 재개발·재건축의 효과와 문제점

당한다. 특히 개발 부담금이 개발이익의 환수장치가 되어서는 안 되며 적정부담원칙(proportionate share)에 따라 재개발로 유발되는 사회적 기반시설이나 공공 서비스 구축비용을 부담하는 수준에 한정되어야 한다.

또한 시장원리에 기초한 재개발·재건축에서 원주민 정착이 우선적 목표가 돼서는 사업이 제대로 추진될 수 없다. 물론 토지 원소유자, 건설사, 세입자 그리고 정부 등 이해 관계자 사이에 개발이익을 배분하는 과정에서 경제적 약자를 존중해야 하나 개발주체의 이해관계를 무시해서는 적절한 주택공급이 이루어질 수 없다.

요컨대 투기로 인한 주택가격 급등은 허구적 수요 문제이므로 대출규제 등 주택수요 관리차원에서 접근을 하고 주택공급을 제한하는 정책을 사용해서는 안된다. 또한 재개발·재건축은 이로 인한 혼잡비용만 고려할 것이 아니라 기회비용 즉, 교외 지역에 위성도시를 건립함에 따라 발생하는 비용과 비교하여 촉진 여부를 결정할 일이라는 주장이 제기될 수 있다.

정리하면 개발지가 남아 있지 않은 대도시에서 기성 주택지역의 재정비만이 수요가 많은 지역에서 가격을 안정시킬 수 있는 정도의 물량을 공급할 수 있는 대안일 수 있다. 다양한 긍정적 외부효과를 유발하는 도시 개발은 토지이용과 경제적 효율성을 제고할 수 있다. 무분별한 개발로 인한 교통이나 공해문제는 주도면밀한 개발계획을 통하여 해결할 수 있다. 그러나 현실적으로 볼 때 개발사업이 종합적이고 체계적인 도시계획 측면에서 진행되지 않고 단위사업으로 이루어지며 특히 개발이익 극대화에 초점을 맞추어 일방적인 사업자 중심으로 편향되는 경향이 강하다. 나아가 고밀도 고층 개발이 장기적으로 해당 주민이나 도시 전체에 미칠 경제적, 사회적 파장이 제대로 검토되지 않고 있는 것이 우

려된다.

수도권 집중현상이 심각하지 않은 선진국에서는 도시 재개발사업이 주로 기초자치단체와 해당 지역주민의 주도 아래 지역 공동체 보존과 경제 활성화 목적으로 진행되는 경향이 있다. 미국의 경우 1960년대 이후 빈민 유입으로 주거환경이 크게 악화된 도시를 중심으로 개발 사업을 추진하였으나, 저소득층에 대한 배려 없이 정부 상층부에서 정책이 일방적으로 결정되어 큰 반발이 있었다.

이에 따라 연방정부는 1970년대 이후 도시문제를 물리적, 공간적 실체가 아닌 사회복지 측면에서 접근하여 지역주민이 참여하는 공동체 강화와 고용 중심의 협력사업으로 전환하여 성공을 거둔 바 있다<sup>58)</sup>. 물론 개발에 따른 임대료 상승으로 아직도 지역 영세민이 개발지역에서 떠나야만 하는 상황이 발생하고 있으나 정부는 공공임대주택 건립을 통하여 이러한 문제를 나름대로 최소화하고 있다. 구체적으로 연방정부는 1970년에 공동체 개발법(community development act: CDA)을 제정하고 이를 뒷받침하기 위한 공동체 개발보조금제도(community development action grant)를 도입한 바 있다.

동 제도 아래서 지방자치단체는 주민과 협력하여 사업을 추진하는데 연방정부는 경쟁적 구도 아래 사업을 승인한다. 승인을 받은 사업은 연방정부가 포괄적 보조금과 장기 융자를 지원하는데 주택개량을 통한 공동체 보존과 공동체 기반시설 향상 그리고 고용증진과 기업유치 등 지역경제기반 강화를 목표로 한다. 또한 지방정부 차원에서는 재산세 등 세제감면 혜택을 부여한다.

최근에는 일부 지역에서 재개발 이후 발생하는 재산세를 담보로 채권을 발행하여 이를 재원으로 재개발하는 사업방식이 활발

58) 차문중편(2004), 주택시장 분석과 정책과제 연구, 한국개발원(KDI)

하게 추진되고 있다(tax increment financing: TIF)<sup>59)</sup>. 지방자치단체 특히 지방의회가 재개발이 필요한 지역과 사업을 결정하면 지방정부는 도시재개발 채권을 발행하여 사업을 진행하고 이후 재개발에 의한 부동산 가격 상승으로 발생하는 재산세 수입으로 채권이자와 원금을 지급한다. 미래의 세수를 담보로 개발사업 재원을 충당하는 방식은 1952년 캘리포니아에서 처음 시행되어 애리조나 주를 제외한 미국 전 지역에서 사업이 진행되고 있다.

한 예로 시카고에서는 130개 사업이 추진되고 있는데 재개발 이후 일정기간(23년) 동안 발생하는 재산세 수입 증대분을 지역도로, 다리 등 사회간접자본, 학교나 공원 등 공공시설 개선, 주택 혹은 상업·산업시설 개발에 투입한다. 주택의 경우 저소득층을 제외한 건축비용에는 투자할 수 없다. 일각에서는 그러나 지역사회를 위한 개발이 아니고 재개발사업자 로비로 재원이 남용되고 세수 증대분이 채권이자 지급에 사용됨으로써 장기적으로 지역에 필요한 공공서비스 재원이 부족하여 재산세 등 세수 인상을 촉발하는 원인이 된다는 비판도 있다.

한편 영국에서는 1990년대 초 도시재생법(urban regeneration act: URA)을 제정하여 도시정비사업을 진행한 바 있다. 사업은 미국의 공동체 개발법과 유사하게 세입자 등 저소득층을 배려한 사업으로 리모델링 위주의 주택개량사업으로 지역경제에 대한 기여도가 고려된다. 일본에서도 1990년대 지역주민을 중심으로 지역공동체 개발정비 사업을 추진하여 과거와 같은 정부 주도의 도심재개발 사업을 지양하고 민간주도의 창의적 참여를 촉진하는 제3섹터 형식으로 지역주민, 민간기업, 정부 계약 방식으로 주민자치기구가 재정비사업에 적극적으로 참여한다. 이처럼 선진국의 경우

59) North Dakota Office of State Tax Commissioner(2003), Urban Renewal Tax Increment Financing Guideline, North Dakota Century Code § 40-58-20(taxinfo@state.nd.us)

개발 사업을 주택정비사업에 국한하지 않고 사회복지기능과 지역 경제 활성화 등 다면적 차원에서 접근하고 지역 공동체를 살리고 보전하는데 역점을 둔다. 지역주민이 주택개선에 투자하는 만큼 정부는 교육, 교통, 공공시설에 투자한다.

#### 라. 개발이익과 개발 부담금

재개발·재건축 사업의 성패를 좌우하는 사항은 용적률과 기반 시설 부담에 따른 개발이익이다. 전술한대로 재개발·재건축이 개발 토지가 부족한 도시에서 주거복지를 향상하고 주택공급을 증대한다는 측면에서 적정 수익을 보장하지 않는 과도한 규제는 바람직하지 않을 수 있다. 특히 양도소득세가 이미 존재하는 상황에서 인구 유입에 따른 기반시설 확보를 명목으로 개발이익을 별도로 환수하는 데에 대한 비판이 있다.

이에 대하여 투기를 방지하고 토지의 효율적 이용을 촉진하기 위하여 개발이익을 환수해야 한다고 반론이 제기될 수 있다. 이는 개발이익이 토지 소유자 노력에 의한 대가가 아니라 토지와 주변 지역에 내재된 속성에 기인하기 때문에 공동이익을 위하여 활용해야 한다는 토지공개념에 기초한 반론이다<sup>60)</sup>. 이에 따라 1989년 개발이익환수에 관한 법률 및 토지초과이득세법 그리고 택지소유 상한에 관한 법률 등이 도입된 적이 있으나 미실현 이익에 기초한 과세는 위헌 판정을 받은 바 있다.

현재 개발이익은 부담금 명목으로 개발자로부터 일부 환수되고 있다. 즉, 1986년 제정된 개발이익 환수에 관한 법률에 따른 개발 부담금과 2006년 도입된 재건축 초과이익 환수에 관한 법률에 따

60) 최수·박재길 외(2006), 재건축사업의 도시 계획적 관리 및 개발이익환수방안, 국토연자 2006-15, 국토연구원

## 48 1. 재개발·재건축의 효과와 문제점

른 재건축 부담금은 재개발·재건축 사업으로 발생하는 개발이익을 환수함으로써 주택가격 안정과 토지의 효율적 이용을 도모하고 국민경제의 건전한 발전을 추구하는데 그 목적이 있다.

개발 부담금의 경우 적용대상 개발이익 즉, 부과기준은 사업 종료시점 토지가액에서 개시시점 토지가액, 정상 토지가격 상승분과 개발비용을 제외한 금액이 된다<sup>61)</sup>. 재건축 부담금에서도 부과기준은 같은 방식으로 산정되는데 토지가 아니라 주택가격이 대상 지표가 된다<sup>62)</sup>. 이렇게 산정된 개발이익(재건축초과이익)에서 환수되는 비율(부담률)은 개발 부담금의 경우 25%이며 재건축 부담금의 경우 조합원 1인당 평균이익에 따라 0~50%의 누진율이 적용된다.

원래 부담금은 공익사업으로부터 특별한 이익을 받는 자에 대하여 그 사업에 소요되는 경비 전부 또는 일부를 부담시키기 위하여 부과하는 공법상의 금전지급의무에 해당한다. 그러나 개발 부담금이나 재건축 부담금은 불로소득을 환수하는 세금의 성격을 갖는다. 즉, 국가가 개발하는 사업이나 용적률 상향조정 등 개인 노력과 무관한 요인으로 주택·토지가격이 큰 폭으로 상승하여 불로소득이 창출되고 투기적 수요가 유입되는 상황을 방지하여 부동산 가격안정을 추구하기 위한 조치이다<sup>63)</sup>.

---

61) 개발 부담금이 부과되는 개발 사업은 택지개발사업, 관광단지조성사업, 골프장 건설사업 및 도시환경정비사업 등이며 지목 변경이 수반되는 다음의 사업을 대상으로 한다: ① 단독주택, 공동주택, 제1종 근린생활시설 및 제2종 근린생활시설 ② 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설 및 운동시설 ③ 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 공장 및 창고시설 ④ 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설 및 관광휴게시설.

62) 재건축 부담금의 대상사업은 도시 및 주거환경 정비법에 의한 주택 재건축사업으로 부담금 산정의 기준이 되는 시점은 각각 추진위 설립 승인일로부터 재건축 사업 준공일이다. 재건축 부담금은 사업단지 전체에 대한 부담금 산정 후 개별 조합원 부담금을 다시 산정한다.

63) 이외 임대주택 의무비율 혹은 재건축의 소형주택 의무비율도 개발이익

여기서 쟁점이 되는 부분은 원활한 용지 공급을 위해 도시계획 및 토지용도를 변경함에 따라서 발생하는 가격 상승분에서 어느 정도가 개발이익(불로소득)에 해당하는가이다. 즉, 정부의 토지·도시계획 변경, 기타 주변 환경적 요인(amenities), 주택·토지 소유자의 투자적 요인을 구분하기 어려워 적정한 개발이익 설정이 쉽지 않다. 한 예로 부동산의 평가 시점 결정에 따라 개발이익 산정이 크게 달라질 수 있다. 특히 사업 승인시점 가격을 개시시점 가격으로 간주하여 개발이익에서 가격 상승분을 제외하는 현행 방식은 이미 예고된 개발·재건축 사업의 경우 개발이익이 제대로 환수되지 않는 문제가 있다. 또한 개발이익의 공간적 범위나 형평성 문제로 개발자의 저항을 초래하거나 반대로 의도한 정책 목표를 달성하지 못할 수 있다.

전술한대로 부담금은 원래 사업으로 인한 비용을 그 이익이 돌아가는 수혜자가 부담하는 수익자부담원칙이나 비용을 유발한 개발자가 부담하도록 하는 원인자부담원칙에 의하여 부과되는 과징금 혹은 수수료에 해당한다. 이러한 성격의 부담금에는 기반시설 부담금, 광역교통 부담금, 학교용지부담금 등이 있다<sup>64)</sup>. 이들 부담금은 개발에 따른 인구유입으로 발생하는 각종 기반시설이나 공공재 수요를 충족하기 위하여 공급되는 비용을 원인자가 부담하도록 하는 제도이다.

---

환수와 원주민 보호차원에서 도입될 수 있지만 이는 방송 주파수처럼 공간권 사용에 대한 수수료로 볼 수도 있다.

64) 학교용지 부담금은 도시계획구역 이외 지역에 분양가의 0.8%가 부과되는 방식이었으나 국가가 의무교육비용을 부담해야 한다는 취지 아래 2005년 위헌판결이 내려진 부담금이다. 광역교통시설 부담금은 광역교통시설 재원 확충을 통한 교통난 완화를 위하여 공공부문과 민간부인이 비용을 분담하고 난개발을 완화하기 위한 목적에서 대도시 광역교통 수요에 영향을 미치는 대규모 택지개발, 도시개발, 대지조성, 주택재개발 재건축에 적용된다.

이 가운데 기반시설 부담금은 건축행위로 인하여 유발되는 기반시설 설치, 정비, 개량에 필요한 재원을 개발 행위자에게 부담하게 하는 제도로써 2005년 8.31 부동산 종합대책의 일환으로 부과되었다. 적용 대상은 연면적 200㎡(60평)를 초과하는 건축물의 건축행위로서 재원은 도로, 공원, 녹지, 상수도, 하수도, 학교, 폐기물처리시설 등 7개 기반시설을 설치하는데 사용된다. 기반시설 설치에 소요되는 총비용 중 국가·지방자치단체의 부담분을 제외하고 민간 개발사업자가 부담하는 비율은 기반시설부담금의 20%로 하되, 지자체의 장이 25%의 범위 내에서 가감할 수 있다. 기반시설부담금은 표준시설비용과 용지비용을 합산한 금액에 200㎡(60평)를 초과하는 건축연면적과 부담률을 곱해서 산정한다<sup>65)</sup>.

기반시설 부담금은 이미 기반시설이 확보된 지역에 부과되거나 도시계획세<sup>66)</sup>나 공동시설세<sup>67)</sup>와 각종 부담금이 존재하는 상황에서 이중 부과가 우려되고 원인자부담원칙과 같은 원래 취지와 달리 분양가격에 부담금이 전가되고 투자심리가 위축된다는 이유로 2008년 폐지된 바 있다. 다만 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에

65) 표준시설비용은 단위당 시설비로서 당해 연도의 생산자 물가상승률 등을 고려해 매년 고시된다(2006년 58,000원/㎡). 용지비용은 지역별 기반시설 상황을 고려하여 0.4의 범위 내(녹지 및 비도시지역 0.4, 주거지역 0.3, 공업지역 0.2, 상업지역 0.1)에서 대통령령으로 정하는 용지환산계수와 시·군·구별 평균 및 건축물별 기반시설 유발계수를 곱하여 산정한다.

66) 도시계획세는 도로 개설, 상·하수도, 공원 등 도시계획사업에 필요한 비용에 충당하기 위하여 부과되는 목적세로서 재산세를 부과할 때 함께 고지된다(지방세법 제235조). 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제6조에 의해 고시된 도시계획구역 토지와 건축물 또는 주택이 과세대상이며 세율은 과세표준의 0.2%이다.

67) 소방시설이나 오물처리시설 등 공공시설에 필요한 비용에 충당하기 위하여 그 시설로 인하여 혜택이 있는 자에게 지방자치단체가 부과한다(지방세법 제239조 제1항). 과세표준은 토지, 건축물 및 선박의 시가표준액으로 6단계로 누진세율이 부과되고 주택을 제외한 4층 이상의 건축물에는 2배로 중과세된다.



따라 자치단체장이 기반시설부담구역을 지정한 경우 건축 행위자가 기반시설 설치비용을 부담해야 한다.

부동산 투기나 철거민 문제 이외에 재개발·재건축에서 문제점으로 지적되는 사항은 단지 위주의 재개발로 충분한 기반시설을 확보하지 못한 채 진행되어 사업 종료 후에 학교나 도로 등 공공용지가 미흡하고 주변지역에 부정적 외부효과를 유발한다는 것이다<sup>68)</sup>. 도시공간 개선과 함께 개발밀도 증대에 상응하는 학교, 도로, 녹지 등 기반시설 확보는 쾌적한 주변 환경 조성에 필수 불가결한 요소이다.

이러한 문제점을 해결하기 위한 여러 가지 형태의 개발 부담금이 적용되었지만 정밀하고 설득력 있는 부담금제도의 입안과 적용이 미비하여 지역주민은 기반시설 부담에 대한 인식이 부족한 형편이다. 기본적으로 도시개발 비용을 기반시설과 연계한 기반시설 연동제는 개발계획에서 당연히 준수해야 할 원칙이다. 미국에서도 지역사회 성장에 따른 적절한 공공시설 설치 및 유지를 위하여 개발사업에 대하여 개발 수수료(impact fee)를 적용한다. 즉, 상하수도, 학교, 도서관, 공원 등 주민유입으로 인하여 필요한 기반시설 설치를 위하여 일종의 개발 부담금이 부과된다<sup>69)</sup>.

그러나 전술한대로 주먹구구식 행정으로 각종 부담금이 부과되고 투기 방지를 위한 개발이익 환수 차원에서 개발 부담금이 적용되면서 이러한 부담금에 대한 정당성이 약화되고 이에 따라 부담금에 대한 인식도 부정적인 것이 사실이다. 따라서 자본이득의

68) 한 예로 학교용지부담금이 철폐되기 이전에는 2,500세대 이상을 건설할 경우 초등학교를 건설해야 하는 도시계획시설 의무규정을 피하기 위하여 대규모 개발 사업임에도 불구하고 사업대상지를 분할하여 개발함으로써 부담을 주변지역에 떠넘기는 사례가 발생하였다.

69) HUD(2008), Impact Fees and Housing Affordability : A Guidebook for Practitioners, U.S. Department of Housing and Urban Development([www.huduser.org](http://www.huduser.org))

예납적 성격이 강한 부담금은 폐지하고 그 대신 개발이익은 양도소득세를 통하여 환수하고 각종 부담금을 정리하여 기반시설 정비에 필요한 재원을 확보하는 수단으로 한정해야 한다.

물론 이러한 지적이 재개발·재건축에 따른 투기를 단지 양도소득세를 통하여 제어할 뿐 정부가 어떤 개입의 여지가 없다는 뜻은 아니다. 이는 재개발·재건축 사업의 성패가 정부가 허용하는 용적률과 건폐율 등 개발밀도의 결정에 따라 좌우되기 때문이다. 환원하면 개발밀도에 대한 정부 개입 특히 용적률 완화라는 정부 결정 없이는 부동산 투자가 적정 수익률을 낼 수 없다. 따라서 용적률 완화를 통하여 도시공간이라는 공유자산(‘공간권’)을 정부가 민간에게 이양한다면 정부도 개발이익의 일정 부분을 요구할 수 있는 근거가 된다.

용적률은 도시계획 측면에서 주변지역과의 조화 등 도시공간구조 그리고 도시개발 성격과 적절한 기반시설과 주민편익시설 설치를 고려하여 결정되어야 한다. 즉, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(국토계획법)<sup>70)</sup>에서는 용도구역에 따른 용적률을 정하고 있는데 지방자치단체가 국토계획법이 정한 범위 내에서 관할구역 면적, 인구규모 및 용도지역의 특성 등을 감안하여 실제 용적률을 결정할 수 있다. 한 예로 서울시는 1998년 사업 대상지를 표고, 경사도, 역세권 접근성, 교통상황, 상주인구 등을 기준으로 특별관리, 주거환경 정비, 주거기능 유지, 주택공급 촉진이라는 네 가지 유형으로 구분하여 일반 거주지역을 1~3종으로 세분화하고 이에 상응하는 차별적인 기준 용적률(150~250%)을 적용하고 있다<sup>71)</sup>.

70) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률은 도시지역과 비도시지역으로 나누어 이원적으로 관리하였던 토지이용관리체계가 준농림지역을 중심으로 난개발을 초래하자 1999년 이를 해결하고자 국토이용관리법과 도시계획법을 통합 한 법이다.

71) 1995년 건축법에서는 용도지역을 세분화하여 일반주거지역의 경우 법정 용적률을 200~400%로 완화하였으나 여타 건축규제로 통용되는 용적률

〈표 Ⅱ-1〉 중앙정부와 서울시 기준 용적률 현황

(단위: %)

| 용도지역     |      |     | 국토계획법 <sup>1)</sup> | 서울시 조례 <sup>2)</sup> |
|----------|------|-----|---------------------|----------------------|
| 주거<br>지역 | 전용   | 제1종 | 50~100              | 100                  |
|          |      | 제2종 | 100~150             | 120                  |
|          | 일반   | 제1종 | 100~200             | 150                  |
|          |      | 제2종 | 150~250             | 200                  |
|          |      | 제3종 | 200~300             | 250                  |
| 준 주거지역   |      |     | 200~500             | 400                  |
| 상업<br>지역 | 일반상업 |     | 300~1,300           | 800 <sup>3)</sup>    |
|          | 유통상업 |     | 200~1,100           | 600 <sup>3)</sup>    |
| 공업<br>지역 | 준공업  |     | 200~400             | 400                  |
|          | 일반공업 |     | 200~350             | 200                  |
| 녹지       |      |     | 50~100              | 50                   |

주: 1) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(국토계획법) 시행령 85조: 이러한 범위 내에서 자치단체 조례가 실제 용적률을 정한다. 2) 서울시도시계획조례 제56조(지역안에서의 용적률) 3) 단 4대문안은 각각 600%, 500%가 적용

실제 용적률은 자연환경, 도시경관, 주거환경과 교통여건 등 도시공간구조와 개발여건을 고려하여 결정되는 이러한 기준 용적률에 주거공간의 쾌적성이나 공공시설 공간 확보를 위한 인센티브를 위하여 추가되는 용적률을 감안한 허용 용적률이 있다<sup>72)</sup>. 허용 용적률은 국토계획법에 의한 상한 용적률을 넘을 수 없지만 임대주택 공급 등 기부채납으로 인한 추가 용적률은 예외로 규정된

은 300%가 상한으로 간주되었다. 이후 2000년 도시계획법 개정을 통하여 3종 일반주거지역의 법정 용적률이 최대 250%로 하향 조정되었다.

72) 한 예로 서초구 반포주공 2·3단지, 송파구 잠실주공1~4단지 재건축에서는 270~285%의 용적률이 적용되었는데 서울시는 주거지역의 고층·고밀화로 도시경관 저해나 교통혼잡을 우려하여 국토계획법이 정한 용적률보다 낮은 용적률을 적용하고 있다.

다<sup>73)</sup>. 최근에는 서울시가 60㎡ 이하의 소형주택 공급을 확대하기 위하여 재개발사업에 대하여 기준 용적률을 20%씩 상향 조정하기로 하였다. 또한 상한 적용률도 3종 일반거주지역의 경우 250%에서 300%로 상향 조정된다.

용적률은 1980년대 정부 주도의 공영개발방식으로 공동주택이 대규모로 공급되던 시기에는 최대 200%까지 허용되었다. 그러나 1994년 준도시지역에서 원칙적으로 용적률을 150%(15층)로 하되 주변경관에 해가 되지 않으면 최대 250%(25층) 까지 용적률이 완화되었고 이후 1995년 건축법에서 용도지역 세분화가 이루어지면서 200~400%의 용적률이 허용되었다. 특히 1997년 6월 주택분양가 규제가 철폐되고 그 이후 외환위기에 직면한 정부가 경기부양 대책의 일환으로 재건축시장에 대한 용적률을 상향조정하고 소형주택 건설의무 비율도 완화하면서 재건축이 활성화되어 결국 2000년 이후 주택가격 상승을 주도하는 요인이 되었다. 이후 2000년 도시계획법 개정을 통하여 용적률은 150~250%로 제한받게 된다.

용적률의 시대적 변천을 보면 전반적으로는 주택공급 증대를 위하여 용적률이 완화되는 과정에서도 정부의 경기부양과 투기와 열악제라는 정책목표 사이에서 용적률이 증대 혹은 감축되어 왔음을 알 수 있다. 또한 소형주택 건설, 친환경적 건설 혹은 리모델링 친화적 건설을 이유로 용적률을 상향 조정하기도 하는데 이는 공간권이라는 공유자산을 민간부문에 양보하는 대신 사적 재산을 공적으로 환수하는 형태로 간주될 수 있다. 그러나 현재

---

73) 국토계획법 시행령 85조 5항에 의하면 다음의 구역 안에서 대지 일부를 공공시설부지로 제공하는 경우에는 당해 건축물에 대한 용적률은 해당 용적률의 200% 이하의 범위 안에서 대지면적의 제공비율에 따라 도시계획조례가 정하는 비율로 할 수 있다: 1. 상업지역 2. 아파트지구 3. 도시재개발법에 의한 재개발구역

300%의 용적률이 적용되는 공동주택이 건설되면서 미래에 노후화된 공동주택을 다시 재개발할 때 상황을 염두에 둔 계획이 없다는 우려가 지적되기도 한다.

이에 비하면 선진국의 경우 재건축(reconstruction)이라는 개념이 존재하지 않고 대신 충원 건축(in-fill construction)이라는 개념을 통하여 대부분의 경우 노후화된 건물을 헐고 같은 밀도로 신축하는 대체 행위가 주종을 이룬다<sup>74)</sup>. 다만 건물주가 공익을 위하여 대지 등을 기부 채납할 때 용적률을 제한적으로 상향 조정을 해주며 상업용 재개발 사업을 제외하면 우리나라처럼 300~400% 용적률을 허용하는 경우는 찾아보기 어렵다.

### 3. 소 결

주택은 주거권이라는 헌법상 기본권을 보장하는 역할을 하며 일반 사적재화와는 다른 특수한 기능을 수행한다. 주택은 국민경제의 기초단위인 가구가 소비와 자본을 축적하는 공간이며 지리적 고정성으로 인하여 지역사회에 외부효과를 유발하고 사회적 연대가 이루어지는 매개체가 된다. 대다수 선진국에서 주택 구입에 대하여 각종 정책적 지원을 하는 이유도 단순히 헌법상의 기본권을 떠나 주택소비가 유발하는 긍정적인 효과가 국민경제와 사회복지 향상에 도움이 되기 때문이다.

양질의 주택을 대량으로 공급하는 재개발·재건축은 이러한 측면에서 볼 때 분명히 긍정적인 기능을 수행한다. 나아가 재개발은 토지·공간의 효율적 이용을 제고하며 교통비용과 거래비용 등 각종 비용을 절약하는 방안이 된다. 특히 우리나라 재개발·재건

74) 김재형 편 (2008), 부동산정책의 종합적 검토와 발전방향 모색, 경제·인문사회연구회 협동연구 총서 08-09-01, 한국개발원(KDI)

축 사업은 1970년대 이후 건립된 주택이 노후화되고 있는 상황에서 소득향상으로 점차 증대되고 있는 주거수준 개선욕구에 부응하는 역할을 하였고 특히 개발여력이 부족한 서울을 중심으로 주거공간 창출에 긍정적인 기능을 담당하였다.

주택은 헌법상 기본권에 해당하지만 동시에 공급이 비탄력적인 투자재이기 때문에 국민경제와 사회복지에 심대한 영향을 미치는 재화이기도 하다. 장기적으로는 주택공급이 어느 정도 탄력적이라도 한정적인 토지공급과 지역에 특수한 주변여건(amenities)으로 그 공급이 상당히 제약을 받는다. 그렇지 않다면 다른 공산품과 달리 부동산에 유독 투기가 발생할 이유가 없다.

물론 지방분권화가 잘된 국가의 경우 시간적 공간적으로 공급여유가 많기 때문에 부동산이 지속적으로 문제가 되지 않는다. 그러나 우리나라의 경우 중앙집권적 사회경제체제로 인하여 부동산 투기가 자기실현(self realization)을 하는 경향이 심하여 부동산 불패신화와 함께 부동산에 대한 집중투자를 야기하는 원인이 된다.

그러나, 부동산 투기는 사회적 갈등뿐만 아니라 국가경제에 심대한 영향을 미친다. 즉, 과도한 부동산 가격상승은 일반 국민의 근로욕구와 인적자본 축적을 저해하는 요인이 된다. 장기적으로는 임금과 부동산 가격 사이의 악순환이 물가상승을 통한 국가경쟁력 저하와 산업 공동화를 유발할 수 있다.

그럼에도 불구하고 주택은 사적 재화이므로 시장논리에 따라 재개발·재건축에서 이루어지는 재산권 사용에 대하여 정부 개입을 반대할 수 있다. 그러나 여타 사적 재화와 달리 재개발·재건축은 그 효과가 소비자 본인에게 한정되지 않는다. 이는 주택공급행태가 인구유입과 환경변화를 통하여 주변지역에 긍정적이거나 혹은 부정적인 영향을 주기 때문이다.

이보다 더 본질적으로는 재개발·재건축이 ‘공간권’이라는 공유 자산에 변화를 주기 때문에 정부개입이 불가피하다<sup>75)</sup>. 즉, 재개발·재건축에서 용적률이나 건폐율 변경은 도시공간에 영향을 주기 때문에 정부가 재개발·재건축을 간섭하지 않는다는 사실이 자체가 거꾸로 주택시장에 개입함을 의미할 수 있다. 우리나라에서 재건축 저밀도 공동주택이 투기대상으로 되는 것도 이러한 이유 때문이다. 이와 같은 배경 때문에 선진국에서는 용도제한(zoning) 등 도시계획이나 규제에 대하여 부당한 재산권 침해로 이유로 이의를 제기하지 않는다.

하지만, 우리나라의 경우 이러한 공간권 개념에 대한 충분한 이해가 없이 도시규제가 이루어진다. 그 결과 용적률 상향조정을 통하여 주택건설비용을 조달하는 방식으로 재개발·재건축이 이루어져 개발로 인한 막대한 투자 수익이 보장되었고 이로 말미암아 부동산에 대한 과다투자와 함께 지속 불가능한 개발이 이루어지는 경향을 보인다. 즉, 부동산이 다른 자산과 그 성격이 동일한 자산으로 인식되어 정당한 부동산 투자이익을 정부가 부당하게 환수한다는 인상이 팽배되어 있다.

두 번째로 우리나라에서는 물리적 개발만 있고 사회경제 공동체이라는 개념이 존재하지 않는다. 재개발·재건축이 기존 공동체와 주변에 형성된 사회경제체제를 해체함으로써 세입자 등 지역 주민에게 피해를 유발할 수 있다는 사실이 인정되지 않는다. 나아가 난개발로 인하여 지역주민은 물론 주변지역 주민과의 갈등이 발생하기도 한다. 이는 영업권 등 무형재산에 대한 국내 인식이 미약하기 때문이기도 하지만 보다 본질적으로 지방자치가 일천한 우리의 역사적 경험에서도 기인한다.

세 번째로 재개발·재건축을 포함한 부동산이 계속 문제가 되

75) 이와 유사한 공유재산에는 항공 영역이나 방송 주파수가 있을 수 있다.

는 이유는 결국 정부가 제대로 역할을 하지 못하고 있음을 의미한다. 즉, 여러 단점에도 불구하고 공영개발방식으로 주택이 공급되었을 때 문제의 소지가 적었던 사실을 상기할 필요가 있다. 이에 비하면 1990년대 이후 민간개발이 주도를 이루면서 정부가 도시성장에 대한 기본적인 철학과 체계적인 계획 없이 상황에 따라 상반된 정책을 혼용해왔던 경험은 결국 부동산 투자를 통한 기대이익을 부풀리는 결과를 낳았고 부동산 불패신화가 정착되는 요인이 되었다.

2000년 이후에는 토지나 주택 정비에 관한 법률이 통합하여 주택을 합리적으로 공급하고 도시공간을 체계적으로 사용하려는 노력이 진행되고 있다. 그러나 아직도 재개발·재건축으로 발생하는 문제를 정확히 인식하고 제대로 처방하는 데는 부족한 측면이 있다. 이는 물론 건설업체를 비롯한 주택 보유자 등 기득계층의 영향력이 막대하기 때문이기도 하다. 그 결과 대부분의 사업은 선계획 후개발원칙에 의한 주거환경 개선사업이 아니라 성냥갑적인 획일화를 통한 개발사업으로 전락한 경향이 많다.

우리나라에서 수도권을 중심으로 한 중앙집권적 체제가 유지되는 한 재개발·재건축을 포함한 부동산 문제는 지속될 가능성이 높다. 따라서 이들 사업이 갖는 문제를 명확히 인식하고 개별 사항에 대한 해결방안을 고민할 필요가 있다. 특히 세제 개선의 경우 장기적인 관점에서 지방재정제도와 함께 각종 부담금, 소형 혹은 임대주택 공급의무 등 관련 규제와 함께 검토하여 제도를 개선할 필요가 있다.

## 제2절 주택 재개발·재건축 관련 조세제도의 현황

재개발 및 재건축 관련 조세제도는 크게 양도소득세와 법인



세·부가가치세 및 지방세로 구분할 수 있는데, 지방세인 취득세와 재산세에 관한 내용은 뒤의 취득세와 재산세 과세의 문제점과 개선방안에서 살펴보도록 하고, 이하에서는 이 중에서 양도소득세와 법인세 및 부가가치세의 내용을 중심으로 하여 현행 조세제도의 현황을 살펴보려고 한다.

## 1. 양도소득세

### 가. 주택재개발·재건축 조합에 대한 현물출자

#### (1) 양도의 개념

소득세법상 “양도”란 자산에 대한 등기 또는 등록과 관계없이 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등으로 인하여 그 자산이 유상<sup>76)</sup>으로 사실상 이전되는 것을 말한다<sup>77)</sup>. 또한 부담부 증여에 있어서 증여자의 채무를 수증자가 인수하는 경우에는 양도로 본다. 그러나 「도시개발법」이나 그 밖의 법률에 따른 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되거나 체비지로 충당되는 경우에는 양도에 해당하지 않는다<sup>78)</sup>.

#### (2) 현물출자와 양도

##### 1) 현물출자의 개념

현물출자란 사업의 목적을 달성하지 위하여 금전이 아닌 양도

76) 이는 양도자에게 경제적 이익이 발생함을 의미하는 것으로 그 대가가 현금이나 현물로 지급된 것을 구분하지 않는다.

77) 소득세법 제88조 1항.

78) 소득세법 제88조 2항.

가능한 자산을 법인, 자기사업체 또는 공동사업체에 제공하는 것을 말한다. 이는 금전출자와 같이 사실상 유상이전에 해당되므로 소득세법상 양도소득세 과세대상이 된다.

## 2) 주택재개발·재건축 조합에 대한 현물출자

조합(partnership)은 구성원의 집합체로써 구성원 모두가 그 권리주체가 된다. 그래서 조합은 법인제도로 규율하지 않고 계약관계로 보아 민법상 채권편에서 규율하고 있다. 그러나 명칭에 ‘조합’이 들어가 있다고 하여 공동사업자의 형태인 조합으로 단정할 수 없다. 예를들어 주택재개발·재건축 조합은 「도시및주거환경정비법」 제18조에 의하여 ‘정비사업조합’이란 명칭을 포함하면서 법인으로 설립하도록 하고 있다.<sup>79)</sup> 또한 조세특례제한법 제104조의7 제2항에서 “2010년 12월 31일 이전에 끝나는 사업연도까지는 비영리내국법인으로 보아 「법인세법」을 적용한다”라고 하여 비영리내국법인으로 과세한다. 그런데 한시적인 규정으로 되어 있고, 당초 2008년 12월 31일 이전에 종료하는 사업연도까지 비영리내국법인으로 법인세법을 적용하도록 하였다가 다시 일몰기간을 연장하여 2010년 12월 31일 이전에 끝나는 사업연도로 개정된 것으로 일몰기간이 끝나게 되면 예전의 논란<sup>80)</sup>과 같이 영리내국법인으로 볼 것인지 비영리내국법인으로 볼 것인지가 다시 문제될 수 있다.

여하튼 주택재개발·재건축 조합의 조합원은 자신의 기존 부동산을 현물출자 형식으로 출자하게 되는데, 법인에 대한 현물출자는 양도에 해당되어 양도소득세 과세대상이 된다.

79) 본고는 주택재개발·재건축 조합에 대한 조세제도를 검토하는 것이므로 법인으로써 접근하고자 한다.

80) 대법원2005.7.15.선고 2003두5754판결 등에 의하여 주택재건축·재개발 조합을 국세기본법 제13조의 법인으로 보는 단체로 구분하게 되었지만, 그 이전에는 소득세법상 1거주자 혹은 부가가치세법상 공동사업자로 보아 과세되기도 하였다.

## 나. 조합원입주권의 소유에 따른 1세대 1주택 비과세 특례

### (1) 적용 원칙

조합원입주권을 1개 소유한 1세대[「도시 및 주거환경정비법」 제48조에 따른 관리처분계획의 인가일(인가일 전에 기존주택이 철거되는 때에는 기존주택의 철거일) 현재 1세대 1주택 비과세 요건을 충족하는 기존주택을 소유하는 세대에 한한다]가 당해 조합원입주권을 양도하는 경우 ① 양도일 현재 다른 주택이 없거나 ② 양도일 현재 1조합원입주권 외에 1주택을 소유한 경우에는 1세대1주택 비과세를 적용한다<sup>81)</sup>. 다만, 양도일 현재 1조합원입주권 외에 1주택을 소유한 경우에는 그 1주택을 취득한 날부터 2년 이내<sup>82)</sup>에 당해 조합원입주권을 양도하는 경우에 한하여 1세대1주택 비과세를 적용한다.

그러나 조합원입주권과 다른 주택을 각각 1개씩 보유하다 다른 주택을 양도한 경우 비록 양도된 다른 주택이 1세대 1주택 비과세 요건을 충족하더라도 비과세를 배제한다. 이는 조합원입주권이 2005. 12. 31. 이전에는 주택으로 보지 않아 비과세하였는데, 이러한 비과세는 조합원입주권을 활용한 부동산 투자를 억제하는 한편, 1세대 1주택의 기본 목적인 국민주거생활안정에 기여하기 위함이다.

### (2) 비과세 특례 내용

1주택과 1조합원입주권의 경우 일정요건이 충족된 경우에만 비

81) 소득세법 시행령 제155조 제17항.

82) 2008. 11. 27. 이전 양도의 경우에는 1년 이내이다.

과세하고, 나머지 경우에는 모두 과세<sup>83)</sup>한다. 2006. 1. 1. 이후 원칙적으로 1세대가 A와 B주택을 보유하다가 A주택을 멸실하여 조합원입주권을 가지고, 나머지 B주택을 양도한 경우(보유거주요건 모두 충족) 그 양도차익에 대하여 과세한다는 것이다. 다만, 다른 1세대 1주택 비과세요건을 충족한 상태에서 ① 1주택을 양도하기 전에 1조합원입주권을 취득하고 2년 이내 종전 1주택을 양도하거나 ② 1주택을 양도하기 전에 1조합원입주권을 취득하고 2년을 경과하여 종전 1주택을 양도한 경우 다음 3가지 조건(1조합원입주권에 해당하는 주택이 완성된 후 2년 이내에 세대전원이 이사하고, 이사 후 세대전원이 1년 이상 거주하고, 또한 그 주택이 완성되기 전이나 된 후<sup>84)</sup> 2년 이내 종전 1주택을 양도하여야만 한다)을 모두 충족하여야 한다. 또한 ③ 주택재개발·재건축사업 시행기간 중 거주를 위하여 취득한 대체취득 1주택과 1조합원입주권의 경우 먼저 기존의 1주택은 멸실되어 1조합원입주권이 되고, 건축기간(사업시행인가일부터 완공일까지) 거주하기 위하여 1주택을 대체취득하고 3가지 요건(건축기간중에 대체 1주택을 취득하고 1년 이상 거주하고, 조합원입주권에 해당하는 주택이 완성된 후 2년 이내에 세대전원이 그 주택에 이사한 후 1년 이상 거주하고, 또한 그 주택이 완성되기 전이나 된 후<sup>85)</sup> 2년 이내 대체취득 1주택을 양도하여야만 한다)을 모두 충족하여야 한다. 나머지의 경우는 설명을 생략한다.<sup>86)</sup>

83) 1주택 2조합원입주권 이상, 2주택 1조합원입주권, 2주택이상 또는 2조합원입주권 이상의 경우

84) 완성일은 사용승인일 또는 사용검사일이나, 임시사용승인을 받은 경우에는 사실상 사용일이나 임시사용승인일 중 빠른날이 된다.

85) 완성일은 사용승인일 또는 사용검사일이나, 임시사용승인을 받은 경우에는 사실상 사용일이나 임시사용승인일 중 빠른날이 된다.

86) 상속, 동거분양 합가, 혼인 합가, 문화재주택, 이농주택, 귀농주택의 경우 등은 우선 1세대 1주택 비과세 특례의 기본 방식을 적용하여 앞에서 설명한 ①, ②, ③의 경우로 만든 다음 판단할 수 있기 때문이다.

(3) 1세대 2주택 이상 또는 2조합원입주권 이상에 대한 중과세

2009. 3. 15.까지 양도된 경우<sup>87)</sup>에는 주택과 조합원입주권의 합이 2개 이상일 경우에는 단일세율 50%를, 3개 이상일 경우 단일세율 60%가 적용될 뿐만 아니라 장기보유특별공제가 배제되었다. 그러나 2009. 5. 21. 법률 제9627호 일부개정예 의하여 2010. 12. 31.까지 양도될 경우 일반세율이 적용되고, 다만 장기보유특별공제만 배제된다.

다. 조합원입주권의 양도에 대한 양도차익 계산특례<sup>88)</sup>

주택 재개발·재건축 조합의 조합원이 당해 조합에 기존건물과 그 부수토지를 제공(건물 또는 토지만을 제공한 경우를 포함한다)하고 취득한 입주자로 선정된 지위를 양도하는 경우 그 조합원의 양도차익은 조합원입주권프리미엄과 부동산의 양도차익으로 각각 구분계산한다. 이 경우 조합원이 청산금을 납부한 경우와 청산금을 지급한 경우로 나누어 계산한다. 즉, 조합원입주권 취득일부터 조합원입주권 양도일까지의 양도차익(이하 ‘관리처분계획인가<sup>89)</sup> 후 양도차익’이라 한다)과 종전 부동산 취득일부터 입주권취득일 전일까지의 양도차익(이하 ‘관리처분계획인가 전 양도차익’이라 한다)의 합계액이 된다.

(1) 청산금을 납부한 경우

87) 법률 제9627호(2009.5.21) 부칙 제2항.

88) 소득세법 시행령 제166조 1항.

89) 2005. 5. 31. 전의 경우 재개발은 “관리처분계획인가일”, 재건축은 “사업시행인가일”로 용어를 구분하였으나 2005. 5. 31. 이후부터는 “관리처분계획인가일”로 통일되었다.

64 2. 주택 재개발·재건축 관련 조세제도의 현황

i) 양도가액

- 기존건물과 그 부수토지의 평가액
- 납부한 청산금
- 필요경비

= 관리처분계획인가 후 양도차익 ..... ①

ii) 기존건물과 그 부수토지의 평가액

- 기존건물과 그 부수토지의 취득가액 또는 환산가액
- 필요경비

= 관리처분계획인가 전 양도차익 ..... ②

iii) 양도차익 = ① + ②

(2) 청산금을 지급받은 경우

i) 양도가액

- 기존건물과 그 부수토지의 평가액
- + 지급받은 청산금
- 필요경비

= 관리처분계획인가 후 양도차익 ..... ①

ii) {기존건물과 그 부수토지의 평가액

- 기존건물과 그 부수토지의 취득가액 또는 환산가액
- 필요경비} ×

{(기존건물과 그 부수토지의 평가액 - 지급받은 청산금)

÷ (기존건물과 그 부수토지의 평가액)}

= 관리처분계획인가 전 양도차익 ..... ②

iii) 양도차익 = ① + ②

(3) 기존건물과 그 부수토지의 평가액<sup>90)</sup>

‘기존건물과 그 부수토지의 평가액’은 관리처분계획에 따라 정하여진 가격을 말한다. 그러나 그 가격을 알 수 없을 경우에는 관리처분계획인가일 전후 각 3개월이내의 매매사례가, 감정평균가, 기준시가의 방법을 순차로 적용한다.

(4) 기존건물과 그 부수토지의 취득가액<sup>91)</sup>

‘기존건물과 그 부수토지의 취득가액’을 알 수 없을 경우 환산가액에 의하는데 그 계산방법은 아래와 같다.

$$\begin{array}{l} \text{기} \\ \text{존} \\ \text{건} \\ \text{물} \\ \text{과} \\ \text{그} \\ \text{부} \\ \text{수} \\ \text{토} \\ \text{지} \\ \text{의} \\ \text{취} \\ \text{득} \\ \text{가} \\ \text{액} \end{array} = \begin{array}{l} \text{기} \\ \text{존} \\ \text{건} \\ \text{물} \\ \text{과} \\ \text{그} \\ \text{부} \\ \text{수} \\ \text{토} \\ \text{지} \\ \text{의} \\ \text{평} \\ \text{가} \\ \text{액} \end{array} \times \frac{\text{취득일 현재 기존건물과 그 부수토지의 기준시가}}{\text{관리처분계획인가일 현재 기존건물과 그 부수토지의 기준시가}}$$

90) 소득세법 시행령 제166조 4항.

91) 소득세법 시행령 제166조 3항.

### 라. 신축주택의 양도에 대한 양도차익 계산특례<sup>92)</sup>

주택 재개발·재건축 조합의 조합원이 해당 조합에 기존건물과 그 부수토지를 제공하고 관리처분계획에 따라 취득한 신축주택 및 그 부수토지를 양도하는 경우 실지거래가액에 의한 양도차익은 2007. 1. 1. 이후 양도분<sup>93)</sup>부터 실지거래가액으로 계산한다. 다만, 계산방법은 조합원입주권의 양도에서 계산한 관리처분계획인가 후 양도차익과 관리처분계획인가 전 양도차익을 사용하여야 한다. 구체적이 계산식은 다음과 같다.

#### (1) 청산금을 납부한 경우

$$\begin{aligned}
 & \text{i) } \{ \text{관리처분계획인가 후 양도차익} \\
 & \quad \times \text{ 납부한 청산금} \\
 & \quad \div (\text{기존건물과 그 부수토지의 평가액} + \text{납부한 청산금}) \} \\
 & = \text{청산금납부분 양도차익} \dots\dots \text{①} \\
 & \text{ii) } \{ \text{관리처분계획인가 후 양도차익} \\
 & \quad \times \text{ 기존건물과 그 부수토지의 평가액} \\
 & \quad \div (\text{기존건물과 그 부수토지의 평가액} + \text{납부한 청산금}) \} \\
 & \quad + \text{관리처분계획 인가 전 양도차익} \\
 & = \text{기존건물분 양도차익} \dots\dots \text{②} \\
 & \text{iii) 양도차익} = \text{①} + \text{②}
 \end{aligned}$$

#### (2) 청산금을 지급받은 경우<sup>94)</sup>

92) 소득세법 시행령 제166조 2항.

93) 2006. 12. 31. 이전 양도분은 기준시가에 의하여 양도차익을 계산하였다.

94) 청산금을 지급받은 경우의 조합원입주권 양도차익 계산방식과 동일하다.



i) 양도가액

- 기존건물과 그 부수토지의 평가액
- + 지급받은 청산금
- 필요경비
- = 관리처분계획인가 후 양도차익 …… ①

ii) {기존건물과 그 부수토지의 평가액

- 기존건물과 그 부수토지의 취득가액 또는 환산가액
- 필요경비}

$$\times \{(\text{기존건물과 그 부수토지의 평가액} - \text{지급받은 청산금}) \\ \div (\text{기존건물과 그 부수토지의 평가액})\}$$

= 관리처분계획인가 전 양도차익 …… ②

iii) 양도차익 = ① + ②

(3) 기준시가에 의한 양도차익 계산방법<sup>95)</sup>

i) 관리처분계획인가일 전일 현재의 기존건물과 그 부수토지의 기준시가<sup>96)</sup>

- 기존건물과 그 부수토지의 취득일 현재의 기존건물과 그 부수토지의 기준시가
- 기존건물과 그 부수토지의 필요경비
- = 기존건물과 그 부수토지의 취득일부터 관리처분계획인가일 전일까지의 양도차익
- … ①(차손일 경우 “0”)

ii) 신축건물의 준공일 전일 현재의 기존건물의 부수토지의 기준시가

- 관리처분계획인가일 현재의 기존건물의 부수토지의 기준시가
- = 관리처분계획인가일부터 신축건물의 준공일 전일까지의 양도차익
- … ②(차손일 경우 “0”)

iii) 신축건물의 양도일 현재의 신축건물과 그 부수토지의 기준시가

- 신축건물의 준공일 현재의 신축건물과 그 부수토지의 기준시가
- 신축건물과 그 부수토지의 필요경비
- = 신축건물의 준공일부터 신축건물의 양도일까지의 양도차익
- … ③(차손일 경우 “0”)

iv) 양도차익 = ① + ② + ③

(청산금을 수령한 경우 청산금에 상당하는 양도차익을 차감)<sup>97)</sup>

95) 소득세법 시행령 제166조 7항.

### 마. 장기보유특별공제

#### (1) 조합원입주권 양도의 경우

‘관리처분계획인가 후 양도차익’은 부동산을 취득할 수 있는 권리에 해당되는 부분을 계산한 것으로 장기보유특별공제대상이 되지 않으나, ‘관리처분계획인가 전 양도차익’은 기존부동산에 대한 양도차익을 산정한 것이므로 기존 부동산의 보유연수에 해당하는율을 적용하여 공제한다.

#### (2) 신축주택 양도의 경우

위 ‘라. (3) i), ii)’ 양도차익의 합계액에 대하여는 기존 부동산에 해당되는 부분이므로 기존 부동산취득일부터 양도일까지의 보유기간에 따른 공제율을 적용하고, 위 ‘라. (3) iii)’ 양도차익은 신축주택에 대한 것이므로 신축주택이 일반건물에 해당하거나 공동주택기준시가 최초고시 전에 양도한 경우와 공동주택으로 공동주택기준시가 최초고시후에 양도한 경우로 나누어 계산한다.

① 신축주택이 일반건물에 해당하거나 공동주택기준시가 최초고시 전에 양도한 경우

96) 기준시가가 관리처분계획인가일까지 고시되지 않은 경우, 「기존건물과 그 부수토지의 취득일 현재의 기존건물과 그 부수토지의 기준시가 + (기존건물과 그 부수토지의 취득일 현재의 기존건물과 그 부수토지의 기준시가 - 그 전기의 기준시가) × (취득일부터 관리처분계획인가일 전일까지의 보유월수 ÷ 기준시가 조정월수)」로 계산한다.

97) 종전 부동산에 대한 기준시가 양도차익 × 청산금 수령액 ÷ 종전 부동산의 평가액

$$\begin{aligned} \text{장기보유특별공제} &= \text{'라. (3) iii)' 양도차익} \\ &\times \text{기존부동산취득일부터 양도일까지} \\ &\text{보유공제율} \end{aligned}$$

② 공동주택으로 공동주택기준시가 최고고시 후에 양도한 경우

$$\begin{aligned} &\text{ㄱ) '라. (3) iii)' 양도차익} \times (\text{불입청산금} \div \text{분양가액}) \times \\ &\text{준공일부터 양도일까지 보유공제율} \\ &\text{ㄴ) \{ '라. (3) iii)' 양도차익} \times (\text{분양가액} - \text{불입청산금}) \div \text{분} \\ &\text{양가액} \} \times \text{기존부동산취득일부터 양도일까지 보유공제율} \\ \text{장기보유특별공제} &= \text{ㄱ) + ㄴ)} \end{aligned}$$

#### 바. 재건축 부담금의 공제

양도소득의 계산에 있어서 재건축 부담금은 필요경비로 공제된다<sup>98)</sup>.

## 2. 법인세

앞서 주택 재개발·재건축 조합을 법인으로 설명하였다. 또한 조세특례제한법 제104조의7 제2항의하여 2010년 12월 31일 이전에 종료하는 사업연도까지 비영리내국법인으로 법인세법을 적용받도록 하고 있다.

비영리내국법인은 원칙적으로 법인세법상 납세의무가 없다고

98) 소득세법 시행령 제163조 3항 4호 및 같은법 시행규칙 제79조 1항 6호.

할 수 있다. 이는 영리목적없이 고유목적사업을 영위하는 것이고, 일부 소득이 발생하더라도 공익목적의 고유목적사업에 사용하기 때문에 납세의무를 지우지 않는 것으로 생각할 수 있다. 그러나 영리법인과는 과세형평성이나 공정한 경쟁관계, 또는 비영리법인으로 위장하여 탈세를 자행할 우려가 있기 때문에 영리사업에 국한하여 발생하는 소득에 대하여 법인세를 과세하고 있다.

### 가. 조합법인 등에 대한 당기순이익 과세

조세특례제한법 제72조에서 조합법인은 결산서상 당기순이익에 기부금과 접대비 한도초과액을 가산한 금액을 과세표준으로 하여 9%세율을 적용하여 과세하는 당기순이익 과세제도를 두고 있다.

주택 재개발·재건축 조합은 명칭상 조합을 사용하고 있으나 조세특례제한법 제72조 1항에 열거한 조합에 해당되지 않아 조합법인에 대한 과세특례를 적용받을 수 없다. 즉, 주택 재개발·재건축 조합의 수익사업에 대한 수익과 수익사업에 직접 관련하여 생긴 부수수익에 대하여만 과세가 된다.

### 나. 수익사업

비영리법인은 열거된 수익사업에 대하여만 법인세 납세의무를 진다.<sup>99)</sup> 현재 법인세법에 열거된 수익사업은 사업소득, 소득세법상 이자소득, 소득세법상 배당소득, 주식 등 양도차익, 고정자산 처분 수익, 채권 등 매매차익이다. 비영리법인이 수익사업을 영위하게 되면 자산, 부채, 그리고 손익을 수익사업과 비수익사업으로 구분하여 정리하여야 한다.<sup>100)</sup>

99) 법인세법 제3조 제2항.

주택 재개발·재건축 조합의 경우, 일반분양에 의한 수익이 사업소득을 구성하므로 이에 대한 법인세 납세의무가 있다. 그러나 사업소득은 계속·반복적으로 영리 목적이 수반되어야 하므로 일시적·우발적 수익은 사업소득을 형성하지 않는다. 예를 들어 주택 재개발·재건축 조합이 일반분양 없이 조합원에게만 아파트를 분양한 경우라면 그 조합원이 주택건축비의 전부를 부담한 것으로 사업소득을 형성하지 않을 것이다. 그런데 일반분양이 있다면, 조합원들은 일반분양수익 상당액 만큼 건축비의 추가부담이 줄어들게 되는데, 이는 조합의 수익사업으로 보아 법인세를 과세하여야 할 것이다. 이때 조합내 유보된 금액이 없는 결과가 형성되었다 하더라도 조합원이 덜 부담하게 된 금액만큼 배당이 된 것으로 보아야 하므로 일단 조합의 수익을 구성한 후 사외유출된 것으로 간주하여야 한다.

### 3. 부가가치세

주택재개발조합이 조합원들에게 주택을 분양하는 경우에는 부가가치세의 과세대상이 아니며, 조합원 이외의 자에게 주택을 분양하는 경우에는 부가가치세의 과세대상이 된다. 한편, 조합원 이외의 자인 경우에도 당해 주택이 국민주택규모 이하인 경우에는 부가가치세를 면세한다.<sup>101)</sup>

100) 법인세법 제113조 제1항.

101) 부가가치세법 제12조 1항 12호, 조세특례제한법 제106조 1항 4호 및 제104조의7 3항

## 제4장 정비사업조합의 법적 성격

### 제1절 문제의 제기

도시및주거환경정비법이 시행되기 전에는 재건축조합의 법인성에 대하여 해석상 다툼이 있었다. 즉, 주택조합이라 함은 동일 또는 인접한 시(특별시 및 광역시를 포함한다)·군에 거주하는 주택이 없는 주민이 주택을 마련하기 위하여 설립한 조합(지역조합), 동일한 직장에 근무하는 주택이 없는 근로자가 주택을 마련하기 위하여 설립한 조합(직장조합) 및 대통령령이 정하는 노후·불량한 주택을 철거하고 그 철거한 대지 위에 주택을 건설하기 위하여 기존주택의 소유자가 설립한 주택(재건축조합)을 말하였다.

한편, 이러한 조합의 법적 성격에 대하여는 조합으로 보는 견해와 비법인사단으로 보는 견해로 나뉘었는데, 학설은 대체로 주택조합을 비법인사단으로 보았다. 즉, 주택건설촉진법이 주택조합의 설립절차에 있어서 관할 시장 또는 군수의 인가를 받도록 규정하고 있는 점과 주택조합과 그 구성원의 결합형태가 같은 도시개발법상의 재개발조합의 성격을 법인으로 규정하고 있는 점 등을 종합하여 볼 때, 주택조합을 사단법인 또는 법인격 없는 사단으로 해석하는 것이 타당하다는 견해<sup>102)</sup> 등에 비추어 보아 대체로 비사단법인으로 보았다.

판례는 주택조합을 민법상 조합으로 보는 것<sup>103)</sup>과 법인격 없는

102) 강인애, 「조세법 VII」, 조세통람사, 1994, p.96; 김홍균, “지방세법상 취득세에 관한 연구 - 취득의 의의를 중심으로 -”, 영남대학교 대학원, 1998.12, p.41; 임재근, 「부동산세법론」, 법률서원, 2005, pp.120-121; 최원, “취득세에 있어서의 취득개념에 관한 연구”, 경희대학교 대학원, 2000.8, p.118.

103) 대법원 1989.10.10선고, 89나19844판결.

<관결요지> 주택건설촉진법 제44조 제1항에 근거하여 설립된 주택조합은 그 조합원들의 주택을 건설하는 사업을 공동으로 시행할 것을 목적으로 한 이른바 동

사단으로 보는 것<sup>104)</sup>으로 2가지로 나누어져 있었다.

그러나, 현행 도시및주거환경정비법 제18조에서는 주택재개발조합과 재건축조합을 정비사업조합이라는 명칭으로 통합하여 법인으로 규정하고 있다. 따라서 현행법상으로는 정비사업조합은 법인이 되며, 조합설립인가를 받은 후에 설립등기를 함으로써 성립하는 것이다. 즉, 도시및주거환경정비법상 재건축조합은 그 명칭 중에서 정비사업조합이라는 문자를 사용하여야 하고, 사업비용의 부과 및 연체료를 강제로 징수할 수 있을 뿐만 아니라, 자료의 제출, 임원의 개선 등 행정청에 의한 감독을 받으며, 조합의 임·직원은 형법 뇌물죄의 적용상 공무원의 취급을 받는 등 도시및주거환경정비법의 규정 내용에 비추어 볼 때 공법상 법인이라고 보아야 할 것이다<sup>105)</sup>.

이와 같이 현행법은 정비사업조합을 법인으로 보도록 하고 있는데, 그 실질에 있어서는 여전히 조합으로서의 성격을 지니고 있

---

업관계의 성질을 가진 것으로서 각 구성원의 개성이 뚜렷하게 집합체의 운영에 반영되어 있음에 비추어 민법상 조합의 실체를 갖춘 것으로 볼 것이므로 그 이름으로 소송상 당사자가 될 수 없다.

104) 대법원 1993.4.27선고, 92누8163판결.

<판결요지> 가. 종합토지세가 수익세로서의 성격을 가진다 하더라도 연혁적으로 토지분재산세에서 출발하였다는 점과 현행법상 토지의 가액 즉 과세시가 표준액을 과세표준으로 한다는 점(지방세법 제234의15 제2항)에 비추어 기본적으로 재산세이다.

나. 위탁자가 수탁자에게 토지의 소유권을 이전하여 당사자 사이에 신탁법상의 신탁관계가 설정되면 단순한 명의신탁과는 달리 신탁재산은 수탁자에게 귀속되고 이로써 수탁자는 신탁의 목적에 따라 신탁재산을 관리 처분할 수 있는 권능을 가지게 되므로 신탁재산에 대한 종합토지세의 부과는 신탁재산을 보유하는 수탁자를 상대로 하여야 한다.

다. "구의동연합직장주택조합"은 구의동 지역에서 조합아파트의 건축을 추진하고 있던 15개의 직장주택조합들이 설립한 연합체로서 공동주택 건설사업이라는 단체 고유의 목적을 가지고 활동하고 있으며, 규약 및 단체로서의 조직을 갖추고 구성원의 가입 탈퇴에 따른 변경에 관계없이 단체 자체가 존속하는 등 단체로서의 주요사항이 확정되어 있어 비법인사단에 해당한다.

105) 김명섭, "주택재건축 관련 취득세 논의", 「사법논집」 제42집, 법원도서관, 2006.12, p.242.

## 74 2. 정비사업조합의 법적 성격

으며, 정비사업조합이 법인이라고 할 경우 당해 법인이 영리법인지 또는 비영리법인지의 여부가 문제가 된다. 이하에서는 이에 대하여 살펴보기로 한다.

### 제2절 정비사업조합의 법적 성격

정비사업조합(Maintenance Business Union)은 조합으로서의 성격과 법인으로서의 성격을 동시에 지니고 있기 때문에 재건축과 관련된 조세제도를 복잡하게 하고 있다. 즉, 정비사업조합은 도시및주거환경정비법상 규정에 의하여 법인으로 하고 있지만, 실질적으로는 조합으로서의 성격이 강하다고 할 것이다.

따라서 이하에서는 정비사업조합의 조합으로서의 성격과 도시및주거환경정비법상 법인으로 보도록 하고 있는데, 이 경우 이러한 법인이 영리법인지 또는 비영리법인지의 여부에 대하여 살펴보기로 한다.

#### 1. 조합으로서의 성격

정비사업조합은 특정한 지역 내에 노후·불량건축물을 소유하고 있는 토지 소유자 등이 토지 등을 출자하여 주택재개발사업 또는 재건축사업을 시행하기 위해서 결합된 단체로서 그 본질은 조합에 가깝다고 하겠다. 그런데, 도시및주거환경정비법은 정비사업조합에 대한 감독을 강화하여 주택재개발 또는 재건축사업을 보다 체계적·효율적으로 수행하기 위하여 정비사업조합에 법인격을 부여하고 있다. 즉, 정비사업조합은 법인으로 하며, 조합설립의 인가를 받은 날부터 30일 이내에 주된 사무소의 소재지에 등기하도록 하고 있는 것이다.



그러나, 정비사업조합이 법인에 해당한다고 하더라도 그 조합적인 성격을 부인하거나 간과하기 어려운 경우가 적지 않다. 즉, 정비사업조합의 경우 정비사업의 시행을 목적으로 법인 형태로 설립되며, 공법상의 여러 가지 규율을 받지만, 조합원의 주택공급이 가장 중요한 점을 고려할 때 민법상 조합의 성격이 강하다고 할 것이다. 이러한 점 때문에 정비사업조합의 납세의무에 관하여는 통상의 법인에 대한 납세의무와는 달리 세법상 여러 가지 특례를 인정하고 있는 것이다<sup>106)</sup>.

## 2. 정비사업조합이 영리법인인지의 여부

현행법에서 있어서는 정비사업조합을 법인으로 보도록 하고 있는데, 소득세나 법인세 또는 부가가치세 등의 과세에 있어서 이러한 정비사업조합이 영리법인지 또는 비영리법인지에 따라서 과세상 차이가 발생하게 된다. 즉, 법인세의 과세에 있어서 당해 조합이 영리법인지 또는 비영리법인지에 따라서 과세상 차이가 발생한다. 먼저, 영리법인의 경우에는 순자산증가설의 입장에서 익금에서 손금을 차감한 전체의 소득에 대하여 법인세를 과세하고, 청산소득에 대한 법인세 납세의무도 부담한다. 이에 반하여, 비영리법인의 경우에는 수익사업에 한정하여 법인세를 과세하고, 청산소득에 대한 법인세도 과세하지 아니한다. 또한 비영리법인의 경우에는 고유목적사업준비금의 손금산입 등 영리법인과는 달리 여러 가지 특례를 인정하고 있다.

부연하면, 정비사업조합이 영리법인지 또는 비영리법인지에 따라서 법인세법과 부가가치세법상 과세상 차이가 많이 발생하게

106) 김완석, “재건축에 대한 조세법적 검토”, 「토지공법연구」 제33집, 한국토지공법학회, 2006.11, pp.45-46.

되는 것이다.

따라서 이하에서는 정비사업조합이 영리법인에 해당하는지 또는 비영리법인에 해당하는지의 여부에 대하여 학설과 판례 및 과세관청의 입장을 살펴본 후에 영리법인에 해당하는지 또는 비영리법인에 해당하는지의 여부에 대하여 결론을 맺고자 한다.

### 가. 학설

#### (1) 영리법인이라는 견해

정비사업조합은 영리법인이라는 주장으로서, 그 근거는 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 주택재개발조합의 경우 사업에서 발생하는 이익은 조합원들에게 지분대로 귀속되고 조합원들이 내어야 할 분양대금에서 이러한 이익을 조정받게 되기 때문에 주택재개발조합이 조합원에게 이익을 배당할 수 있다고 한다. 이러한 경우에는 바로 비영리법인에서 제외되는 것이 아니고 법인세법 시행령 제1조에서 정하는 조합법인 등에 해당하는 경우에 한하여 이익을 배당할 수 있다고 하더라도 비영리법인으로 보게 되는데, 주택재개발조합은 이에 열거되어 있지 않기 때문에 법인세법상 영리법인으로 과세되어야 한다고 한다<sup>107)</sup>.

둘째, 정비사업조합이 영리활동에 의하여 얻은 이익을 그 조합원에게 분배하는지 또는 법인이 해산할 때에 잔여재산을 그 조합원에게 분배하는지의 여부가 결정적인 기준이 된다고 한다. 어떤 법인이든 영리활동에 의하여 얻은 이익을 그 구성원에게 분배 또

107) 박훈, “재개발조합의 과세문제”, 「조세와 법」 제1권 제2호, 서울시립대학교 법학연구소·지방세연구소, 2008.12, pp.225-226.

는 배당한다거나 법인이 해산하면서 잔여재산을 그 구성원에게 분배한다면 그 법인을 영리법인으로 보아야 하는데, 정비사업조합이 영리활동에 의하여 얻은 이익은 궁극적으로는 그 조합원에게 배분되기 때문에 정비사업조합은 영리법인에 해당한다고 한다<sup>108)</sup>.

## (2) 비영리법인이라는 견해

정비사업조합은 비영리법인이라는 주장으로서, 그 근거는 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 정비사업조합은 비영리적인 성격과 영리적인 성격을 모두 가지고 있지만, 전체적으로 보면 비영리법인으로서의 성격이 강하게 나타나는 조합원에 대한 분양이 주된 것이고, 영리법인의 성격을 가지는 일반에 대한 분양은 부수적인 것이므로 비영리법인으로 보는 것이 타당하다고 한다<sup>109)</sup>.

둘째, 재건축조합은 조합원에게 지분권도 인정되지 않고 정관에 이익분배에 관한 규정도 없기 때문에 주택조합제도의 본질상 건축한 일부 신축 건물을 일반분양하여 그 분양대금으로 일부 건축비를 충당하는 사정만을 가지고 영리성이 있다고 할 수는 없으므로, 비영리법인에 해당한다고 한다<sup>110)</sup>.

## 나. 판례 및 과세관청의 입장

108) 김완석, “재건축에 대한 조세법적 검토”, 「토지공법연구」 제33집, 한국토지공법학회, 2006.11, p.47; 김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2, p.49.

109) 이종교, “주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구”, 「공법연구」 제37집 제1-2호, 한국공법학회, 2008.10, p.169.

110) 김명섭, “주택재건축 관련 취득세 논의”, 「사법논집」 제42집, 법원도서관, 2006.12, p.252.

판례의 입장은 정비사업조합은 비영리법인에 해당한다고 한다. 즉, 대법원은 구 도시재개발법(1995. 12. 29. 법률 제5116호로 전문 개정되기 전의 것)상 주택개량재개발조합은 법인세법 제1조 제1항 소정의 특별법에 의하여 설립된 법인으로서 민법 제32조에 규정된 설립목적 및 그와 유사한 설립목적을 가진 비영리법인에 해당하므로, 청산소득에 대한 법인세 납세의무를 부담하지 않는다고 한다<sup>111)</sup>.

과세관청의 경우에도 재개발조합은 비영리법인이라는 전제하에 조합이 획득한 소득 중에서 비조합원에게 분양하는 주택 및 상가만을 수익사업으로 보아 법인세를 과세하고 있다<sup>112)</sup>. 조세심판원의 경우도 동일한 입장을 취하고 있다<sup>113)</sup>.

#### 다. 결어

정비사업조합은 다음과 같은 근거로 영리법인에 해당한다고 보아야 할 것이다.

첫째, 조세특례제한법 제104조의 2 제2항에서는 도시및주거환경정비법 제18조에 따라 설립된 조합(전환정비사업조합을 포함하며, 이하 “정비사업조합”이라 한다)에 대하여는 법인세법 제1조에 불구하고 2010년 12월 31일 이전에 끝나는 사업연도까지는 비영리내국법인으로 보아 법인세법(같은 법 제29조는 제외한다)을 적용한다고 규정하고 있다. 이는 기본적으로 조합을 영리법인임을 전제로 한 것이라고 할 것이다. 즉, 조세특례제한법상의 규정은 현재의 정비사업조합이 영리법인에 해당한다는 전제하에 2010년까지는 일시적으로 비영리법인으로 취급하겠다는 규정으로 보아

111) 대법원 2005.5.27. 선고, 2004두7214 판결.

112) 국세청, 1993.4.27, 법인 46012-1554.

113) 국심, 1994.1.13, 93서2665.

야 할 것이다.

둘째, 일반적으로 주택재건축사업은 아파트 단지를 위주로 시행되고 있는 현실에서 보아 일반분양수입이 거액인 동시에, 조합원 분양사업과 일반분양사업은 주택 재건축사업에서 불가분의 관계에 있으며, 실질에 있어서 하나의 목적이다. 조세특례제한법의 규정은 외형상 비영리법인으로 규정하면서도 비영리법인의 고유목적사업비에 충당되는 수익사업소득에 대한 고유목적사업 준비금의 손금산입을 허용하지 않음으로써 과세상 실질에 있어서는 영리법인과 같이 취급하는 것임을 알 수 있다<sup>114)</sup>.

셋째, 재건축사업의 경우에는 대부분 토지등 소유자의 재산가치의 증식을 목적으로 이루어지고 있다. 따라서 출자자의 재산가치 증식을 위해서 주택을 건축 및 판매하는 영리법인과 실질적으로 거의 동일하다고 보아야 할 것이다.

넷째, 주택사업에서 발생한 이익은 출자자들이 납부하여야 할 분양대금에서 조성하게 되기 때문에 재건축사업의 모든 수익과 비용은 사실상 조합원에게 배분되게 된다. 이 경우에 배당은 조합원의 출자액에 비례하게 되므로 일반 영리법인의 배당과 차이가 없다고 할 것이다. 따라서 영리법인으로 보아야 할 것이다.

다섯째, 법인세법 제1조 제2호에서는 비영리법인이란 민법 제32조의 규정<sup>115)</sup>에 의하여 설립된 법인, 사립학교법 기타 특별법에 의하여 설립된 법인으로서 민법 제32조의 규정된 목적과 유사한 목적을 가진 법인 및 국세기본법 제13조 제4항의 규정에 의한 법인으로 보는 법인격이 없는 단체를 말한다고 규정하고 있다. 그런데, 정비사업조합은 그 설립목적이 학술·종교·자선·기예 및 사

114) 김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2, p.50.

115) 학술, 종교, 자선, 기예, 사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 사단 또는 재단은 주무관청의 허가를 얻어 이를 법인으로 할 수 있다(민법 제32조).

교 등과 같은 비영리활동의 수행에 있지 않기 때문에 영리법인으로 보아야 할 것이다.

마지막으로, 주택재건축사업은 비수익사업인 조합원용 주택건축비를 수익사업인 일반분양수입에서 충당하는 것이 예정된 사업이다. 이러한 손익구조가 비영리법인의 본질이므로, 주택재건축정비사업조합을 실질적인 비영리법인으로 본다면 그러한 고유목적사업 전입 상당액은 일반 비영리법인의 경우와 같이 법인세 과세소득계산에서 손금산입을 허용해야 할 것이다. 그러나, 조세특례제한법상의 관련 규정은 주택재건축정비사업조합을 비영리법인으로 적용하도록 규정하면서도 한편으로는 고유목적사업 준비금의 손금산입을 허용하지 않고 있다. 이는 실질적으로는 영리법인과 동일하게 취급하겠다는 의미라고 해석할 수 있을 것이다<sup>116)</sup>.

116) 同旨; 김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2, pp.103-104.

## 제5장 양도소득세 과세문제

### 제1절 정비사업조합에 대한 조합원 출자 등에 대한 양도소득세의 과세여부

#### 1. 양도의 의미

자본이득(Capital Gains)이란 재고자산이나 이에 준하는 자산 외의 자산의 가치의 증가익을 의미한다. 우리나라에서는 자본이득 중 특히 실현된 이득에 대하여만 소득세를 과세하고 있는데, 이를 양도소득이라고 한다. 이러한 양도소득은 장기간에 걸쳐서 조성·집적된 소득이 매매 등과 같은 행위에 의하여 일시에 실현되는 속성을 갖는다. 따라서 보유기간 동안에 발생한 소득을 당해 소득이 실현된 연도에 일시에 과세하기 때문에 매년 단위로 발생 또는 증가한 이득에 대하여 소득세를 과세하는 경우보다 필연적으로 세부담이 가중되는 현상이 나타나게 된다. 양도소득세가 초과누진세율구조를 채택하고 있기 때문이다. 이를 결집효과라고 한다<sup>117)</sup>.

우리나라의 소득세법에서는 양도란 자산에 대한 등기 또는 등록에 관계없이 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등으로 인하여 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것을 말한다고 규정하고 있다<sup>118)</sup>. 한편, 부담부증여에 있어서 증여자의 채무를 수증자가 인수하는 경우에는 증여가액 중 그 채무액에 상당하는 부분은 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것으로 본다. 따라서 현행 소득세법상 양도란 자산의 이전적 승계 가운데 교환조건적 또는 대가

117) 김완석, 「소득세법론」, (주)광교이텍스, 2009, p.549.

118) 소득세법 제88조 제1항.

적 관계가 수반되는 유상이전만을 의미하고, 자산의 소유권이 증여나 상속과 같은 무상이전에 의하여 이루어지는 경우에는 양도소득세가 과세되지 않고, 수증자에 증여세를 과세하거나 상속인에게 상속세를 과세한다. 한편, 소득세법에서는 유상이전의 유형으로 매도, 교환 및 법인에 대한 현물출자<sup>119)</sup> 등을 규정하고 있지만, 이는 예시적인 규정으로 이에 해당하지 아니하더라도 유상이전에 해당하는 경우에는 당연히 양도소득세가 과세된다.

배우자 또는 직계존비속<sup>120)</sup>에게 양도한 재산은 양도자가 당해 재산을 양도한 때에 그 재산의 가액을 배우자 등이 증여받은 것으로 추정하여 이를 배우자 등의 증여재산가액으로 한다. 또한 특수관계에 있는 자<sup>121)</sup>에게 양도한 재산을 그 특수관계에 있는 자가 양수일로부터 3년 이내에 당초 양도자의 배우자 등에게 다시 양도한 경우에는 양수자가 당해 재산을 양도한 당시의 재산가액을 당해 배우자 등이 증여받을 것으로 추정하여 이를 배우자 등의 증여재산가액으로 한다. 다만, 당초 양도자 및 양수자가 부담한 소득세법에 의한 결정세액의 합계액이 당해 배우자 등이 증여받은 것으로 추정할 경우의 증여세액보다 큰 경우에는 그러하지 아니하다<sup>122)</sup>. 이와 같이 배우자 등에 대한 양도시 이를 증여로 추정하는 이유는 증여세의 부담을 회피하기 위하여 유상이전의 형식을 취하는 경우가 많기 때문이다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 자산의 유상이전이 확실하기 때문에 양도로 본다<sup>123)</sup>.

#### ① 법원의 결정으로 경매절차에 의하여 처분된 경우

119) 한편 조합에 대한 현물출자의 경우에 양도에 해당하는지의 여부에 대한 논란이 있는데, 이에 대한 구체적인 내용은 (김완석, 「소득세법론」, (주)광교이텍스, 2009, pp.558-559)의 내용을 참조하기 바란다.

120) 이하에서는 배우자 등이라 한다.

121) 특수관계에 있는 자란 양도자 및 양도자의 배우자 또는 직계비속과 상속세및증여세법 시행령 제26조 제4항 각호의 1에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다.

122) 상속세및증여세법 제44조 제1항 및 제2항.

123) 상속세및증여세법 제44조 제3항.



- ② 파산선고로 인하여 처분된 경우
- ③ 국세징수법에 의하여 공매된 경우
- ④ 증권거래법 제2조 제12항의 규정에 의한 유가증권시장 또는 동조 제14항의 규정에 의한 코스닥시장을 통하여 유가증권이 처분된 경우. 다만, 불특정다수인간의 거래에 의하여 처분된 것으로 볼 수 없는 경우로서 대통령령이 정하는 경우를 제외한다.
- ⑤ 배우자 등에게 대가를 지급받고 양도한 사실이 명백히 인정되는 경우

이와 같이 배우자 등에게 양도한 재산에 대하여 증여로 추정하여 당해 배우자 등에게 증여세를 부과한 경우에는 소득세법의 규정에 불구하고 당초 양도자에게 당해 재산의 양도에 따른 소득세를 부과하지 아니한다.

## 2. 양도의 해당 여부

정비사업조합에 대한 조합원의 출자가 양도소득세의 과세대상이 되는 양도에 해당하는지의 여부가 문제된다.

이에 대하여는 긍정설과 부정설의 대립을 상정할 수 있다. 이하에서는 이러한 긍정설과 절충설 및 부정설의 입장에 대하여 살펴보고, 정비사업조합에 대한 조합원의 출자가 양도에 해당하는지의 여부에 대하여 살펴보고자 한다.

### 가. 긍정설

긍정설의 입장은 정비사업조합에 대한 조합원의 출자는 양도에 해당한다는 견해로서, 그 근거는 다음과 같다.

첫째, 토지구획정리사업을 통한 환지의 경우에는 토지의 위치와

## 84 1. 정비사업조합에 대한 조합원 출자 등에 대한 양도소득세의 과세여부

면적만이 변경될 뿐이며, 이를 통하여 토지 이용의 효율을 높일 수 있기 때문에 국가가 정책적으로 비과세대상으로 인정할 수 있지만, 주택재개발 및 주택재건축의 경우에는 토지의 구획정리와는 달리 기존의 토지·건축물이 완전히 다른 주택으로 신축되는 점을 고려할 때에는 이를 양도로 보아야 한다고 한다<sup>124)</sup>.

둘째, 소득세법 제88조 제1항에서는 법인에 대한 현물출자를 양도소득세의 과세대상이 되는 양도로 규정하고 있는 바, 이러한 조합에 대한 현물출자의 경우 출자된 자산이 출자자의 개인재산과 구별되는 별개의 조합재산을 이루어 조합원의 합유로 되고, 출자자는 그 출자의 대가로 조합원의 지위를 취득하는 것이기 때문에 양도소득세의 과세대상인 양도에 해당한다고 한다<sup>125)</sup>.

### 나. 절충설

절충설은 재개발조합에 대한 출자행위는 양도소득세의 과세대상이 되는 양도에 해당하지 않지만, 재건축조합에 대한 출자행위는 양도소득세의 과세대상이 된다는 입장이다. 즉, 재개발·재건축사업의 경우 이전 건물 및 토지에 관련된 다양한 권리관계를 일률적으로 정리하기 위해서는 공용환지 또는 공용환권이라는 법적 개념을 차용하여 온 것일 뿐이고, 실제 재개발 또는 재건축사업의 결과로 생기는 신축주택과 종전주택을 전혀 동일성이 없음에도 공용환권의 결과 종전 토지 및 건물과의 동일성이 유지되고 있다는 형식논리, 재개발사업의 경우는 사업목적에 있어 공익성이 충분하고, 사업대상 토지의 면적 및 필지의 변경, 조합원들 사이

124) 민태욱, “주택재개발·재건축조합의 조세법적 성격과 조세문제”, 「토지공법연구」 제20집, 한국토지공법학회, 2003.11, pp.439-440.

125) 홍성욱, “주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 2006.2, pp.44-45.

의 지분교환 등이 일어나는 점 등 환지와 유사성이 있으므로 계속 비과세하는 것이 타당하지만, 재건축사업에 있어서는 조합원들이 종전에 소유하고 있었던 대지 지분의 일률적인 감축이 있을 뿐 필지의 변경이나 조합원들 사이의 지분교환이 일어나지 않는다는 점, 현실적으로는 재건축조합에의 출자 및 그 대가로 분양권(Purchase Right)을 취득하는 것이 불량건축물이나 노후건축물을 정비하고 도시환경을 개선한다는 공익적인 목적보다는 조합원들이 보유하고 있는 자산의 가치증가라는 사익추구적인 성격이 훨씬 강하다는 점, 특히 재건축조합과 시공사 사이에 확정지분제로 공사도급계약이 체결되는 경우 조합원의 입장에서는 자신의 대지나 건물 지분을 출자하는 대가로 조합원입주권을 취득하는 교환계약을 체결하는 것과 실질적으로 아무런 차이가 없다는 점을 고려하면, 적어도 재건축조합에 대한 조합원출자행위는 양도소득세의 과세대상이 되는 자산의 양도로 보아야 한다고 한다<sup>126)</sup>.

#### 다. 부정설

부정설의 입장은 재개발조합에의 출자행위뿐만 아니라, 재건축조합에 대한 출자행위 모두 양도소득세의 과세대상에 해당하지 않는다는 입장이다.

#### 라. 과세관청의 입장

과세관청은 주택건설촉진법 제3조 제9호의 규정에 의한 재건축조합이 같은 법 시행령 제32조 제2항 제8호의 규정에 의한 재건

126) 한정훈, “재개발·재건축사업에 있어 양도소득세와 관련된 쟁점에 관한 연구”, 「재판자료」 제115집, 법원도서관, 2008.6, pp.534-535.

축사업을 시행하는 경우 조합원이 소유한 토지·건물을 재건축조합에 현물출자하고 사업시행 완료로 동 조합 측으로부터 건설된 주택의 처분계획에 따라 재건축한 주택을 분양받은 것은 환지로 보아 양도에 해당하지 아니하는 것이나, 환지청산금으로 교부받은 부분은 양도에 해당하여 양도소득세 과세대상이 된다고 한다<sup>127)</sup>. 즉, 과세관청의 입장은 기본적으로 부정설의 입장을 취하고 있다.

다만, 도시및주거환경정비법의 적용대상이 아닌 20세대 미만의 경우에는 현물출자한 날을 양도소득세를 과세하며, 현물출자한 날이라 함은 공동사업계약을 체결한 날로 보도록 하고 있다<sup>128)</sup>. 즉, 도시및주거환경정비법의 적용대상이 아닌 경우에는 양도로 보고 있는 것이다.

#### 마. 결어

앞에서 서술하였듯이 우리나라의 소득세법상 양도란 자산에 대한 등기 또는 등록에 관계없이 매도, 교환, 법인에 대한 현물출자 등으로 인하여 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것을 말한다. 다만, 도시재개발법 기타 법률의 규정에 의한 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되거나 체비지로 충당되는 경우에는 양도로 보지 아니한다고 규정하고 있다<sup>129)</sup>.

이 경우에 정비사업조합이 정비사업조합의 조합원에게 종전의 토지 또는 건축물에 대신하여 건축물을 분양하는 것이 소득세법 제88조 제2항에서의 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되는 때에 해당하는지의 여부가 분명하지 않다.

생각건대, 정비사업조합의 조합원이 정비사업조합에 건축물 및

127) 재산 46014-978, 2000.8.9

128) 제도 46011-10615, 2001.4.16.

129) 소득세법 제88조 제2항.

그 부속토지를 현물출자하고 관리처분계획에 따라 취득하는 대지 또는 건축물 등은 소득세법 제88조 제2항의 도시개발법 기타 법률에 의한 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되거나 체비지로 충당되는 경우에 해당하여 양도에 해당하지 않는다고 보는 것이 타당할 것이다. 정비사업조합의 조합원이 정비사업조합에 토지 또는 건축물을 현물출자하는 때에는 양도로 보지 않기 때문에 정비사업조합의 조합원이 관리처분계획에 따라 취득한 토지 또는 건축물을 양도하는 때에 한꺼번에 과세하도록 하고 있다<sup>130)</sup>.

결과적으로 재개발 또는 재건축 사업시에 조합원이 조합에게 토지 등을 제공하는 것과 재개발·재건축 사업이 완료되어 조합원에 건물 등을 분양하는 것 및 일반인에게 분양하는 것 모두 양도소득세를 과세하지 않는다고 보는 것이 타당할 것이다.

한편, 과세관청의 도시및주거환경정비법의 적용대상 여부에 따라서 양도소득세의 과세대상 여부를 달리 취급하고 있는데, 그 근거가 명확하지 않기 때문에 그 타당성에 있어서는 의문이다.

## 제2절 조합원입주권의 양도소득세 과세대상의 구분

### 1. 양도소득세 과세대상

양도소득세의 과세대상은 부동산 등 일정한 자산에 한정되어 있다. 즉 법에 규정된 경우에 한하여 양도소득세를 과세하는데, 이하에서는 이러한 양도소득세의 과세대상에 대하여 간략하게 살펴보고자 한다.

130) 同旨; 김완석, “재건축에 대한 조세법적 검토”, 「토지공법연구」 제33집, 한국토지공법학회, 2006.11, p.55.

### 가. 토지와 건물

토지는 지적법에 의하여 지적공부에 등록하여야 할 지목에 해당하는 것을 말하며, 건물에는 건물에 부속된 시설물과 구축물을 포함한다<sup>131)</sup>.

### 나. 부동산에 관한 권리

부동산에 관한 권리란 부동산을 취득할 수 있는 권리, 지상권, 전세권과 등기된 부동산임차권을 말한다<sup>132)</sup>. 이 경우 부동산을 취득할 수 있는 권리란 특정한 부동산을 취득할 수 있는 지위 또는 기회이익을 가리키는 것으로서, 건물이 완성되는 때에 그 건물과 이에 부수되는 토지를 취득할 수 있는 권리를 포함한다.

### 다. 주식 등

주식의 양도에 대하여는 모든 주식의 양도에 대하여 양도소득세를 과세하는 것이 아니라, 다음 중 하나에 해당하는 주식 또는 출자지분의 양도로 인하여 발생하는 소득에 한하여 양도소득세를 과세한다<sup>133)</sup>.

① 증권거래법에 의한 주권상장법인의 주식 또는 출자지분 등으로서 소유주식의 비율이나 시가총액 등을 감안하여 대통령령이 정하는 대주주<sup>134)</sup>가 양도하는 것과 동법에 의한 유가증권시장에

131) 소득세법 제94조 제1항 제1호.

132) 소득세법 제94조 제1항 제2호.

133) 소득세법 제94조 제1항 제3호.

134) 대주주란 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

첫째, 법인의 주식 또는 출자지분을 소유하고 있는 주주 또는 출자자 1인과 그와 국세기본법시행령 제20조의 규정에 의한 친족 기타 특수관계에 있는 자가 주식

서의 거래에 의하지 아니하고 양도하는 것

② 증권거래법에 의한 코스닥상장법인의 주식 등으로서 당해 법인의 대주주가 양도하는 것과 동법에 의한 거래에 의하지 아니하고 양도하는 것

③ 주권상장법인 또는 코스닥상장법인이 아닌 법인의 주식 등

따라서 우리나라의 경우에는 주권상장법인의 주식 또는 코스닥상장법인의 주식 등으로서 대주주가 양도하는 분과 비상장법인의 주식에 한하여 양도소득세를 과세하고, 주권상장법인 또는 코스닥상장법인의 소액주주 등이 양도하는 주식 등의 경우에는 양도소득세를 과세하지 않고 있는 것이다.

#### 라. 기타자산

특정주식, 부동산과다보유법인의 주식, 사업용 고장자산과 함께 양도하는 영업권 및 특정시설물의 이용권·회원권을 말한다.

### 2. 조합원입주권의 양도소득세 과세대상 구분

조합원입주권은 양도소득세의 과세대상에 해당한다. 여기서 문제되는 것은 조합원입주권을 부동산으로 볼 것인지 또는 부동산을 취득할 수 있는 권리로 볼 것인지의 여부이다. 이와 같이 부동산으로 볼 것인지, 아니면 부동산을 취득할 수 있는 권리로 볼 것

---

등의 양도일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일 현재 당해 법인의 주식 등의 합계액의 100분의 3 이상을 소유한 경우의 당해 주주 1인 및 기타주주.

둘째, 주식 등의 양도일이 속하는 사업연도의 직전사업연도 종료일 현재 주주 1인 및 기타주주가 소유하고 있는 당해 법인의 주식 등의 시가총액이 100억원 이상인 경우의 당해 주주 1인 및 기타주주

인지에 따라서 양도소득세의 과세에 있어서 장기보유특별공제의 적용대상 여부 및 세율의 적용 등이 서로 상이하게 적용되기 때문이다.

부동산을 취득할 수 있는 권리라 함은 부동산 자체의 취득을 주목적으로 하는 권리로서, 부동산의 취득을 권리의 직접 대상으로 하거나, 그렇지 않더라도 적어도 그 권리를 취득하는 사실상의 주된 목적이 부동산 자체의 취득에 있어 향후 추가적인 요건을 구비하거나 일정한 절차를 거친다면 그 부동산을 취득할 수 있게 되는 권리를 의미한다<sup>135)</sup>.

이 경우에 분양예정지 대지 또는 건축시설을 취득할 수 있는 권리는 환지지구내의 토지로 볼 수 있고, 따라서 조합원 분양권은 환지예정지구내의 토지를 양도한 것으로 보아야 한다는 견해를 상정할 수 있다<sup>136)</sup>. 생각건대, 재개발조합원이 조합에 종전의 토지 또는 건축물을 제공하고 관리처분계획에 따라 취득하는 조합원 분양권의 법적 성격은 부동산을 취득할 수 있는 권리로 보아야 할 것이다<sup>137)</sup>.

또한, 부동산을 취득할 수 있는 권리라 함은 부동산 자체의 취득을 주된 목적으로 하는 권리로서, 부동산의 취득을 권리의 직접 대상으로 하거나 그렇지 않더라도 적어도 그 권리를 취득하는 사실상의 주된 목적이 부동산 자체의 취득에 있어 향후 추가적인 요건을 구비하거나 일정한 절차를 거친다면 그 부동산을 취득할 수 있게 되는 권리를 의미한다. 이러한 관점에서 재건축조합의 조합원이 당해 조합을 통하여 취득한 입주자로 선정된 지위는 부동산을 취득할 수 있는 권리로 보아야 한다<sup>138)</sup>.

135) 대법원 2000. 9. 29선고, 98두205 판결.

136) 송승찬, “도시재개발사업에서 조합원이 관리처분계획에 의하여 취득하는 분양 예정지 대지 또는 건축시설 양도의 성격”, 「대법원 판례해설」, 법원행정처, 1994.5, p.304.

137) 대법원 1993.11.23선고, 93누1633판결.



이와 같이 조합원입주권은 원칙적으로 부동산을 취득할 수 있는 권리에 해당한다고 할 수 있는데, 이하에서는 이러한 조합원입주권의 취득시기와 조합원입주권이 부동산으로 되는 시기에 대하여 살펴보기로 한다.

### 가. 조합원입주권으로 변동되는 시기

부동산을 취득할 수 있는 권리인 조합원입주권으로 변동되는 시기가 언제인지가 문제이다.

이에 대하여 다음과 같은 근거로 사업계획의 승인이 있는 때가 조합원입주권의 취득시기로 보는 것이 타당하다는 견해가 있다.

첫째, 사업계획승인처분의 내용 및 성격 등에 비추어 보면, 재건축조합의 조합원이 재건축조합에 제공한 종전의 토지 또는 건축물에 대한 소유권 등은 재건축 사업계획이 승인됨에 따라 그 때부터 장차 분양받을 대지나 건축시설에 대한 소유권을 취득할 때까지는 이를 분양받을 권리로 변환되었다고 할 것이므로, 그 권리의 취득시기는 사업계획의 승인이 있는 때로 봄이 타당하다고 한다<sup>138)</sup>.

둘째, 재건축사업은 노후·불량주택을 철거하고 그 철거한 대지 위에 새로운 주택을 건설하는 사업인 바, 재건축조합의 조합원이 재건축조합에 종전의 토지 및 건축물을 제공함으로써 사업계획승인에 따라 취득하게 되는 분양예정 대지 또는 건축시설을 분양받을 권리는 재건축사업이 시행됨에 따라 그 분양받을 대지나 건축

138) 대법원 2000.9.29선고, 98두205판결; 대법원 2005.3.11선고, 2004두9456판결.

139) 조일영, “구 주택건설촉진법에 의한 재건축조합의 조합원이 기존의 주택이나 대지를 제공하고 그 사업계획에 따라 취득하는 주택 등을 분양받을 권리의 취득시기”, 「대법원 관례해설」 제69호, 2007.12, 법원도서관, p.340; 조성권, “재건축 아파트 분양권과 관련된 1세대 1주택 비과세 문제”, 「재판자료」 제108집, 법원도서관, 2005.12, p.353.

시설에 대한 소유권을 취득할 때 까지는 부동산을 취득할 수 있는 권리로 변환되었다고 할 것이므로, 그 권리의 취득시기를 재건축사업계획의 승인이 있는 때로 보아야 할 것이 타당하다고 한다<sup>140)</sup>.

판례 또한 재건축조합 조합원은 재건축 사업계획승인시에 분양권을 취득한다고 판시하고 있다<sup>141)</sup>.

그러나, 다음과 같은 근거로 관리처분계획의 인가가 있을 때에 조합원입주권으로 변환된다고 보는 것이 타당할 것이다.

첫째, 관리처분계획 이전에 집합건물을 철거하고 이미 정비사업 구역지정이 있었다고 하더라도 관리처분계획승인 이전까지는 조합원 분담금 및 분양받을 주택의 규모 등이 전혀 확정되지 않은 상태이므로 조합원입주권이라는 권리 자체가 아직 확정되었다고 보기 어려운 사정을 고려하건대, 조합원입주권으로 변환되는 시기는 관리처분계획의 인가가 있는 때로 일원적으로 파악하는 것이 옳다고 생각한다.

둘째, 사업계획의 승인은 재건축조합이 자율적으로 정한 사업계획의 내용에 대하여 보충적으로 유효하게 만들어 주는 강화상의 인가에 불과하여 이러한 사업계획의 승인만으로는 재건축조합의 조합원이 조합을 통하여 확정적으로 입주자로 선정된 지위를 취득하는 것으로 볼 수는 없으므로, 재건축조합과의 관계에 있어서 조합원이 입주자로 선정된 지위를 취득하는 때는 관리처분계획의 인가가 있는 때로 보는 것이 타당하다<sup>142)</sup>.

140) 조성권, “재건축조합의 조합원이 1세대 1주택 비과세 요건을 갖춘 고가주택에 해당하는 분양권을 양도함에 있어 기존주택과 분양주택의 면적이 서로 상이한 경우, 양도소득세액을 산정함에 있어 장기보유특별공제액은 주택면적과 보유기간을 분양주택을 기준으로 할 것인지 여부”, 「대법원 판례해설」 제69호, 법원도서관, 2007.12, p.238.

141) 대법원 2007.6.15선고, 2005두5369판결.

142) 한정훈, “재개발·재건축사업에 있어 양도소득세와 관련된 쟁점에 관한 연구”, 「재판자료」 제115집, 법원도서관, 2008.6, p.537.

마지막으로, 소득세법 시행령 제155조 제16항도 관리처분계획인가일에 조합원이 입주자로 선정된 지위를 취득하는 것임을 전제로 하여 규정하고 있다<sup>143)</sup>.

#### 나. 조합원입주권이 부동산으로 변동되는 시기

조합원입주권이 부동산으로 변동되는 시기가 언제인지가 문제인데, 이에 대하여 도시및주거환경정비법에서 재건축사업에서의 권리변동과정에 명확하지 않음에 따라 발생하는 혼란을 피하기 위하여 재개발과 재건축사업 모두 이전고시라는 공법적인 절차를 거쳐 권리변동과정을 명확하게 하였는데, 굳이 세법상으로만 조합원들이 준공시에 신축주택에 관한 소유권을 취득한다고 볼 필요성이 없는 점, 소득세법 제88조 제1항에서 자산에 대한 등기 또는 등록과 관계없이 자산이 사실상 이전되는 것을 양도로 보는 이유는 사법상 거래의 경우 양도에 있어 등기가 등록 자체가 강제되지 않는 상황에서 등기 및 등록시점을 늦추는 방법으로 조세회피를 시도하는 것을 방지하고 일률적인 과세를 하기 위한 것이라 할 것인데, 공법적인 절차를 거쳐서 권리이전이 되는 경우 그러한 조세회피의 위험성이 낮다는 점, 신축건물이 준공된 이후 이전고시가 있기 이전에 조합원이 조합원 지위를 양도하는 경우에 장차 부동산을 취득할 권리의 양도를 보는 것이 보다 거래의 실질에 부합한다는 점 등을 종합하여 보건대, 조합원입주권은 이전고시에 의하여 부동산을 취득할 수 있는 권리에서 부동산으로 변환된다고 보는 것이 타당하다고 할 것이다<sup>144)</sup>.

143) 同旨; 조성권, “재건축아파트 분양권과 관련된 1세대 1주택 비과세 문제”, 「재판자료」 제108집, 법원도서관, 2005.12, pp.352-353.

144) 同旨; 한정훈, “재개발·재건축사업에 있어 양도소득세와 관련된 쟁점에 관한 연구”, 「재판자료」 제115집, 법원도서관, 2008.6, p.539.

### 제3절 조합원입주권 양도에 있어서 1세대1주택 비과세 특례적용의 문제

#### 1. 1세대 1주택 비과세 규정의 입법취지와 내용

1세대 1주택에 대한 비과세제도는 양도소득세 부과와 원칙에 대한 예외에 해당하므로 부동산 투기 억제대책이 강화되면 비과세 요건도 강화되고, 부동산 경기가 하강국면에 진입하여 투기 억제 필요성이 약화되면 비과세 요건도 약화되었는데, 그 중에서도 특히 주택의 보유기간에 대한 법령의 개정부분이 변화가 심하였다<sup>145)</sup>.

1세대 1주택의 양도소득에 대한 비과세란 주택의 양도당시를 기준으로 하여 1세대가 국내에 1주택만을 소유하다가 이를 양도한 경우로서 일정한 요건을 충족하는 경우 양도소득세를 비과세하는 것을 말한다. 이하에서는 이러한 1세대 1주택의 비과세제도를 비과세의 취지, 1세대의 의미, 주택의 범위, 1주택 및 그 특례, 3년간 보유의 의미로 구분하여 살펴보기로 한다.

#### 가. 1세대 2주택 비과세제도의 취지

1세대 1주택의 양도로 인하여 발생하는 소득에 대하여 양도소득세를 비과세하는 이유는 주택은 국민의 주거생활의 기초가 되는 것이기 때문에 1세대가 국내에 1개의 주택을 소유하다가 양도하는 것이 양도소득을 획득하거나 투기목적으로 일시적으로 거주하거나 소유하다가 양도하는 것이 아니라고 볼 수 있는 일정한

---

145) 조성권, “재건축아파트 분양권과 관련된 1세대 1주택 비과세 문제”, 「재판자료」 제108집, 법원도서관, 2005.12, p.321.

경우에는 그 양도소득에 대하여 소득세를 부과하지 아니함으로써 국민의 주거생활의 안정과 거주이전의 자유를 세법에서 보장하고자 함이라고 한다<sup>146)</sup>. 또한 1세대 1주택의 양도소득까지 과세한다면 그 세대는 종전의 주택에 비해 납부세액만큼 가치가 적은 새로운 주택밖에 구입하지 못한다는 점이 과세의 당위성보다 더욱 고려되었기 때문이라고 한다<sup>147)</sup>.

한편, 1세대 1주택 비과세 규정의 입법 취지는 자산가치의 상승은 장기간에 걸쳐 일어나고 그 상승분 중에는 실질적인 자산가치가 상승된 부분뿐만 아니라 화폐가치의 하락으로 인한 명목가치의 상승분도 포함되어 있다고 할 것인데, 아직 우리 세법상 이런 부분을 보정하여 주는 제도가 없는 상황에서, 1세대 1주택 양도로 인한 양도소득에도 무조건 양도소득세를 부과하게 되면 주택 양도인은 종전에 살고 있었던 주택보다 더 가치가 낮은 주택을 구입할 수밖에 없어 소득이 아니라 소득의 원천에 대하여 과세하는 문제점을 해결하기 위한 것이라는 견해도 있다<sup>148)</sup>.

결과적으로 1세대 1주택의 양도에 대하여 양도소득세를 비과세하는 취지는 국민들의 주거생활의 안정과 거주이전의 자유를 보장하기 위한 것이라고 할 것이다.

#### 나. 1세대의 의미

세대라 함은 거주자 및 그 배우자가 그들과 동일한 주소 또는 거소에서 생계를 같이하는 가족<sup>149)</sup>과 함께 구성하는 집단을 말한

146) 대법원 1993. 1. 19. 선고 92누12988판결; 대법원 2001. 9. 28. 선고 2000두10465판결 등.

147) 조성권, “재건축아파트 분양권과 관련된 1세대 1주택 비과세 문제”, 「재판자료」 제108집, 법원도서관, 2005.12, p.323.

148) 한정훈, “재개발·재건축사업에 있어 양도소득세와 관련된 쟁점에 관한 연구”, 「재판자료」 제115집, 법원도서관, 2008.6, pp.540-541.

다<sup>150)</sup>. 따라서 세대를 구성하기 위해서는 원칙적으로 배우자가 있어야 하며, 생계를 같이 하는 가족이란 당해 거주자와 생계비를 공동으로 부담하면서 생계를 유지하고 있는 가족을 의미한다. 또한 양도소득세의 비과세를 적용함에 있어서 1세대에 해당하는지의 여부는 양도당시를 기준으로 판단하여야 한다.

이와 같이 1세대는 적어도 거주자와 그 배우자로 구성되어야 하는바, 이는 부부가 주민등록의 분산을 통한 형식상의 1세대를 구성하는 방법으로 1세대 1주택 비과세 규정을 적용받아 양도소득세를 회피하는 것을 방지하기 위한 장치라고 할 것이다. 한편, 생계를 같이하는 동거가족은 현실적으로 생계를 같이하는 것을 의미하며, 반드시 주민등록상 세대를 같이 함을 요하지는 않으나 일상생활에서 볼 때 유·무상을 통하여 생활자금에서 생활하는 단위를 의미한다고 할 것이므로, 생계를 같이하는 동거가족인지의 여부는 그 주민등록지가 같은지의 여하에 불구하고 현실적으로 한 세대에서 거주하면서 생계를 함께하고 동거하는가의 여부에 따라 판단하여야 한다<sup>151)</sup>.

이 경우 배우자를 판단함에 있어서 사실혼 배우자를 포함할 것 인지의 여부가 문제인데, 이에 대하여 사실혼 배우자를 포함하여야 한다는 견해가 있다<sup>152)</sup>. 그러나, 판례는 양도소득세의 비과세 요건인 1세대 1주택에 해당하는지의 여부를 판단함에 있어서, 거주자의 배우자가 거주자와 사실상 동거하고 생계를 같이 하는지의 여부를 묻지 아니하고 그 배우자라는 사실만으로 거주자와 1세대를 구성한다고 해석되고, 주택의 양도 당시 법률상 배우자라

149) 가족이란 거주자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 말하되, 취학·질병의 요양·근무상 또는 사업상의 형편으로 본래의 주소 또는 거소를 일시퇴거한 자를 포함한다(소득세법 시행령 제154조 제6항).

150) 소득세법 시행령 제154조 제1항.

151) 고성춘, 「조세법」하, 도서출판 청보, 2008, pp.294-295.

152) 강인애, 「신소득세법」, 한일조세연구소, 2006, p.1014.

면 비록 그 부부관계가 실질적으로 파탄에 이르렀다고 하더라도, 세법 규정의 엄격해석의 원칙상 배우자가 없는 경우를 전제로 하는 구 소득세법시행령 제15조 제2항은 그 적용이 없다고 할 것이므로 그 부부의 일방만으로 여기서 말하는 1세대를 구성한다고 볼 수 없다고 판시하여<sup>153)</sup> 법률상 배우자만을 의미하고 사실혼 배우자는 제외하는 것으로 보고 있다. 그러나, 조세평등주의의 입장에서 보면 세법에서 민법상 개념을 그대로 차용할 것이 아니라 조세법에 있어서는 실질관계가 중요하다고 할 것이므로 법률상 배우자 뿐만 아니라 사실혼 배우자의 경우도 포함하는 것이 타당할 것이다<sup>154)</sup>.

한편 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 배우자가 없는 때에도 1세대로 본다<sup>155)</sup>.

- ① 당해 거주자의 연령이 30세 이상인 경우
- ② 배우자가 이혼하거나 사망한 경우
- ③ 소득세법 제4조의 규정에 따른 소득이 국민기초생활보장법 제2조 제6호의 규정에 따른 최저생계비 수준 이상으로서 소유하고 있는 주택 또는 토지를 관리·유지하면서 독립된 생계를 유지할 수 있는 경우. 다만, 미성년자의 경우를 제외하되, 미성년자의 결혼, 가족의 사망 그밖에 기획재정부령이 정하는 사유로 1세대의 구성이 불가피한 경우에는 그러하지 아니하다.

## 다. 주택의 범위

### (1) 주택의 의의

153) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두17463판결; 대법원 1998. 5. 29. 선고, 97누19465판결.

154) 同旨; 30세 미만인 자가 사실혼관계에서 자녀까지 출산하여 함께 생활하는 경우에는 소득세법상 1세대 1주택의 가족으로 봄이 타당하다(국세심판원 1987. 12. 12 87서1737결).

155) 소득세법 시행령 제154조 제2항.

주택이란 주거용으로 사용하는 건물과 이에 부수되는 건물정착면적의 5배(도시지역 밖의 경우에는 10배) 이내의 토지를 말한다. 이 경우 주택에 해당하는지의 여부는 건물공부상의 용도구분이나 당국의 구조변경허가에 관계없이 사실상 주거에 공하는 건물을 뜻하는 것이고, 일시적으로 주거가 아닌 다른 용도로 사용되고 있다고 하더라도 그 구조·기능이나 시설 등이 본래 주거용으로서 주거용에 적합한 상태에 있고 주거기능이 그대로 유지·관리되고 있어 언제든지 본인이나 제3자가 주택으로 사용할 수 있는 건물의 경우에는 이를 주택으로 보아야 한다<sup>156)</sup>. 한편 주택에는 건축법상 허가받은 것뿐만 아니라 무허가 주택도 1세대 1주택으로서 비과세 요건을 충족한 경우에는 양도소득세를 비과세하는 것으로 보아야 할 것이다<sup>157)</sup>.

거주자가 비과세 요건을 갖춘 1주택의 전부를 양도하는 것은 물론 일부를 양도하는 경우에도 그 양도로서 분할되는 부분이 각각 1주택으로 되지 아니하는 한 비과세 대상이 된다고 할 것이므로, 거주자가 비과세 요건을 갖춘 1세대 1주택과 이에 부수되는 토지에 대한 지분을 양도한 것이라면 그 1주택을 분할하여 양도한 경우에 해당하지 아니하고, 1주택의 일부를 양도한 것에 불과하여 양도소득세 비과세 대상에 해당된다<sup>158)</sup>.

주택의 부수토지도 함께 비과세하는데, 주택에 부수되는 토지란 양도하는 주택과 경제적 일체를 이루고 있는 토지로서 사회통념상 주거생활의 공간으로 인정되는 토지를 의미한다<sup>159)</sup>. 또한 주택의 부수토지는 그 지목 여하를 불문하기 때문에 당해 토지의 지목이 전·답 등 농지이거나 임야인 경우에도 주택의 부수토지가

156) 同旨; 대법원 2005. 4. 28. 선고 2004두14960판결.

157) 강인애, 「신소득세법」, 한일조세연구소, 2006, p.1010.

158) 대법원 1993. 8. 24. 선고 93누3202판결.

159) 대법원 1995. 8. 22. 선고 95누7383 판결.



될 수 있는 것이다.

주택에 부수되는 토지를 건물면적의 5배(10배)의 범위 내로 제한한 것은 1세대 1주택을 병자하여 과다한 토지를 소유하는 것을 방지하기 위한 것이다. 또한 건물면적의 계산은 건물 정착면적, 즉 바닥면적으로 계산하기 때문에 여러 층으로 된 건물의 경우에도 1층의 건물 바닥면적을 기준으로 5배(10배)를 계산하는 것이다<sup>160)</sup>. 이 경우 1세대 1주택과 그 부수토지를 따로 양도하는 경우에도 당해 부수토지를 비과세할 것인지의 여부가 문제인데, 부수토지만을 별도로 양도하는 경우에는 비과세를 적용받을 수 없는 것으로 보아야 한다<sup>161)</sup>.

한편, 1세대 1주택의 비과세에 있어서 주택과 그 부수토지가 동일인의 소유임을 요하는 것은 아니고, 1세대 1주택의 요건을 갖춘 건물과 대지를 세대구성원이 각각 소유하고 있는 경우에도 이를 1세대 1주택으로 보아야 한다. 그리고 재개발조합의 조합원이 재개발조합에 주택 및 그 부수토지를 제공하고 관리처분계획에 따라 아파트분양권을 취득하여 양도한 경우에는 그 아파트분양권을 1세대 1주택 및 그 부수토지로 간주하여야 한다<sup>162)</sup>.

## (2) 고가주택의 제외

양도소득세의 비과세가 적용되는 주택에는 실지거래가액 9억원<sup>163)</sup>을 초과하는 고가주택은 제외한다<sup>164)</sup>. 종전에는 고급주택의

160) 조성권, “재건축아파트 분양권과 관련된 1세대 1주택 비과세 문제”, 「재판자료」 제108집, 법원도서관, 2005.12, p.328.

161) 同旨; 강인애, 「신소득세법」, 한일조세연구소, 2006, p.1016.

162) 대법원 1999. 12. 10. 선고, 98두3051판결.

163) 2008년까지는 고가주택의 기준가액을 6억원으로 하였는데, 2009년부터 9억원으로 상향조정하였다.

164) 소득세법 제89조 제3호, 소득세법 시행령 제156조.

경우에 비과세를 배제하였지만, 2002년 12월 30일 소득세법의 개정에 의하여 고가주택으로 변경되었다. 즉, 과거에는 양도소득세의 비과세 적용 배제 주택의 경우에는 가액기준과 면적기준을 동시에 충족하는 고급주택을 기준으로 하였지만, 현재는 가액기준만을 고려한 고가주택에 대하여 양도소득세의 비과세 적용을 배제하고 있는 것이다.

고가주택의 개념은 1세대 1주택의 양도차익에 대한 비과세제도에 있어서 과다한 양도차익에 대하여는 비과세 혜택을 부여하여서는 안된다는 국민들의 법감정을 고려하여 도입된 것이다. 이 경우 고가주택인지의 여부는 양도당시를 기준으로 하여 판단하여야 한다<sup>165)</sup>. 즉, 고가주택인지의 여부에 대한 판단기준은 양도당시이므로, 비과세요건을 충족하기 위해서는 양도 당시에만 고가주택이 아니면 족하고, 더 나아가 당해 주택이 취득일 이후 계속하여 고가주택이 아니었을 것까지는 필요로 하는 것은 아니다.

#### 라. 1주택 및 그 특례

양도소득세의 비과세를 적용받고자 하는 경우에는 당해 주택의 양도 당시에 1세대가 국내에 1개의 주택을 보유하고 있어야 한다. 이 경우 양도된 주택이 1세대 1주택에 해당하는지의 여부는 당해 주택의 양도당시를 기준으로 판단하여야 한다. 따라서 비과세대상이 되는 1세대 1주택에 해당하기 위해서는 당해 주택의 보유기간이 3년 이상으로서 양도당시 양도인이 구성하는 세대가 국내에 소유하는 1개의 주택이면 족하고, 당해 주택의 취득일 이후 다른 주택을 취득한 사실이 일체 없거나, 적어도 당해 주택을 보유한 3년 동안 다른 주택을 소유한 사실이 없을 것까지 필요로 하지 않

165) 대법원 1998. 7. 10. 선고 97누20816판결.

으며, 양도주택이 1세대 1주택에 해당하는지의 여부는 그 주택의 양도당시를 기준으로 판단하면 되는 것이다<sup>166)</sup>. 다만, 다음의 경우에는 2주택에 해당하는 경우에도 양도소득세의 비과세 규정을 적용한다<sup>167)</sup>.

① 국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택을 양도하기 전에 다른 주택을 취득<sup>168)</sup>함으로써 일시적으로 2주택이 된 경우 다른 주택을 취득한 날부터 2년 이내<sup>169)</sup>에 종전의 주택을 양도하는 경우. 이와 같이 일시적인 2주택에 대하여 2년의 유예기간을 설정하여 양도소득세를 비과세하는 이유는 부동산의 경우 그 매매가 용이하지 않을 뿐만 아니라 그 매매에 상당한 기간이 소요되는 점을 고려한 것이다.

② 상속받은 주택과 그 밖의 주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우<sup>170)</sup>. 이는 1세대 1주택을 보유하여 양도소득세가 과세되지 않게 되어 있는 자가 그의 의사나 선택에 의하지 아니하고 상속이라는 사유에 의하여 1세대 2주택이 되게 된 경우에는 일반 주택의 양도에 대하여 비과세의 혜택을 부여함으로써 본의 아니게 1세대 2주택이 됨으로써 양도소득세의 비과세 혜택이 소멸됨으로 인한 불이익을 구제하자는 데에 취지가 있다<sup>171)</sup>. 따라서 일반주택이 아니라 상속받은 주택을

166) 대법원 1993. 1. 19선고 92누12988판결.

167) 소득세법 시행령 제155조.

168) 자기가 건설하여 취득한 경우를 포함한다.

169) 2년 이내에 양도하지 못하는 경우로서 한국자산관리공사에 매각을 의뢰한 경우, 법원에 경매를 신청한 경우 및 국제징수법에 의한 공매가 진행 중인 경우를 포함한다(소득세법 시행규칙 제72조 제1항).

170) 2002년까지는 상속받은 주택을 먼저 양도하는 경우에는 기간에 상관없이 비과세하였다. 그러나, 이와 같은 규정은 상속주택에서 막대한 이익 발생하여도 양도소득세가 비과세되는 문제가 있어 이를 시정할 필요가 있었으며, 상속주택의 경우에는 본인의 의사와 상관없이 취득하게 되기 때문에 일반주택의 1세대 1주택 판정시 주택의 수에서 제외하도록 하여 문화재주택 및 농어촌주택과의 과세형평성을 고려하여 현재와 같이 개정하였다.

171) 대법원 1993. 2. 9.선고 92누15680 판결.

양도하거나 증여받은 경우에는 양도소득세를 과세한다.

③ 1주택을 보유하고 1세대를 구성하는 자가 1주택을 보유하고 있는 60세 이상<sup>172)</sup>의 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 동거봉양하기 위하여 세대를 합침으로써 1세대가 2주택을 보유하게 되는 경우 합친 날부터 5년 이내<sup>173)</sup>에 먼저 양도하는 주택

④ 1주택을 보유하는 자가 1주택을 보유하는 자와 혼인함으로써 1세대가 2주택을 보유하게 되는 경우 그 혼인한 날부터 5년 이내<sup>174)</sup>에 먼저 양도하는 주택

⑤ 문화재보호법에 의한 지정문화재 또는 등록문화재에 해당하는 주택과 그밖의 주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우. 이는 지정문화재 등의 보전·관리를 지원하기 위한 정책적 견지에서 마련된 조세우대조치라고 할 수 있다.

⑥ 상속주택·이농주택 또는 귀농주택으로서 수도권 외의 지역 중 읍지역 또는 면지역에 소재하는 주택과 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우. 이 경우 귀농주택에 대하여 양도소득세 특례를 규정하고 있는 이유는 도농간 교류를 촉진하여 농어촌주택에 대한 수요를 유지하고 농어촌주택의 정비를 촉진하기 위한 정책의 일환이라고 할 것이다<sup>175)</sup>.

⑦ 기획재정부령이 정하는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그밖에 부득이한 사유로 취득한 수도권 밖에 소재하는 주택과 일

172) 2008년까지는 남자의 경우에는 60세 이상, 여자의 경우에는 55세 이상으로 규정하였지만, 2009년부터 남자와 여자를 60세 이상으로 동일하게 개정하였다.

173) 2008년까지는 2년 이내였는데, 2009년부터 5년 이내로 그 기간을 대폭 연장하였다.

174) 2008년까지는 2년 이내였는데, 2009년부터 5년 이내로 그 기간을 대폭 연장하였다.

175) 고성춘, 「조세법」 하, 도서출판 청보, 2008, p.310.

반주택을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우

⑧ 조합원입주권을 1개 소유한 1세대가 당해 조합원입주권을 양도하는 경우로서 양도일 현재 다른 주택이 없는 경우 또는 양도일 현재 1조합원입주권 외에 1주택을 소유한 경우<sup>176)</sup>

### 마. 3년간 보유의 의미

1세대 1주택으로서 양도소득세의 비과세대상이 되기 위해서는 당해 주택을 3년 이상 보유하여야 한다<sup>177)</sup>. 이 경우 보유기간의 계산은 당해 주택의 취득일부터 양도일까지로 하며<sup>178)</sup>, 취득일과 양도일은 원칙적으로 대금청산일로 하되, 그것이 불분명한 경우에는 소유권이전등기일로 하여야 한다.

한편, 종전주택을 헐고 신축하는 경우에는 거주기간이나 보유기간을 계산함에 있어서 그 기간을 통산하도록 규정하고 있는데, 이는 1세대 1주택의 비과세 입법취지가 거주자가 일시적으로 거주하다가 옮겨 다니는 것이 아니라 한 곳에서 상당기간 거주하다가 그 주택을 양도하고 주거를 이전하는 것은 국민의 당연한 자유이며, 권리로서 오직 양도소득을 얻기 위하여 투기를 도모하는 것이 아니므로 세법상 이를 보장하는데 있는 것이다.

서울특별시와 일정한 지역<sup>179)</sup>의 경우에는 보유기간이 3년 이상

176) 양도일 현재 1조합원입주권 외에 1주택을 소유한 경우에는 당해 1주택을 취득한 날부터 2년 이내에 당해 조합원입주권을 양도하는 경우에 한한다.

177) 보유기간의 계산은 1세대를 단위로 하기 때문에 1세대를 구성하는 세대원간에 증여 등을 원인으로 하여 주택의 소유권자가 다르게 된 경우에도 그 양도 전후를 통하여 1세대를 구성하는 이상 소유권자별로 그 보유기간을 계산할 것이 아니라 그 세대 전체의 보유기간을 계산하는 것이 타당하다(대법원 1995. 7. 14. 선고 94누15530판결).

178) 소득세법 시행령 제154조 제5항.

179) 구체적으로는 서울특별시, 과천시 및 택지개발촉진법 제3조의 규정에 의하여 택

이고, 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 경우에 한하여 비과세를 적용한다. 이 경우 거주기간에 대하여 소득세법 시행령 제154조 제5항은 주민등록표상의 전입일로부터 전출일까지로 한다고 규정하고 있지만, 이러한 규정은 단순히 입증의 편의를 위한 규정에 지나지 아니하며 납세의무자의 입증이 있으면 그 이외의 경우에도 가능할 것이다.

1세대가 양도일 현재 국내에 1개의 주택을 보유하고 있는 경우로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보유기간과 거주기간의 제한을 받지 아니한다<sup>180)</sup>.

① 임대주택법에 의한 건설임대주택을 취득하여 양도하는 경우로서 당해 건설임대주택의 임차일부터 당해 주택의 양도일까지의 거주기간이 5년 이상인 경우

② 주택 및 그 부수토지의 전부 또는 일부가 공익사업을위한토지등의취득및손실보상에관한법률에 의한 협의매수·수용 및 그 밖의 법률에 의하여 수용되는 경우. 이 경우에 있어서는 그 양도일 또는 수용일부터 2년 이내에 양도하는 그 잔존주택 및 그 부수토지를 포함하는 것으로 한다.

③ 해외이주법에 따른 해외이주로 세대전원이 출국하는 경우. 다만, 출국일부터 2년 이내에 양도하는 경우에 한한다.

④ 1년 이상 계속하여 국외거주를 필요로 하는 취학 또는 근무상의 형편으로 세대전원이 출국하는 경우. 다만, 2년 이내에 양도하는 경우에 한한다.

⑤ 1년 이상 거주한 주택을 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양 기타 부득이한 사유로 양도하는 경우

⑥ 장기저당담보주택을 양도하는 경우<sup>181)</sup>. 장기저당담보주택에

지개발예정지구로 지정·고시된 분당·일산·평촌·산본·중동 신도시지역을 말한다.

180) 소득세법 시행령 제154조 제1항 단서.

181) 소득세법 시행령 제155조의 2.

대하여 1세대 1주택의 특례를 인정한 취지는 노령화사회에 대비하여 연로자가 장기저당담보로 금융대출을 받아 생활비를 충당하는 경우를 지원하려는 정책적 배려이다. 즉, 1주택을 소유한 60세 이상의 연로자가 자기가 소유하고 있는 주택을 담보로 연금식 대출을 받아 생활하는 경우 당해 장기저당담보로 제공된 주택의 경우에는 보유기간의 제한을 받지 아니하는 것이다<sup>182)</sup>.

⑦ 주택개발사업 등의 시행기간 동안 거주하기 위하여 대체주택을 취득하는 경우

## 2. 조합원입주권 양도에 대한 1세대1주택 비과세특례 적용

### 가. 문제의 소재

주택의 재개발 및 재건축 과정에서는 기존에 거주하던 조합원들은 재개발 및 재건축으로 인하여 다른 곳으로 이주하여야 하며, 이주하는 경우에 소유하고 있던 분양권을 양도하기도 하고, 분양권을 소유한 채 일시적으로 다른 주택을 구입하기도 한다. 또한 재개발 및 재건축이 완료된 후에는 조합원으로서 분양받은 주택으로 이주하기도 하고, 종전에 구입한 주택에 계속하여 거주하기도 한다. 이와 같이 분양받은 주택 또는 그 이외의 주택을 양도하는 경우에 1세대 1주택의 비과세 적용여부가 문제되는 것이다.

이러한 비과세 적용여부에 대하여 과거에는 소득세법상 명확한 규정이 없어서 그 해석상 논란이 많이 되었는데, 현재는 소득세법 제89조 제2항과 소득세법 시행령 제156조의 2에 명문으로 규정하여 그 논란을 많이 제거하였다. 즉, 조합원입주권의 경우에도 조합원입주권을 1개 소유한 1세대가 당해 조합원입주권을 양도하는

182) 강인애, 「신소득세법」, 한일조세연구소, 2006, p.1055.

경우에는 1세대 1주택으로 보아 양도소득세를 비과세하며, 일시적으로 조합원입주권과 1주택이 있는 경우 등과 같은 특례를 인정하고 있어서 해석상 논란을 많이 제거하였다.

이하에서는 조합원입주권의 양도에 대한 양도소득세 비과세 적용여부에 대하여 간략하게 살펴보기로 한다.

#### 나. 조합원입주권의 양도에 대한 1세대 1주택 비과세의 적용 여부

현행 소득세법에서는 조합원입주권을 1개 소유한 1세대[도시및 주거환경정비법 제48조의 규정에 따른 관리처분계획의 인가일(인가일 전에 기존주택이 철거되는 때에는 기존주택의 철거일) 현재 제154조 제1항의 규정에 해당하는 기존주택을 소유하는 1세대에 한한다]가 당해 조합원입주권을 양도하는 경우 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 1세대 1주택으로 본다고 규정하고 있다. 다만, ②의 경우에는 당해 주택을 취득한 날부터 1년 이내에 당해 조합원입주권을 양도하는 경우에 한한다고 한다<sup>183)</sup>.

① 양도일 현재 다른 주택이 없는 경우<sup>184)</sup>

② 양도일 현재 1조합원입주권 외에 1주택을 소유한 경우

이에 대하여 주택의 양도로 인한 양도소득세의 과세시에 조합원입주권도 주택의 수에 합산되는데, 이는 재건축·재개발을 이용한 조세회피를 방지함으로써 과세형평을 제고하고, 재건축·재개발 주택에 대한 투기적인 수요를 억제할 수 있다는 점에서 정책적인 필요성은 인정되지만, 이러한 소득세법상의 규정은 조합원입주권

183) 소득세법 시행령 제155조 제17항.

184) 관리처분계획인가일 현재는 2주택이나 양도일 현재 입주자로 선정된 지위 외에 다른 주택이 없는 경우에는 1세대 1주택 비과세를 적용받을 수 있다(재산세과-4313, 2008.12.19).



과 일반 신규주택 분양권이 양도소득세 계산시 처분할 때에만 서로 다르게 취급된다. 즉, 양자는 완성된 주택을 받을 권리라는 점에서 동일한 성격을 가지고 있음에도 불구하고 조합원입주권 또는 분양권 자체를 양도할 경우에는 동일하게 부동산에 관한 권리로 취급하면서 조합원입주권과 주택을 함께 보유한 자가 주택을 처분할 경우에만 조합원입주권을 주택수 산정에 포함하는 것이다. 또한 1세대 1주택 비과세의 적용이나 1세대 2주택 및 3주택의 경우 세대기준으로 주택주가 몇 개인지에 따라 세부담에 차이가 크다. 따라서 양도소득세 과세실무에서 세대기준 주택수에 대한 다툼이 많다. 여기에 조합원입주권에 대한 것까지 주택수 산정에 들어오면서 세대 및 주택의 수에 따른 양도소득세를 더욱 복잡하게 만들었다고 한다.

결국 조합원입주권을 양도소득세 계산시 주택수에 포함시킨 소득세법 제89조 제2항, 제104조 제1항 제2호의4, 동조 제2호의6은 일반 신규주택 분양권과의 형평성, 1세대 1주택 비과세제도 및 1세대 2주택, 1세대 3주택 중과세제도의 운영의 단순화를 위해 삭제되는 것이 타당하다는 견해가 있다<sup>185)</sup>.

그러나, 재개발조합의 조합원이 재개발조합에 주택 및 그 부수토지를 제공하고 관리처분계획에 따라 취득한 아파트분양권을 양도하는 경우에는 당해 아파트분양권은 1세대 1주택과 그 부수토지를 양도한 것으로 간주하여 보유기간의 요건을 갖추면 당해 양도는 1세대 1주택의 양도로서 양도소득세를 비과세하는 것이 타당할 것인데<sup>186)</sup>, 그 근거는 다음과 같다.

첫째, 앞의 1세대 1주택 비과세규정의 입법 취지를 고려하건대, 1세대 1주택의 요건을 이미 충족하고 있던 사람이 재개발 또는

185) 박훈, “재개발조합의 과세문제”, 「조세와 법」 제1권 제2호, 서울시립대학교 법학연구소·지방세연구소, 2008.12, pp.228-229.

186) 대법원 1994.3.8선고, 93누1734판결.

재건축사업의 시행으로 인하여 주택의 소유권이 조합원입주권으로 변환되었다는 이유만으로 비과세 혜택을 받지 못하는 것은 현저히 공평에 반하기 때문에 조합원입주권에 대하여 1세대 1주택 비과세규정을 적용하는 것이 타당하고, 일단 1세대 1주택 비과세가 적용되는 경우에는 일시적인 2주택 소유자에 대한 특례규정도 적용된다고 보는 것이 타당할 것이다<sup>187)</sup>.

둘째, 재건축된 주택뿐만 아니라 재건축 중인 분양권도 종전 주택의 연장 내지는 변환된 것이라 할 것인데도 재건축한 주택이 완공된 후 그 주택을 양도하면 비과세되는데 반하여 재건축 중인 주택이 완공되기 전에 분양권을 양도하면 과세되는 것은 합리적이지 못하기 때문에, 재개발조합 또는 재건축조합의 조합원이 분양권을 양도하는 경우 그 분양권은 부동산을 취득할 수 있는 권리에 불과하고 이는 주택과 구별되므로 1세대 1주택에 관한 비과세규정을 직접 적용하여 양도소득세를 비과세하는데 어려움이 있는 바 이를 해소하여 일반 주택의 양도와 형평성을 유지하고 서민가계를 지원할 목적으로 아파트 분양권에 관하여도 양도소득세를 비과세하는 것이 타당할 것이다<sup>188)</sup>.

그리고, 재개발조합의 조합원이 재개발조합에 주택 및 그 부수토지를 제공하여 재개발사업의 일환으로 주택이 철거된 후 잔존하는 부수토지와 함께 장차 아파트 건축물을 분양받을 수 있는 조합원의 지위를 관리처분계획인가 이전에 양도한 경우, 그 권리의 양도 당시에 보유기간의 요건을 갖추었다면 그 양도는 1세대 1주택의 양도로서 양도소득세 비과세대상에 해당하는 것으로 보아야 한다<sup>189)</sup>.

187) 同旨; 한정훈, “재개발·재건축사업에 있어 양도소득세와 관련된 쟁점에 관한 연구”, 「재판자료」 제115집, 법원도서관, 2008.6, pp.542-543.

188) 고성춘, 「조세법」하, 도서출판 청보, 2008, pp.301-302.

189) 대법원 1999.12.10 선고, 98두3051판결.

또한 토지의 양도계약 체결 당시에 그 지상에 주택이 있었고 그 양도계약에는 부수토지 외에 주택도 포함된 것과 같이 볼 수 있어 비과세요건을 갖추고 있었다면 양도계약 후 토지의 인도시기 이전에 주택이 철거되어 나대지 상태로 되었다고 하더라도 양도소득세를 비과세되고, 양도당시에 이미 나대지가 되었다고 하더라도 당해 주택의 철거가 도시계획사업의 시행으로 인한 것이라면 이는 비과세 요건을 구비한 것이 된다<sup>190)</sup>.

한편, 수분양자의 조합원입주권의 양도는 주택으로 취급될 여지가 없기 때문에 어떠한 경우라 하더라도 부동산을 취득할 수 있는 권리에 해당한다고 보아야 한다.

## 제4절 재건축부담금과 양도소득세의 이중과세 문제

### 1. 현행 소득세법상의 규정

정비사업조합의 조합원은 재건축사업으로 인한 재건축초과이익에 10% ~ 50%의 초과누진율을 곱하여 계산한 금액을 재건축부담금으로 납부하여야 한다<sup>191)</sup>. 이러한 재건축부담금은 소득세법

190) 조성권, “재건축아파트 분양권과 관련된 1세대 1주택 비과세 문제”, 「재판자료」 제108집, 법원도서관, 2005.12, p.328.

191) 재건축초과이익환수에관한법률 제12조.

납부의무자가 납부하여야 할 재건축부담금은 제7조의 규정에 의하여 산정된 재건축초과이익을 당해 조합원 수로 나눈 금액에 다음의 부과율을 적용하여 계산한 금액을 그 부담금액으로 한다.

- ① 조합원 1인당 평균이익이 3천만원 이하 : 면제
- ② 조합원 1인당 평균이익이 3천만원 초과 5천만원 이하 : 3천만원을 초과하는 금액의 100분의 10×조합원수
- ③ 조합원 1인당 평균이익이 5천만원 초과 7천만원 이하 : 200만원×조합원수+5천만원을 초과하는 금액의 100분의 20×조합원수
- ④ 조합원 1인당 평균이익이 7천만원 초과 9천만원 이하 : 600만원×조합원수+7천만원을 초과하는 금액의 100분의 30×조합원수
- ⑤ 조합원 1인당 평균이익이 9천만원 초과 1억1천만원 이하 : 1천200만원×조합원

시행령 제163조에서 양도차익을 산정함에 있어서 비용으로 공제하도록 하고 있다. 즉, 개발이익환수에관한법률에 따른 개발부담금(개발부담금의 납부의무자와 양도자가 서로 다른 경우에는 양도자에게 사실상 배분될 개발부담금 상당액을 말한다)과 재건축초과이익환수에관한법률에 따른 재건축부담금(재건축부담금의 납부의무자와 양도자가 서로 다른 경우에는 양도자에게 사실상 배분될 재건축부담금 상당액을 말한다)은 자본적 지출액으로 보아 양도차익을 산정함에 있어서 필요경비로 공제하도록 하고 있다<sup>192)</sup>.

## 2. 현행 규정의 문제점 및 개선방안

앞에서 살펴보았듯이 현행 소득세법은 재건축부담금을 비용으로 공제하도록 하고 있다.

이러한 재건축부담금은 그 목적에 있어서 통상적인 부담금이 일정한 공익사업과 이해관계가 있는 자가 그 사업에 필요한 비용의 전부나 일부를 납부하는 금전급부와는 달리, 조세 또는 준조세적인 성격을 갖는다고 할 수 있다<sup>193)</sup>. 즉, 재건축부담금은 그 형식은 부담금이지만, 그 실질은 소득세의 일종으로서 양도소득의 일부이기 때문에 양도소득세의 예납적 성격을 가진다고 할 것이다. 따라서 재건축부담금을 양도소득세액에서 직접 차감하지 않고 필요경비로 계상하는 경우에는 재건축초과이익 중에서 재건축부담금을 공제한 나머지 금액에 대하여는 재건축부담금과 양도소득

수+9천만원을 초과하는 금액의 100분의 40×조합원수

⑥ 조합원 1인당 평균이익이 1억1천만원 초과 : 2천만원×조합원수+1억1천만원을 초과하는 금액의 100분의 50×조합원수

192) 소득세법 시행령 제163조 제3항 제3의2호 및 제3의3호.

193) 同旨; 류지태, 「행정법신론」, 신영사, 2007, p.979.

세를 중복적으로 과세하는 것이 되어 불합리하다고 할 것이다<sup>194)</sup>. 부연하면, 양도소득세와 재건축부담금의 이중과세 자체만으로 당해 규정의 위헌성 여부를 논하기는 어렵지만, 뒤에서 살펴보듯이 현행 소득세법상 양도소득세의 중과세율은 50%와 60% 또는 70%가 적용되며, 재건축부담금은 10% ~ 50%의 초과누진세율구조를 취하고 있기 때문에 재건축부담금과 양도소득세를 합하면 거의 재산의 몰수에 가깝기 때문에 그 위헌을 면하기 어렵다고 할 것이다.

이러한 문제점을 제거하기 위해서 현재의 비용공제를 채택하되, 재건축부담금의 이자까지 합산하여 공제하는 것이 바람직하다는 견해가 있다<sup>195)</sup>. 그러나, 세액공제의 방법이 아니라, 소득공제의 방법을 유지하면서 이자비용을 추가로 공제한다고 하여도 이중과세의 문제는 그대로 남아있기 때문에 그 타당성을 인정하기는 힘들다고 할 것이다.

또한, 양도소득금액에서 부담한 재건축부담금 상당의 재건축초과이익을 공제하는 것이 타당하다는 견해가 있다<sup>196)</sup>. 즉, 양도소득의 과세표준을 산정함에 있어서 재건축부담금 상당액을 공제하자는 견해이다. 그러나, 이와 같이 양도소득금액에서 공제하게 되면, 재건축부담금과 양도소득세의 세율구조의 차이로 인하여 과다공제 또는 과소공제의 문제가 여전히 남기 때문에 그 타당성을 인정하기 힘들다고 할 것이다.

결과적으로 재건축부담금과 양도소득세의 이중과세의 문제를

194) 이러한 중복과세의 문제는 양도소득세뿐만 아니라 일반적인 소득세와 법인세에 있어서도 동일한 문제가 발생하며, 개선방안은 양도소득세의 경우와 동일하다고 할 것이다.

195) 이주희, “재건축사업의 초과이익 환수제도의 부적정성에 관한 연구”, 「토지공법연구」 제40집, 한국토지공법학회, 2008.5, p.16.

196) 김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2, p.125.

해결하기 위해서는 다음과 같이 단기적인 개선방안과 장기적인 개선방안으로 구분하여 살펴볼 수 있을 것이다.

단기적으로는, 재건축부담금은 실질적으로 조세로서 양도소득세의 예납적인 성격이 강하기 때문에 이중과세의 문제점을 제거하기 위해서는 양도소득세액에서 재건축부담금 등을 세액공제하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

장기적으로는, 재건축부담금은 폐지하는 것이 바람직하다고 할 것이다. 왜냐하면, 재건축부담금은 특별부담금의 부과를 위한 합헌성 요건으로서 집단적 동질성, 집단적 효용성, 객관적 근접성, 집단적 책임성의 요건을 갖추지 못하고 있기 때문에 납부의무자들의 평등권을 침해하여 위헌의 소지가 크다고 할 것이다. 또한 과잉금지의 원칙에도 위배될 소지가 매우 크다고 할 것이다.<sup>197)198)</sup> 따라서 장기적으로는 재건축부담금은 폐지하여 양도소득세와의 이중과세(Double Taxation)의 문제를 근본적으로 해결하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

## 제5절 조합원입주권의 양도와 장기보유특별공제의 적용여부

### 1. 장기보유특별공제제도의 의의 및 취지

장기보유특별공제는 토지 또는 건물로서 보유기간이 3년 이상인 경우에 한하여 적용하되, 1세대 3주택 이상에 해당하는 주택,

197) 同旨; 김성수, “재건축부담금에 대한 헌법적 검토”, 「토지공법연구」 제31집, 한국토지공법학회, 2006.5, pp.44-48; 성소미, “재건축 개발이익환수에 관한 법적 쟁점”, 「토지공법연구」 제31집, 한국토지공법학회, 2006.5, pp.23-24.

198) 재건축부담금의 문제점에 대한 보다 구체적인 내용은 (양은열, “재개발·재건축 규제와 재산권 보장에 관한 법적 연구”, 서울시립대학교 대학원 박사학위논문, 2009.2, pp.239-243)의 내용을 참조하기 바란다.

1세대가 주택과 조합원입주권을 보유한 경우로서 주택 수와 조합원입주권 수의 합이 3 이상인 경우의 그 주택, 1세대 2주택에 해당하는 주택, 1세대가 주택과 조합원입주권을 각각 1개씩 보유하고 있는 경우의 그 주택, 비사업용 토지 및 미등기양도자산의 경우에는 그 적용을 배제하고 있다<sup>199)</sup>.

장기보유특별공제제도를 둔 이유는 장기보유자산에 대하여 양도소득금액을 산정함에 있어서 일정액을 공제함으로써 평균과세를 도모하고, 건전한 부동산의 투자행태 내지는 보유행태를 유도하려고 하는 것이다. 즉, 양도소득세에 있어서 장기보유특별공제 제도는 1988년 양도소득세율의 누진화와 함께 장기 실현이득에 나타날 수 있는 동결효과를 완화하기 위하여 도입된 제도이다<sup>200)</sup>.

이러한 장기보유특별공제액은 그 성격상 보유기간에 따라 상이하게 결정되어야 하는데, 구체적으로 자산의 보유기간이 3년 이상인 것에 대하여 해당 자산의 양도차익에 보유기간별 공제율을 곱하여 계산한 금액으로 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 1세대 1주택(이에 부수되는 토지를 포함한다)에 해당하는 자산의 경우에는 해당 자산의 양도차익에 보유기간별 공제율을 곱하여 계산한 금액을 말한다<sup>201)</sup>.

## 2. 조합원입주권에 대한 장기보유특별공제제도의 적용여부

현행 소득세법상 장기보유특별공제는 부동산에 한정하고 있기 때문에 부동산을 취득할 수 있는 권리로 보고 있는 조합원입주권의 경우에는 원칙적으로 장기보유특별공제의 적용대상이 되지 아

199) 소득세법 제95조 제2항.

200) 송진영·정지선, “양도소득세 과세표준 산정방법과 세율구조에 관한 연구”, 『세무학연구』 제25권 제4호, 한국세무학회, 2008.12, p.96.

201) 구체적인 공제율은 소득세법 제95조 제2항에 규정되어 있다.

니한다.

이 경우 문제되는 것은 조합원입주권이 주택으로 의제되는 경우에 장기보유특별공제의 적용에 있어서도 주택으로 보아 장기보유특별공제를 적용할 수 있는지의 여부가 문제이다.

이에 대하여 장기보유특별공제의 적용을 부인하는 견해가 있다. 즉, 조합원입주권에 대하여도 1세대 1주택 비과세 혜택을 줄 수 있는가에 대한 대법원 판례와 기존 과세실무와의 차이를 해소하기 위해서 일정한 요건을 정하여 1세대 1주택 비과세 혜택을 주겠다는 것이지, 관리처분계획의 인가일 당시 1세대 1주택의 요건을 갖춘 경우 모든 면에서 주택으로 의제하겠다는 취지까지는 아니기 때문에 장기보유특별공제를 적용할 수 없다고 한다. 부연하면, 오히려 세법상 조세감면에 관한 규정은 엄격하게 해석하여야 하고, 소득세법상 장기보유특별공제제도가 인플레이션으로 인한 자산소득 증가분을 보정하는 제도를 완전히 대체할 수 있는 제도는 아니라는 것을 생각할 때, 조합원입주권에 대하여도 장기보유특별공제를 인정하는 것은 타당하지 않다고 한다<sup>202)</sup>.

이에 대하여 판례는 장기보유특별공제의 적용을 긍정하고 있다. 즉, 재건축조합의 조합원이 기존주택과 토지를 재건축조합에 제공하고 당해 조합을 통하여 취득한 분양권을 양도하는 경우 위 시행령 제154조 제1항 소정의 1세대 1주택 비과세 요건을 갖춘 때에는 그 분양권은 위 시행령 제155조 제16항이 정하는 바에 따라 ‘주택’으로 의제되는바, 다만 그 양도 당시 실지거래가액이 6억 원을 초과하는 고가주택에 해당하기 때문에 양도소득세가 부과되는 경우에는 장기보유특별공제를 받을 수 있다. 그리고 장기보유특별공제가 적용되기 위한 보유기간은 기존주택의 취득일로부터 분양

202) 한정훈, “재개발·재건축사업에 있어 양도소득세와 관련된 쟁점에 관한 연구”, 「재판자료」 제115집, 법원도서관, 2008.6, p.545.



권의 양도일까지로 계산하여야 하고, 나아가 기존주택과 분양권에 의하여 새로이 취득할 분양주택의 면적이 서로 상이한 경우에는 장기보유특별공제액 산정의 기준이 되는 ‘기준면적 미만의 고가주택’의 판정은 기존주택의 면적이 아닌 양도 당시 분양주택의 면적을 기준으로 한다<sup>203)</sup>고 하여 장기보유특별공제의 적용을 인정하고 있는 것이다.

생각건대, 조합원입주권은 부동산을 취득할 수 있는 권리에 해당하여 주택에 대한 장기보유특별공제 규정이 적용되지 아니함이 원칙이지만, 구법 시행령 제155조 제16항의 요건을 충족하여 1세대 1주택으로 의제되고, 고가주택에 해당함에 따라 양도소득세를 과세하는 경우에는 주택의 양도와 마찬가지로 장기보유특별공제가 허용된다고 보는 것이 타당할 것이다<sup>204)</sup>. 또한, 조합원입주권에 대하여 1세대 1주택 비과세 규정을 적용하는 이유는 형식적으로는 부동산을 이용할 수 있는 권리이지만, 실질적으로는 주택에 해당하기 때문이라고 할 것이다. 따라서, 주택으로 보는 경우에는 장기보유특별공제의 적용에 있어서도 주택과 동일하게 이를 적용하는 것이 타당하다고 할 것이다. 만약에 장기보유특별공제를 적용하지 않게 되면, 결과적으로 조세평등주의에 위배되기 때문에 부당하다고 할 것이다.

## 제6절 양도소득세 중과세의 문제점과 개선방안

### 1. 양도소득세 중과세율제도의 문제점

203) 대법원 2007.6.14선고, 2006두16854 판결.

204) 조성권, “재건축조합의 조합원이 1세대 1주택 비과세 요건을 갖춘 고가주택에 해당하는 분양권을 양도함에 있어 기존주택과 분양주택의 면적이 서로 상이한 경우, 양도소득세액을 산정함에 있어 장기보유특별공제액은 주택면적과 보유기간을 분양주택을 기준으로 할 것인지 여부”, 「대법원 판례해설」 제69호, 법원도서관, 2007.12, p.249.

현재 우리나라의 소득세법에서는 1세대 2주택·조합원입주권 이상의 주택의 양도에 대하여는 장기보유특별공제의 적용을 배제하고 있을 뿐만 아니라, 50% 또는 60%의 단일비례세율로 중과세하고 있는데, 이러한 중과세는 자의적인 차별에 해당할 소지가 있다.

한편, 둘 이상의 조합원입주권만 보유한 경우에도 다주택자로서 중과세의 대상이 되는지의 여부가 문제가 될 수 있다. 그러나, 이 경우에는 주택이 아니라 부동산을 취득할 수 있는 권리를 보유하고 있는 것이므로, 중과세의 적용대상이 되는 것은 아니라고 보아야 할 것이다.

이와 같은 조합원입주권에 대한 중과세 규정은 다음과 같은 문제점이 있는 것이다<sup>205)</sup>.

첫째, 현행 양도소득세제가 과세대상자산을 부동산과 부동산에 관한 권리로 구분하여 과세표준의 산정 및 세율구분 등을 달리 규정하고 있으면서도 부동산에 관한 권리에 해당하는 조합원입주권만을 주택의 양도에 따른 소득세를 과세함에 있어서 주택수에 포함시킴으로써 사실상 주택으로 간주하는 것은 의제적이며, 부동산 투기억제라는 특정한 정책목적을 위한 행정편의주의적인 입법이라고 할 것이다.

둘째, 조합원입주권과 일반 분양권은 다 같이 완성된 주택을 받을 권리라는 점에서 동일한 성격임에도 불구하고 조합원입주권 또는 일반분양권 자체를 양도할 경우에는 동일하게 부동산에 관한 권리로 취급하면서 조합원입주권과 주택을 함께 보유한 자가 주택을 처분할 경우에만 조합원입주권을 주택수 산정에 포함시킴으로써 조합원입주권과 일반분양권을 차별 취급하는 것은 법적·

205) 김완석, “재건축에 대한 조세법적 검토”, 「토지공법연구」 제33집, 한국토지공법학회, 2006.11, pp.70-71.

논리적 정합성 측면에서 문제가 있으며, 바람직한 입법형식이라고 할 수 없다.

셋째, 조합원입주권에 대한 중과세의 필요성이 인정된다 하더라도 적용시에 예상되는 실수요자 등 선의의 피해자를 최소화하기 위해서 광점위한 예외규정의 운용이 필요하며, 이로 인하여 집행 과정에서 과세형평성, 조세저항 및 관련 조세소송의 급증 등 제도 운용의 기회비용이 과다하게 소요될 우려가 있다.

넷째, 양도소득세의 경우 특례세율로써 1세대3주택 이상에 대해서는 장기보유특별공제를 인정하지 않으면서 66%(소득할주민세 포함)의 비례세율로 과세하며, 토지·건물로서 보유기간 1년 미만의 것과 1세대2주택의 경우 역시 장기보유특별공제를 인정하지 않으면서 55%(소득할주민세 포함)의 징벌적 과세를 하고 있다. 이러한 경우 기본세율에 의해 산정한 세액을 초과하는 부담은 담세능력과 무관하기 때문에 사실상 처벌적 벌금과 다름 아닌 것이다. 특히 1세대2주택과 1세대3주택에 대한 징벌적 과세가 문제이다. 이를 참여정부가 부동산투기억제대책을 발표한 후에 새로 취득한 2 내지 3주택에 대해 투기억제를 위해 중과세를 한다고 하더라도 부담의 형평성과 담세능력의 관점에서는 문제가 있는데, 그 이전부터 적법하고 국가시책에 위반함이 없이 취득해 보유하고 있던 것까지 싸잡아 징벌적 과세를 하는 것은 실질적으로 소급과세와 같다<sup>206)</sup>.

여덟 번째, 1세대 2주택 이상 보유하는 세대가 양도하는 주택의 양도소득에 대한 중과세조치는 과세의 형평성을 침해하여 조세평등주의에 위반되는 문제점이 있다. 즉, 규모가 큰 상업용 건물 등과 같이 다액의 양도차익이 발생하는 자산의 양도에 대하여는 그

206) 송진영·정지선, “양도소득세 과세표준 산정방법과 세율구조에 관한 연구”, 「세무학연구」 제25권 제4호, 한국세무학회, 2008.12, p.101.

양도소득금액을 산정함에 있어서 장기보유특별공제를 적용하며, 일반적인 세율에 의하여 양도소득세를 과세하면서 유독 1세대 3주택 이상의 주택의 양도소득에 대하여 높은 세율 등에 의하여 중과세하는 것은 자의적인 차별에 해당할 소지가 있다. 또한 1세대 3주택 이상에 해당하는 주택의 양도소득에 대한 높은 소득세율은 부동산 이외의 다른 자산의 소득세율 등에 비교하여 지나치게 높은 문제점이 있다<sup>207)</sup>.

마지막으로, 노후·불량한 주거 밀집지역의 주택을 개량·건설하고 도로 등 공공시설을 정비하는 재개발과 노후화되고 불량화된 주택을 새로이 짓는 재건축은 당연히 이루어져야 하는 사업임에도 불구하고 아파트 가격 폭등을 동반한 집값 불안정의 주원인처럼 취급되고 있지만, 아파트 가격의 실질적인 불안정 요인은 주택공급 정책의 부재, 정부의 일관성 없는 정책 및 무리한 정책 등의 남발이 주요한 원인이라고 보는 것이 타당할 것이다<sup>208)</sup>.

## 2. 양도소득세 중과세율제도의 개선방안

국민의 주거수준 향상에 대한 욕구는 기본권 측면에서 행복추구권 내지 인간다운 생활을 할 권리로 인식되고 있을 뿐만 아니라, 현행 헌법 제35조 제3항에는 국가는 주택개발정책 등을 통하여 모든 국민이 쾌적한 주거생활을 할 수 있도록 노력하여야 한다고 국가의 의무사항으로 규정하고 있다. 그러한 측면에서 보면 주택재건축은 헌법에 규정된 국가차원의 지원대상이요 규제대상이 될 수 없다. 주택재건축사업 또는 다른 어떤 방법을 통하든

207) 김완석, “주택세제 관련 법제, 정책·입법 평가”, 『토지공법연구』 제35집, 한국토지공법학회, 2007.2, pp.111-112.

208) 양은열, “재개발·재건축 규제와 재산권 보장에 관한 법적 연구”, 서울시립대학교 대학원 박사학위논문, 2009.2, p.1.

국민들의 주거문화수준 향상을 위한 행위는 막을 수도 없고, 막아서도 안되는 일이라고 할 것이다<sup>209)</sup>.

이러한 관점에서 현행 소득세 세율구조는 기본적으로 너무 높게 설정되어 있다. 즉, 다주택 보유자 등에 대한 중과세제도는 여러 가지 면에서 위헌의 소지를 안고 있기 때문에 이러한 자산에 대한 중과세율제도는 폐지하는 방향으로 개선이 이루어져야 할 것이다.

즉, 양도소득세의 경우에는 기본적으로 중과세율제도는 폐지하고, 모든 자산에 대하여 초과누진세율구조로 변경하는 것이 타당할 것이다.

---

209) 김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2, pp.9-10.

## 제6장 소득세와 법인세 및 부가가치세의 과세문제

### 제1절 소득세 과세의 문제점과 개선방안

#### 1. 소득세의 일반

소득세는 개인의 소득을 그 과세물건으로 하고 있다. 그러나, 소득세의 과세물건이 소득이라고 하여 실정 세법에서 모든 소득을 과세물건으로 하고 있지는 않다. 즉, 과세소득을 규정하는 방식에는 포괄주의와 열거주의가 있는데, 우리나라의 경우에는 기본적으로 열거주의를 채택하고 있기 때문에 과세대상이 되는 소득을 소득세법에서 규정하고 있다. 따라서 개인에게 경제적인 이익이 귀속되었다고 하더라도, 소득세법에서 과세소득으로 열거되어 있지 아니한 경우에는 소득세를 부과할 수 없는 것이다.

한편, 소득세법은 개인에게 귀속한 모든 소득에 대하여 그 소득의 발생원천에 관계없이 획일적인 방법에 의하여 종합과세하는 것이 아니라 소득의 구분에 따른 질적 담세력의 차이를 인정하여 차별과세하도록 하고 있다. 소득세법에서는 소득세의 과세대상이 되는 소득을 소득의 발생원천에 따라서 이자·배당·부동산임대·사업·근로·연금·기타·퇴직소득 및 양도소득으로 구별하여 당해 원천별 소득에 포함될 내용을 한정적으로 열거하고 있다<sup>210)</sup>.

즉, 현행 소득세법에 있어서는 당해 소득이 어느 소득으로 되는지에 따라서 필요경비의 인정여부 등에 의하여 소득세의 부담이

---

210) 김완석, 「소득세법론」, (주)광교이텍스, 2009, pp.167-168.

달라지게 되는 것이다.

## 2. 재건축 관련 소득세 과세의 문제점과 개선방안

주택재건축정비사업조합이 일반분양 수입금액에서 당해 공사가  
가 등을 제외한 개발이익금 상당액을 각 조합원들에게 지분비율  
에 따라서 배분하여 각 조합원이 부담하여야 할 건축비에 충당하  
는 경우에 각 조합원이 획득한 것이 소득세의 과세대상에 해당하  
는지의 여부가 문제이다.

이에 대하여 판례는 배당소득에 해당한다고 보고 있다. 즉, 주  
택건설촉진법상의 주택조합 사업은 통상 조합원 개개인이 자기의  
토지나 주택을 출자하고, 조합은 조합원에게 1세대씩 분양할 아파  
트 외에 여분의 아파트와 상가 등을 건축하여 일반분양하고, 그  
대금으로 건축비를 일부 충당함으로써 각 조합원이 부담할 건축  
비를 경감하는 방식으로 이루어지는 사실, 이 사건 주택조합은 조  
합원들로부터 대지와 점포 등을 출자받아 18층 아파트 1동 108세  
대를 재건축하여 조합원들에게 우선분양하고 남은 아파트는 일반  
분양하였으며, 그로 인한 수입금을 각 조합원들에게 지분비율에  
따라 배분하여 각 조합원이 납부할 건축비에 충당한 사실을 알  
수 있으나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 주택조합이 국세기본법상  
법인으로 보는 법인격이 없는 단체로서 법인세법상 비영리내국법  
인에 해당하는 이상 이 사건 주택조합이 주체가 되어 제3자에게  
재건축한 아파트를 일반분양하고 얻은 소득은, 그 소득이 구성원  
에게 분배되는 경우 구성원에게 배당소득세가 부과됨은 별론으로  
하고, 우선 비영리법인의 사업소득이 되어 법인세 부과대상이 되  
는 것이므로, 이 사건 주택조합에게 이 사건 일반분양으로 인한  
소득에 대하여 법인세를 부과하는 것이 실질과세의 원칙에 어긋

난다고 할 수는 없다. 같은 취지에서 원심이, 원고들이 이 사건 재건축주택의 일반분양으로 얻은 소득이 소득세법 제17조 제1항 제2호 소정의 '법인으로 보는 단체로부터 받은 배당 또는 분배금'으로서 배당소득에 해당될 여지가 있으나 피고가 원고들의 이 사건 소득금액이 이 사건 주택조합으로부터 받은 배당소득에 해당함을 주장·입증하고 그 처분사유를 변경한 바 없으므로, 이 사건에서 법원이 원고들에 대한 종합소득세 부과가 실질과세의 원칙에 부합하는 것으로서 정당하다고 판단할 수는 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 실질과세의 원칙에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다고 판시하여<sup>211)</sup>, 배당소득에 해당한다고 보고 있는 것이다.

그런데, 이와 같이 각 조합원이 획득한 소득에 대하여 배당소득으로 해석하게 되면, 양도소득세와 중복과세되는 결과를 초래하게 되어 불합리하게 된다. 왜냐하면, 조합원용 주택건축비 총당액은 당초 조합원 소유대지의 일부 양도에 해당되는 감보와 용적률 증가 등을 통하여 가능할 일반분양 주택의 분양이익으로 구성되며, 이는 결과적으로 구 주택이 신 주택으로 대체되는 과정에서 발생한 조합원의 재산의 가치 상승분이다. 이러한 가치 상승분은 미실현이익으로 남게 되며, 향후 조합원이 신축 주택을 양도할 때에 양도소득세로 과세되기 때문이다<sup>212)</sup>.

이러한 문제점을 제거하기 위해서는 현재와 같이 배당소득세로 과세하고, 양도소득세의 과세시에 세액공제하는 방법과 배당소득세를 과세하지 않는 방법을 고려할 수 있다. 이 경우에 세액공제 방법을 채택하게 되면 추가적인 조세수입은 발생하지 않고, 과세

211) 대법원 2005.6.10선고, 2003두2656 판결.

212) 김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2, p.120.



상 불편만을 초래하게 된다. 따라서 배당소득으로 보지 않고, 소득세를 과세하지 않는 것이 타당할 것이다.

## 제2절 법인세 과세의 문제점과 개선방안

### 1. 법인세 과세의 일반

법인세는 법인의 소득에 대하여 부과하는 조세이다. 이 경우 법인은 내국법인과 외국법인 및 영리법인과 비영리법인으로 구분하여 그 납세의무의 범위에 대하여 차등을 두고 있다. 먼저, 내국법인의 경우에는 국내외를 묻지 않고 전세계소득에 대하여 법인세를 과세하며, 외국법인의 경우에는 국내원천소득에 한하여 법인세의 납세의무를 부담한다.

법인세는 순자산증가설의 입장에서 익금의 총액에서 손금의 총액을 차감하여 각사업연도의 소득금액을 계산하는데, 비영리법인의 경우에는 수익사업에서 발생하는 소득금액에 한하여 법인세를 과세한다.

### 2. 재개발·재건축조합에 대한 법인세 과세의 문제점과 개선방안

#### 가. 현행 세법상 규정

법인세법은 기본적으로 조합원에게 분양한 것은 비수익사업으로 보고, 조합원 이외의 자에게 분양한 것에 대하여 수익사업으로 보아 법인세를 과세하고 있다. 즉, 도시및주거환경정비법 제18조에 따라 설립된 조합(전환정비사업조합을 포함하며, 이하 “정비

사업조합”이라 한다)에 대하여는 법인세법 제1조에 불구하고 2010년 12월 31일 이전에 끝나는 사업연도까지는 비영리내국법인으로 보아 법인세법(같은 법 제29조는 제외한다)을 적용한다<sup>213)</sup>.

따라서 조합원에 대한 분양수입은 수익사업에서 제외하고, 일반 분양분과 상가분양분은 수익사업으로 보아 법인세를 과세하는 것이다.

또한, 조세특례제한법 제104조의 7 제2항의 규정을 적용함에 있어서 정비사업조합이 도시및주거환경정비법에 의하여 당해 정비사업에 관한 관리처분계획에 따라 조합원에게 종전의 토지를 대신하여 토지 및 건축물을 공급하는 사업은 법인세법 제3조 제2항의 규정에 의한 수익사업이 아닌 것으로 본다<sup>214)</sup>.

한편, 주택재건축정비사업조합은 비영리법인으로 보기 때문에 청산절차가 없다. 따라서 청산소득에 대한 법인세 납세의무는 없는 것으로 보아야 할 것이다.

## 나. 현행 규정의 문제점과 개선방안

### (1) 근본적인 개선방안

이와 같이 현행 세법은 정비사업조합을 비영리법인으로 보아 수익사업에 대하여 법인세를 과세하고 있는데, 실질적으로 보면, 일반분양에서 발생된 소득의 경우에도 조합원용 주택건축비에 충당되기 때문에 계산상의 각 사업연도 소득금액은 담세력이 수반되지 않는 수치에 불과하므로, 법인세를 과세하는 것이 타당한지의 여부가 문제된다. 즉, 법인세를 부담하는 각 사업연도소득은

213) 조세특례제한법 제104조의 7 제2항.

214) 조세특례제한법 시행령 제104조의 4.

수익사업부분을 과세하기 위한 계산상 수치에 불과하고, 실질적으로는 이미 조합원들의 자산가치 증가로 이전되었다. 향후 조합원들이 보유 부동산을 양도하는 경우 그 증가된 금액은 양도소득세의 과세대상이 되고, 한편으로는 앞서도 살펴보았듯이 이에 대하여 재건축부담금도 부과된다. 이와 같이 현재의 과세제도에 의하면 주택재건축정비사업조합의 법인세 과세표준 중에서 수익사업에서 전입되어 조합원용 주택 건축비에 충당한 금액 만큼은 양도소득세와 재건축부담금의 중복적인 과세대상이 되는 것이다<sup>215)</sup>.

또한, 주택재개발 또는 재건축사업은 실질적으로 조합원들의 공동사업과 동일하고, 조합은 그 기구에 불과한 것으로서 구 도시재개발법 및 현행 도시및주거환경정비법에서 조합의 법인격을 규정한 취지는 조합원들의 공동사업으로 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 여러 가지 번거로움을 고려하여 좀 더 간편하고 원활하게 사업을 수행할 수 있도록 함과 동시에 설립인가, 정관, 임원, 총회 등 절차 통제로 사업을 적절히 감독할 수 있도록 하자는 일종의 편의적·형식적인 개념으로 이해할 수 있을 것이다<sup>216)</sup>.

그리고, 근본적으로 조합은 그 업무의 원활한 추진을 위하여 존재하는 기구에 불과하기 때문에 조세특례제한법 제104조의 7 제2항은 지속적으로 법 개정의 형식을 통하여 비영리법인으로 의제될 것으로 보인다. 이는 결과적으로 조세법을 복잡하게 하는 문제가 있기 때문에 이러한 문제점을 해소하기 위해서라도 법인세를 과세하는 규정의 개선이 필요하다고 할 것이다.

이러한 문제점을 해소하는 방법으로는 도시및주거환경정비법 제18조 제1항에서 조합은 비영리법인으로 한다라고 규정하고, 감

215) 김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2, pp.117-119.

216) 同旨; 홍성욱, “주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 2006.2, p.21.

독점차 등을 강화하는 방안을 생각할 수 있다<sup>217)</sup>. 그러나, 위에서 살펴본 바와 같이 정비사업조합은 실질적으로 조합원들의 공동사업과 동일하기 때문에 세법에서 조합으로 의제하여 법인세를 과세하지 않고, 소득세법상 양도소득세로 과세하는 것이 타당할 것이다. 이와 같이 법인세를 과세하지 않으면 정비사업조합에 대한 조세특례제한법상 규정도 불필요하기 때문에 조세법을 단순하게 할 뿐만 아니라 뒤의 해석상 논란도 발생하지 않을 것이다.

## (2) 현행 규정상의 문제점과 개선방안

### 1) 조세특례제한법 시행령 제104조의 4의 해석론

정비사업조합이 정비사업에 관한 공사를 완료한 후에 그 관리처분계획에 따라 조합원에게 공급하는 것으로서 종전의 토지를 대신하여 공급하는 토지 및 건축물의 범위에 관하여 해석상 다툼이 제기되고 있다. 즉, 종전의 토지를 대신하여 공급하는 토지 및 건축물의 범위에 관하여 정비사업조합이 관리처분계획에 따라 조합원에게 공급하는 공동주택 및 그 부수토지 가격의 전액이라는 견해, 조합원이 정비사업조합에 출자한 토지와 건축물 가격의 범위안의 금액이라는 견해, 조합원이 정비사업조합에 출자한 토지 가격의 범위 안의 금액이라는 견해의 대립을 생각해 볼 수 있다.

범문대로 엄격하게 해석한다면 조합원이 정비사업조합에 출자한 토지 가격의 범위 안에서만 수익사업으로 보아서는 안된다고 해석하여야 할 것이다. 그런데, 정비사업조합이 조합원에게 공급하는 공동주택에 대하여 조합원이 정비사업조합에 출자한 토지 가격의 범위 안에서만 수익사업으로 보지 않는다는 조세특례제한법

217) 홍성욱, “주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 2006.2, p.93.

시행령 제104조의 4의 규정은 합리성을 결여하고 있다. 그 전부를 수익사업으로 보지 않거나 그 전부를 수익사업으로 보도록 규정하는 것이 법리에 부합하기 때문이다. 입법상의 불비로 보여진다.

조합원이 출자하는 토지와 건축물의 가액, 조합원이 조합에 추가로 납부하는 청산금, 정비사업비와 정비사업의 시행과정에서 발생한 수입의 차액을 보전하기 위하여 조합에 납부하는 부과금은 조합원의 출자금으로 새기고자 한다.

이 경우에 조합원이 정비사업조합에 출자하는 토지와 건축물의 가액은 도시및주거환경정비법에 의한 관리처분계획에 의하여 정하여진 가액에 의하여야 한다<sup>218)</sup>.

## 2) 주식 등 변동상황 명세서의 제출의무

정비사업조합은 법인세법상 비영리법인으로 의제되면 조합원이 종전 부동산을 조합에 출자하고 출자지분을 취득하게 된다. 또한 조합원 출자지분(조합원입주권)은 수시로 양도가 이루어지므로 출자지분의 변동이 빈번하게 발생한다. 법인세법 제119조에 법인이 주식 등 변동상황이 있는 경우에는 주식 등 변동상황 명세서를 제출하도록 규정하고 있으며 예외적으로 제출실익이 없는 조합원과 소액주주 등에 대하여는 제출제외 대상으로 제한적으로 열거 규정하고 있다. 그러나, 정비사업조합의 경우 제출 제외 대상으로 열거되어 있지 않으므로 주식 변동상황 명세서를 제출하여야 한다. 그렇지만, 정비사업조합의 경우 출자지분의 가액이 매우 크고 조합원 수가 많으며 수시로 변동되므로 실무상 주식 변동상황 명세서를 작성하기가 매우 어렵다. 또한 주식 등 변동상황 명세서를 제출하도록 한 입법취지가 주식변동에 따른 양도소득세 등 과세

218) 김완석, “재건축에 대한 조세법적 검토”, 「토지공법연구」 제33집, 한국토지공법학회, 2006.11, p.49.

자료로 활용할 목적이 있음을 고려하여 보면, 조합원입주권 양도 자료는 주식변동상황 명세서를 제출하지 않아도 쉽게 과세자료의 확보가 가능하므로 제출의 실익이 없다고 보여진다. 따라서 정비사업조합도 주식 변동상황 명세서 제출 제외 범인으로 규정하는 입법적 보완이 필요하다. 즉, 도시및주거환경정비법에 의한 재건축·재개발 정비사업조합의 조합원의 출자지분변동에 대한 주식 등 변동상황 명세서는 다른 제도적 장치에 의하여 과세관청이 쉽게 파악 가능하므로 법인세법 시행령 제1조 조합법인 등의 범위에 포함시켜 제출제외 대상으로 하여야 한다<sup>219)</sup>.

### 제3절 부가가치세 과세의 문제점과 개선방안

#### 1. 토지와 주택의 공급에 대한 부가가치세 과세의 일반

부가가치세는 재화 또는 용역이 생산·제공되거나 유통되는 모든 단계에서 창출된 부가가치를 과세표준으로 하여 과세하는 조세이다. 이러한 부가가치세는 당해 조세의 부담을 거래상대방에게 전가시켜서 종국적으로는 최종소비자가 그 부담을 지도록 한다는 점에서 일반소비세에 해당한다.

이러한 부가가치세의 납세의무자는 영리목적의 유무에 불구하고 사업상 독립적으로 재화 또는 용역을 공급하는 자이다.

부가가치세는 모든 재화 또는 용역의 공급에 대하여 과세하는 일반소비세이기 때문에 법에 영세율 또는 면세대상으로 규정되어 있지 아니하는 한 예외 없이 부가가치세가 과세된다.

이 경우 토지는 생산요소로서 그 자체가 부가가치의 창출요소

219) 이진오·김완일·이강오, 「납세협력비용 감축방안에 관한 연구」, 한국조세연구포럼, 2008.11, pp.102-103.

이기 때문에 그 공급은 면세대상이다. 여기에는 토지매매업자가 공급하는 토지뿐 아니라 과세사업자가 토지만을 공급하거나 과세 재화 또는 용역에 부수하여 토지를 공급하는 경우에도 토지의 공급부분은 면세한다<sup>220)</sup>. 그러나, 토지의 임대는 원칙적으로 과세대상이다.

한편, 주택의 공급은 원칙적으로 부가가치세의 과세대상에 해당한다. 다만, 국민주택규모 이하의 주택의 공급에 대하여 부가가치세를 면세한다.

## 2. 조합원에 대한 주택의 공급의 부가가치세 과세의 문제점과 개선방안

부가가치세에 있어서는 주택재개발조합 또는 주택재건축조합이 조합원에게 주택을 분양하는 경우 부가가치세의 과세대상에 해당하는지에 대한 문제이다. 즉, 조합이 조합원 이외의 자에게 주택을 분양하는 경우에는 부가가치세의 과세대상이 되는 것이지만, 조합원에게 분양하는 것이 부가가치세의 과세대상에 해당하는지의 여부가 문제인 것이다. 부연하면, 조합의 일반분양분은 조합원 이외의 자에게 보류지 및 체비지에 해당하는 상가나 주택을 분양하는 것으로서, 토지와 건물을 분양계약에 의하여 유상으로 매매하는 것이므로 재화의 공급에 해당하여 부가가치세가 과세된다. 다만, 일반분양 주택 중에서 국민주택의 공급은 면세대상이다.

이하에서는 이러한 내용에 대하여 학설과 판례의 입장을 살펴보고, 결론을 맺고자 한다.

220) 임승준, 「조세법」, 박영사, 2006, p.873.

## 가. 학설

### (1) 긍정설

정비사업조합이 조합원에게 주택을 분양하는 것은 부가가치세의 과세대상이 된다는 견해인데, 그 근거는 다음과 같다.

첫째, 조합원은 주택재개발을 계기로 자신의 부동산을 내어 놓고 다시 부동산을 받게 되는데, 주택재개발조합이 조합원과 구별되는 법인의 형태로 있다면 이를 부가가치세법상 납세의무자의 지위를 인정할 필요가 있다는 것이다. 즉, 조합원의 입장에서 보면 경제적으로 자신의 부동산을 자신이 찾아가는 것으로 볼 수 있지만, 동일한 부동산을 되돌려 받는 것은 아니고 가치가 증가된 또는 다른 부동산을 받는다는 점에서 주택재개발조합이 조합원에게 하는 주택분양은 부가가치세법상 과세대상이 되는 재화의 공급으로 보아야 한다고 한다<sup>221)</sup>.

둘째, 부가가치세법상 사업자인 정비사업조합이 부가가치세의 과세대상이 되는 공동주택을 공급하는 경우에는 부가가치세법 제6조의 규정에 의한 재화의 공급에 해당한다고 한다. 즉, 정비사업조합이 그 조합원에게 공급하는 공동주택에 대하여 부가가치세를 면세한다는 규정을 두고 있지 않는 한 부가가치세의 과세대상이 된다고 새겨야 한다는 것이다<sup>222)</sup>.

둘째, 주택재개발조합·재건축조합이 조합원에게 주택을 분양하는 것의 성격을 매매라고 한다. 주택의 분양과 관련하여 조합원에게 제공되는 것은 우선분양을 신청할 수 있는 권리에 지나지 않

221) 박훈, “재개발조합의 과세문제”, 「조세와 법」 제1권 제2호, 서울시립대학교 법학연구소·지방세연구소, 2008.12, p.219.

222) 김완석, “재건축에 대한 조세법적 검토”, 「토지공법연구」 제33집, 한국토지공법학회, 2006.11, p.50.



는데, 우선분양권을 지닌 조합원이 이를 행사하여 주택 분양을 신청할 경우 조합과 조합원간에는 분양계약서가 작성되어 매매계약이 성립되는데, 편의를 위해서 분양대금만을 출자금과 상계할 뿐이라고 한다. 설사 조합원에 대한 분양이 출자의 반환에 해당하더라도 현물로서 출자를 반환하는 것은 원칙적으로 재화의 공급에 해당한다고 한다<sup>223)</sup>.

## (2) 부정설

주택재개발조합이 조합원에게 주택을 분양하는 것은 부가가치세의 과세대상이 되지 아니한다는 견해인데, 그 근거는 다음과 같다.

첫째, 일반적으로 조합은 조합원을 위하여 신탁재산을 개발·관리·처분하여야 하고, 수탁자가 신탁받은 토지상에 주택을 신축하는 등의 개발행위를 하여 창출한 신축건물 등은 바로 신탁재산으로 되는 것이며, 그 신탁재산의 개발 등으로 발생한 이익과 비용은 최종적으로 조합원에게 귀속하게 되는 것이므로, 경제적 실질면에서 보면 이는 조합원의 계산에 의한 것이기 때문에 재화의 공급에 해당하지 아니한다고 한다<sup>224)</sup>.

둘째, 도시및주거환경정비법 제55조가 조합원 분양을 환지로 보며 그에 따라 소득세법상 조합원 분양을 양도로 보지 않고 있으며, 재개발·재건축 사업의 실질상 조합이 신축건물을 취득하여 사업자로서 조합원에게 공급하는 것이 아니라 조합원들이 최종소비자의 지위에서 직접 취득한 것으로 볼 것이기 때문에 재화의

223) 민태욱, “주택재개발·재건축조합의 조세법적 성격과 조세문제”, 「토지공법연구」 제20집, 한국토지공법학회, 2003.11, p.438; 김백영, 「조세판례연구」Ⅱ, 법률정보센터, 1993, p.344.

224) 조철호, “부동산신탁에 있어서 신탁부동산의 처분에 대한 부가가치세 납세의무자”, 「재판자료」 제108집, 법원도서관, 2005.12, p.389.

공급에 해당하지 아니한다고 한다. 또한 주택재개발·재건축사업에서 일반분양수입으로 공사비 등 총사업비를 충당하고 부족하여 조합원으로부터 분담금을 납부 받는 경우가 많은바, 이 부분에 상응하는 조합원 분양분에 대하여는 재화의 공급으로 볼 수 있는 것인지의 의문이 있을 수 있으나, 이러한 부분 역시 조합원이 최종소비자로서 자기 주택을 직접 취득한 것 또는 환지처분으로서 재화의 공급으로 볼 수 없다고 한다<sup>225)</sup>.

#### 나. 판례의 입장

우리나라 판례는 조합원들이 실질적인 최종 소비자의 지위에서 취득하는 것이라는 관점에서 재화의 공급이 아니라고 보고 있다. 즉, 주택개량을 위하여 조합원들이 스스로 결성한 주택개량재개발조합이 실시하는 재개발사업 중 조합원들에게 분양되는 주택에 관한 사업은 건축시부터 분양에 이르기까지 조합원들이 실질적인 최종 소비자의 지위에 있는 것이라고 하여야 할 것이고, 비록 조합원과 법률상 인격이 다른 조합이 그 공사비를 지급하였다거나 조합이 조합원들에게 주택을 분양하는 형식을 취하였더라도 조합이 조합원들에게 재화를 공급하였다고 볼 수는 없다고 판시하여<sup>226)</sup> 부가가치세의 과세대상에 해당하지 아니한다고 하고 있다.

#### 다. 결 어

현행 부가가치세법의 해석상 정비사업조합이 조합원에게 주택을 공급하는 것은 재화의 공급에 해당한다고 해석할 수 밖에 없

225) 홍성욱, “주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 2006.2, p.69.

226) 대법원 1990.6.22.선고, 90누509 판결.

다. 즉, 현행 부가가치세는 법에 면세대상으로 규정되어 있지 않는 경우에는 과세되는 일반소비세이기 때문에 정비사업조합이 조합원에게 공급하는 것도 재화의 공급에 해당한다고 보아야 할 것이다.

또한, 조세특례제한법에서는 도시및주거환경정비법 제18조에 따라 설립된 조합이 도시및주거환경정비법에 의하여 당해 정비사업에 관한 공사를 완료한 후에 그 관리처분계획에 따라 조합원에게 공급하는 것으로서 종전의 토지를 대신하여 공급하는 토지 및 건축물(당해 정비사업의 시행으로 건설된 것에 한한다)은 부가가치세법 제6조의 규정에 의한 재화의 공급으로 보지 아니한다고 규정하고 있는데<sup>227)228)</sup>, 이 규정은 기본적으로 조합원에 대한 분양이 부가가치세의 과세대상임을 전제로 하고 있는 것이다.

그러나, 실질적으로는 다음과 같은 근거로 재화의 공급에 해당한다고 보기 어렵다고 할 것이다.

첫째, 관리처분계획에 의하여 종전 토지 등의 소유자가 신축건물을 분양받은 경우 토지구획정리사업상 환지에 해당하기 때문에 부가가치세법상 재화의 공급에 해당하지 아니한다고 보아야 할 것이다.

둘째, 주택재개발사업의 경우 실질에 있어서 결국 토지 등의 소유자가 조합의 명의를 빌려 건물을 신축한 것이므로, 조합이 부가

227) 조세특례제한법 제104조의 7 제3항.

228) 이 규정 중에서 종전의 토지를 대신하여 공급하는 토지 및 건축물의 범위에 관하여 해석상 논란이 있다. 법문대로 엄격하게 해석한다면 주택재건축정비사업조합이 조합원에게 공급하는 정비사업 시행으로 건설된 토지 및 건축물은 공동주택이지만 그 공동주택 중 당초 출자한 토지가격 내에서만 재화의 공급에서 제외하고, 그 나머지 부분에는 과세한다고 해석될 수 있지만, 현실적으로 합리성을 결여한 입법이라고 할 것이다. 따라서 관리처분에 따라 조합원에게 공급되는 주택 전체에 대해서 부가가치세의 과세대상에서 제외하는 것이 타당할 것이다(김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2, p.131).

가치세법상 별도의 사업자의 지위에 있다고 볼 수 없기 때문에 조합과 조합원의 사이에 거래가 있다고 보기 힘들다고 할 것이다<sup>229)</sup>.

이와 같이 현행 부가가치세법상 재화의 공급에 해당한다고 볼 수밖에 없지만, 실질적으로는 재화의 공급으로 보기에 는 무리가 있다고 할 것이다. 따라서, 주택재개발조합 또는 주택재건축조합이 조합원에게 공급하는 것은 부가가치세의 과세대상에 해당하지 아니함을 부가가치세법에 명문으로 규정하는 것이 타당하다고 할 것이다. 즉, 재개발조합 등이 조합원에 공급하는 것을 부가가치세법상 면세대상으로 규정하는 입법적인 보완이 필요하다.

이와 같이 조합원에 대한 공급에 대하여 부가가치세법에서 면세대상으로 규정하게 되면, 앞의 조세특례제한법상의 규정은 불필요하기 때문에 삭제하여야 할 것이다.

229) 同旨; 홍성욱, “주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 2006.2, p.68.

## 제7장 취득세와 재산세의 과세문제

### 제1절 취득세의 과세에 있어서 문제점과 개선방안

#### 1. 취득세의 의의와 성격

취득세(Acquisition Tax)는 지방세 중에서 도세로서 부동산 등 취득세 과세물건을 취득하는 때에 성립하고, 당해 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득일로부터 30일 이내에 과세표준에 세율을 곱하여 산출한 세액을 과세물건 소재지를 관할하는 시장 또는 군수에게 신고하고 납부하여야 하는 신고납부 조세이다.

이러한 취득세의 성격을 어떻게 볼 것인지에 대하여는 형식설의 입장과 실질설의 입장이 대립한다. 우리나라의 통설과 판례<sup>230)</sup>는 취득세를 소유권이 이동하는 유통과정을 통하여 일어나는 취득이라는 행위에 대하여 과세하는 조세이므로, 행위세적인 성격을 지니고 있으며, 경제적인 측면에서는 유통세에 속한다고 하여 형식설의 입장에서 취득세의 성격을 파악하고 있다. 그러나, 다음과 같은 근거로 형식설이 아닌 실질설의 입장에서 취득세의 성격을 파악하여야 할 것이다<sup>231)</sup>.

첫째, 취득세를 판례의 견해와 같이 형식설의 입장에서 파악하게 되면 취득자가 완전한 내용의 소유권을 취득하는지의 여부와 관계없이 소유권이전의 형식만 있으면 취득세 납세의무가 발생하

230) 대법원 1984.11.27 선고, 84누52 판결; 대법원 1978.9.26. 선고 78누204 판결; 대법원 2002.6.28 선고, 2000두7896 판결 등.

231) 취득세의 성격에 대한 학설의 대립과 판례의 입장 등에 대한 구체적인 내용은 (정지선, “취득세의 합리적 개선방안에 관한 연구 -입법론을 중심으로-”, 서울시립대학교 세무대학원 박사학위 논문, 2006.8, pp.18-25)의 내용을 참조하기 바란다.

게 된다. 그러나, 이와 같이 보게 되면 앞에서 살펴본 바와 같이 조세법 전반을 지배하는 원칙 중 하나인 실질과세의 원칙에 반하게 된다. 따라서 취득세는 실질적으로 소유권이 이전된 경우에 과세되는 것으로 보아야 한다.

둘째, 현재 우리나라의 취득세는 형식적인 소유권의 취득이 없는 경우에도 실질적으로 취득한 경우에는 취득세의 과세대상에 해당한다. 거기에 더하여 경제적 처분권 없이 이루어진 소유권 취득은 담세력이 없기 때문에 취득의 본질에 어긋난다. 따라서 경제적 처분권 없이 이루어진 소유권의 취득은 당연히 취득세의 과세대상에 해당하지 않아야 할 것이다.

셋째, 판례는 취득세가 유통세이기 때문에 형식설의 입장에서 취득세의 성격을 파악하여야 한다고 하지만, 유통세라 하더라도 취득세 과세물건의 이전의 배후에 있는 담세력에 착안하여 과세하는 것이기 때문에 수수료적 성격이 강한 등록세와는 달리 법률상 소유권을 취득하였다고 하더라도, 당해 재산을 실질적으로 사용 또는 수익할 수 없다면 담세력이 없으므로 취득세를 과세할 근거가 없다고 보아야 할 것이다.

넷째, 형식설에 의할 경우에는 법률효과가 실질적으로 발생하지 아니하고 형식적으로 소유권의 이전이 되어 소유권자의 명의변경이 이루어진 경우에도 취득세를 과세하게 되어 납세자의 재산권을 부당하게 침해하는 결과를 초래하게 된다. 예를 들어 형식설에 의할 경우에는 명의신탁의 경우 명의는 비록 명의수탁자에게 이전되지만, 실질적인 소유권은 명의신탁자에게 있음에도 불구하고 취득세를 과세하게 되어 명의수탁자의 재산권이 부당하게 침해되는 것이다.

다섯째, 민법상으로는 부동산 등은 등기 또는 등록이라는 형식상의 소유권 이전만으로도 외관상 법적으로는 완전한 소유권의

취득으로 인정될 수 있지만, 지방세법상 취득의 개념은 담세력을 전제로 하기 때문에 실질적인 소유권 취득이 없는 형식상의 소유권 이전만을 기준으로 취득으로 보아서는 안된다.

이하에서는 주택재개발사업에 있어서 취득세 과세의 문제와 주택건축사업에 있어서 취득세 과세의 문제 및 주택건설업자가 분양용으로 취득한 공동주택에 대한 취득세 납세의무에 대하여 살펴보기로 한다.

## 2. 주택건설업자가 분양용으로 취득한 공동주택의 취득세 납세의무

주택건설업자가 분양용으로 취득한 공동주택의 경우에는 재개발 및 재건축과 직접적인 관련은 없다고 할 것이다. 그러나, 일반적으로 건설회사가 행하는 개발 또는 건축사업을 조합과 달리 취급하는 경우 조세중립성을 해치를 결과를 초래할 수 있는 문제점이 있다.

따라서, 주택건설업자가 분양용으로 취득한 공동주택의 경우 납세의무자가 누가 되는지에 대하여 살펴볼 필요가 있다. 즉, 주택건설업자가 공동주택을 신축하여 실수요자에게 분양하는 경우 주택건설업자의 공동주택의 원시취득에 대하여 취득세 납세의무가 있는지의 여부가 문제인 것이다.

이하에서는 주택건설업자가 분양으로 공동주택을 신축하는 경우 취득세 납세의무에 대하여 주택건설업자라는 견해와 분양받는 자라는 견해의 대립과 지방세법상의 규정에 대하여 살펴보고, 누구를 납세의무자로 하는 것이 타당한지의 여부에 대하여 살펴보기로 한다.

## 가. 납세의무자에 대한 학설

### (1) 주택건설업자라는 견해

공동주택사업자가 분양용으로 취득한 공동주택은 상품용 부동산에 해당하며, 공동주택이 상품용 부동산이라고 하더라도 사회통념상의 부동산에 해당되기 때문에 주택건설업자의 공동주택의 원시취득의 경우에는 공동주택사업자가 취득세 납세의무자가 된다는 견해이다<sup>232)</sup>. 즉, 공동주택인 건물은 주거용에 공여하는 과세대상물건으로서 지방세법상 과세대상인 건물은 용도에 불문하고 건물구조를 기준으로 과세대상여부를 판단하는 것이기 때문에 상품용 주택이라고 하더라도 부동산의 범위에 포함되어 공동주택사업자가 원시취득에 대하여 취득세 납세의무자가 되고, 분양받은 자는 승계취득자로서 취득세 납세의무를 부담한다는 것이다.

### (2) 분양받는 자라는 견해

이는 건축주가 건축과정에서 그 의사와 무관하게 소유권을 취득하게 되고 임시적·일시적으로 그 소유권을 보유하는 것이므로 그 소유권의 취득이 당해 소유권의 가치에 상응하는 수준의 담세력의 표출이라고 볼 수 없으며, 주택사업자의 원시취득에 대하여 그 주택사업자를 납세의무자로 하여 취득세를 부과하게 되면 그 부과된 취득세는 그 수분양자에게 전가되어 수분양자가 취득세를 이중부담하는 문제점이 발생하므로 주택건설업자의 원시취득은 취득세 납세의무가 없고, 분양자가 분양받을 때에 취득세 납세의무를 부담한다는 견해이다<sup>233)</sup>.

232) 전동훈, 「지방세실무해설」, (주)영화조세통람, 2003, p.488.



## 나. 지방세법상의 규정

지방세법상 취득세 납세의무의 규정은 예외적인 규정이 존재하는 경우를 제외하고는 등기 또는 등록이 이루어지는 모든 취득에 대하여 취득세 납세의무를 부담하는 것으로 되어 있다. 따라서 지방세법상으로는 주택건설업자의 주택의 신축에 따른 원시취득의 경우에도 취득세 납세의무를 부담하게 된다.

## 다. 결 어

다음과 같은 사유로 주택건설업자의 주택의 신축에 따른 원시취득은 취득에 대하여는 취득세 납세의무가 없고, 분양자가 분양받을 때에 취득세 납세의무를 부담하는 것으로 보아야 한다.

첫째, 주택건설업자의 주택의 신축에 따른 원시취득에 대하여 취득세를 과세하게 되면, 동일한 과세물건에 대하여 중복과세하는 결과를 초래하게 되어 부당하다. 즉 주택건설업자의 원시취득은 형식적인 취득으로서 실질적인 취득자는 실수요자인데, 주택건설업자에 대하여 과세하면 이중과세되는 결과를 초래하는 것이다.

둘째, 취득세는 일반적으로 그 취득자의 취득행위에 대하여 담세력을 인정하여 과세하는 세목이다. 그런데, 주택건설업자의 원시취득에 대하여 취득세를 과세하게 되면 당해 취득세는 주택의 원가를 구성하여 실수요자에게 전가되어 실수요자의 세부담이 그만큼 증가하게 되어 불합리한 결과를 초래하게 된다. 즉 건설업자의 원시취득에 대하여 취득세를 부과하게 되면 결국 건설업자는 취득세부담액은 사실상 건축비 내지 분양가액에 포함되어 분양자

233) 한병식, “분양주택의 원시취득에 대한 취득세 과세문제의 재검토”, 「지방세」 통권68호, 한국지방재정공제회, 2001, p.28.

에게 전가될 것이 자명한 것이다.

셋째, 지방세감면조례에 의하면 주택건설사업자 또는 주택법 제9조 제1항 제6호의 규정에 의한 고용자가 분양할 목적으로 건축한 5세대 이상의 공동주택과 당해 공동주택을 건축 후 미분양 등의 사유로 제13조의 규정에 의한 임대용으로 전환하는 경우 그 공동주택 중 전용면적 60㎡이하인 공동주택에 대하여는 취득세와 등록세를 면제한다고 규정하고 있다<sup>234)</sup>. 이러한 감면조례는 현행 지방세법상 비과세규정에 주택건설업자 등의 원시취득에 대한 취득세 비과세규정이 존재하지 아니함으로 인한 문제점을 보완하기 위한 규정이라고 이해된다. 이러한 감면조례의 규정을 보더라도 주택건설업자 등의 주택의 원시취득에 대하여는 취득세 납세의무가 없는 것으로 보아야 한다.

넷째, 현행 지방세법은 취득의 유형에 있어서 원시취득과 승계취득을 구분하지 아니하지만, 취득세가 실수요자에게 전가되는 것을 방지하기 위하여 지방세법 제105조 제2항에서는 차량·기계장비·항공기 및 주문에 의하여 건조하는 선박의 원시취득에 대하여는 취득세 납세의무를 부담시키지 아니하고, 승계취득의 경우에 한하여 취득세 납세의무를 부담시키고 있다. 이러한 지방세법상의 규정과 조화를 이루기 위해서라도 주택건설업자 등의 주택의 원시취득은 취득세 과세대상인 취득에 해당하지 아니하는 것으로 보아야 하는 것이다. 즉 차량 등의 원시취득에 대하여는 취득으로 보지 아니하는데 반하여 일반분양주택의 경우 취득으로 보아 취득세를 과세하는 것은 과세대상간의 조세형평에 어긋나는 것으로 타당하지 않은 것이다.

다섯째, 지방세법 제105조 제10항에서는 이중과세의 방지를 위하여 “주택법 제32조의 규정에 의한 주택조합이 당해 조합원용으

234) 전동훈, 「지방세감면조례해설」, (주)영화조세통람, 2004, p.56.

로 취득한 조합주택부동산은 그 조합원이 취득한 것으로 본다”라고 규정하고 있다. 즉 조합이 형식적으로 취득하지만, 조합의 취득에 대하여 취득세를 과세하게 되면 취득세의 이중과세에 해당하는 문제점이 발생하므로 이러한 문제점을 해결하기 위하여 조합의 취득은 취득으로 보지 아니하는 것이다.

여섯째, 그 건축자인 원시취득자는 그 분양목적으로 건축을 한 것으로서 그 의사와는 무관하게 법률상 임시적·일시적으로 주택을 취득하게 되는 것일 뿐이고 그 실질소유자는 당해 주택을 분양받은 수분양자이다. 따라서 건축업자에 대하여 그 소유권자라 하여 취득세를 부담시키는 것은 실질과세의 원칙에 어긋나는 것으로서 부당한 것이다<sup>235)</sup>.

일곱 번째, 우리나라와 유사한 취득세 구조를 취하고 있는 일본의 경우에도 일정한 요건을 충족한 신축주택의 경우에는 이중과세의 방지를 위하여 취득세의 과세대상에서 제외하고 있다. 즉 당해 주택이 최초로 사용 또는 양도가 이루어진 날에 그 취득이 된 것으로 보고 그 시점에서의 당해 주택의 소유자 또는 양수인을 취득자로 하여 취득세를 부과한다. 다만, 주택이 신축된 날로부터 6월을 경과하여도 그 사용 또는 양도가 이루어지지 아니한 경우에는 당해 주택이 신축된 날로부터 6월이 경과한 날에 주택의 취득이 이루어진 것으로 보아 그 시점에서의 주택의 소유자를 취득자로 간주한다<sup>236)</sup>. 이러한 규정은 분양목적으로 건축을 한 것으로서 그 의사와는 무관하게 임시적·일시적으로 주택을 취득하는 경우에는 담세력이 없다고 보아 취득세 납세의무를 부담시키지 않게 하기 위함이다.

여덟 번째, 대부분의 주택 재개발 및 재건축사업의 경우에는 실

235) 한병식, “분양주택의 원시취득에 대한 취득세 과세문제의 재검토”, 「지방세」 통권68호, 한국지방재정공제회, 2001, p.32.

236) 일본 지방세법 제73조의2 제1항.

질적으로 조합과 일괄 도급계약을 체결한 건설회사에 의해서 수행되고 있는데, 이들의 자와 서로 달리 취급하게 되면 조세평등주의에 위배될 소지가 크다고 할 것이다. 따라서 취득세 납세의무를 부담하지 않도록 하는 것이 바람직할 것이다.

### 3. 주택재개발사업에 있어서 취득세 과세의 문제점과 개선 방안

주택의 재개발과정에 있어서 취득세의 과세문제는 조합원이 당해 조합에 토지와 건물을 현물출자하는 경우 당해 조합에 대한 취득세 과세문제와 조합원으로부터 현물출자받은 토지와 건물에 대하여 조합이 공동주택을 신축하여 조합원에게 또는 비조합원에게 분양하는 단계에서의 취득세 과세문제로 구분할 수 있다.

이하에서는 이러한 취득세의 과세문제에 대하여 살펴보기로 한다.

#### 가. 현물출자 단계에 있어서의 취득세 과세문제

조합원이 재개발조합에 현물출자하는 단계에 있어서 당해 조합의 취득에 대하여 취득세를 과세할 것인지가 문제인데, 이에 대하여는 긍정설과 부정설의 대립을 상정할 수 있다.

긍정설의 입장은 주택재개발조합의 경우에는 법인의 형태이기 때문에 지방세 과세체계의 일관성을 유지하기 위해서 취득세를 과세하는 것이 타당하다고 한다<sup>237)</sup>. 이에 반하여 부정설의 입장은 주택재개발사업의 경우에는 재건축사업과는 달리 일반적으로 조

237) 임재근, “지방세법상 조합과세 현황과 그 개선방향”, 「조세연구」 제6집, 한국조세연구포럼, 2006.10, pp.32-33.

합원이 현물출자하는 토지 또는 건축물을 조합에게 소유권을 이전하는 절차 없이 조합이 조합원의 동의하에 그 출자된 부동산을 사업목적에 사용한다. 이와 같이 출자한 부동산이 조합원의 명의로 남아있기 때문에 조합에게 취득세 과세문제는 발생하지 아니한다고 한다.

생각건대, 주택재개발사업은 조합원 명의의 등기를 유지한 채, 조합원이 종전 부동산을 조합이 주택재개발사업 목적에 사용·관리 및 처분할 것을 동의함으로써 수행된다. 이러한 절차에서 조합이 종전 부동산을 취득하거나 소유권을 이전한 사실이 없으므로 취득세의 과세대상에 해당하지 않는다고 할 것이다. 따라서 주택재개발조합이 조합원의 종전 부동산을 사업목적에 사용하는 것은 조합원 분양용이든, 일반분양용이든 관계없이 취득세의 과세대상에 해당하지 않는다고 할 것이다<sup>238)</sup>.

#### 나. 조합이 신축한 공동주택을 분양하는 단계에 있어서의 취득세 과세문제

##### (1) 조합원에게 분양하는 경우

주택재개발조합이 조합원에게 신축한 주택을 분양하는 경우 그 분양분에 대하여 조합에게 취득세를 과세할 것인지의 여부가 문제인데, 다음과 같은 근거로 취득세를 과세할 수 없다고 보아야 할 것이다.

첫째, 도시및주거환경정비법 제55조 제2항에서 관리처분계획에 의하여 조합원에게 분양하는 대지 또는 건축물은 도시개발법 제

238) 同旨; 홍성욱, “주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 2006.2, p.81.

40조의 규정에 의하여 행하여진 환지로 본다고 규정하고 있으며, 보류지와 일반에게 분양하는 대지 또는 건축물은 도시개발법 제34조의 규정에 의한 보류지 또는 체비지로 본다고 규정하고 있다.

둘째, 지방세법 제109조 제3항에서는 도시개발법에 의한 도시개발사업과 도시및주거환경정비법에 의한 정비사업(주택재개발사업 및 도시환경정비사업에 한한다)의 시행으로 인하여 당해 사업의 대상이 되는 부동산의 소유자(상속인을 포함한다)가 환지계획 및 토지상환채권에 의하여 취득하는 토지, 관리처분계획에 의하여 취득하는 토지 및 건축물과 사업시행자가 취득하는 체비지 또는 보류지에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 부동산에 대하여는 취득세를 부과한다.

① 환지계획 등에 의한 취득부동산의 가액의 합계액이 종전의 부동산가액의 합계액을 초과하여 토지및주거환경정비법 등 관계 법령에 의하여 청산금을 부담하는 경우 그 청산금에 상당하는 부동산

② 환지계획 등에 의한 취득부동산의 가액의 합계액이 종전의 부동산가액의 합계액을 초과하는 경우 그 초과액에 상당하는 부동산. 이 경우 사업시행인가 이후 환지 이전에 부동산을 승계취득한 자에 한한다.

위의 도시및주거환경정비법 제55조 제2항과 지방세법 제109조 제3항의 규정에 의하면 주택재개발사업으로 신축된 주택 중에서 조합원에 대한 분양은 환지의 성격을 가지고 있기 때문에 종전의 토지나 건물이 그 동일성을 유지하면서 새로운 토지나 건물로 변환된 것으로 보는 것이다. 이러한 법리에 의하면 조합은 신축주택의 소유권을 취득하였다고 볼 수 없고, 조합원은 신축주택에 대한 소유권자이기는 하지만, 신축주택은 종전의 토지나 건물의 변환물

에 불과하기 때문에 새로 신축주택을 취득한 것으로 볼 수 없는 것이다. 따라서 주택재개발사업으로 신축된 주택 중에서 조합원에 대한 분양분은 취득세 납세의무가 발생하지 아니하는 것이다<sup>239)</sup>.

한편, 위의 규정에서 종전의 부동산가액을 초과하여 청산금을 부담하는 경우 청산금에 대하여는 취득세를 과세한다고 규정하고 있는데, 그 타당성을 없다고 할 것이다. 따라서 당해 규정은 삭제하는 것이 타당하다고 할 것이다.

#### (2) 조합원 이외의 자에게 분양하는 경우

주택재개발사업에 있어서 조합원 이외의 자에게 분양하는 경우에 당해 조합에게 취득세를 과세할 것인지의 여부가 문제인데, 이에 대하여 주택재개발사업에 있어서 조합원에 대한 분양은 비영리적인 성격이 강하지만, 조합원 이외의 자에 대한 분양을 영리적인 성격이 강하기 때문에 그 취급을 달리하여야 한다는 견해가 있다. 즉, 주택재개발사업에 있어서 조합원 이외의 자에게 분양하는 것은 영리적인 성격이 강하기 때문에 조합에게 취득세를 과세하는 것이 타당하다고 한다<sup>240)</sup>.

또한 주택재개발조합이 공급하는 주택을 분양받는 조합원 이외의 제3자는 주택건설공급자로서의 주택재개발조합으로부터 분양받는 것에 해당하기 때문에, 이 경우에는 조합과 분양받은 자 모두에게 취득세를 과세하는 것이 타당하다고 한다. 즉, 조합이 취득하는 조합원 공급용 이외의 부동산은 종국적으로 분양대금을 통하여 조합원의 건축비를 조달하는 성격을 가지고 있는 것으로

239) 同旨; 이종교, “주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구”, 「공법연구」 제37집 제1-2호, 한국공법학회, 2008.10, p.373.

240) 이종교, “주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구”, 「공법연구」 제37집 제1-2호, 한국공법학회, 2008.10, p.382.

수익적 성격이 있다고 판단하여야 할 것이고, 이를 고려한다면 조합이 부동산의 공급자로서 원시취득한 것으로 보는 것이 타당하다는 것이다<sup>241)</sup>.

그러나, 도시및주거환경정비법 제55조 제2항에 의하면 보류지와 일반인에게 분양하는 대지 또는 건축물은 보류지 또는 체비지로 본다고 규정하고 있으며, 지방세법 제109조 제3항에서 체비지 또는 보류지에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다고 규정하고 있기 때문에 조합원 이외의 자에게 분양하는 경우에도 당해 조합에게는 취득세 납세의무가 없다고 보아야 할 것이다.

한편, 조합으로부터 분양받은 조합원 이외의 자는 신축주택을 승계취득하는 것이므로 당연히 취득세 납세의무가 있다고 보아야 할 것이다.

#### 4. 주택재건축사업에 있어서 취득세 과세의 문제점과 개선 방안

주택의 재건축과정에 있어서 취득세의 과세문제는 위의 주택재개발사업과 마찬가지로 조합원이 당해 조합에 토지와 건물을 현물출자하는 경우 당해 조합에 대한 취득세 과세문제와 조합원으로부터 현물출자받은 토지와 건물에 대하여 조합이 공동주택을 신축하여 조합원에게 또는 비조합원에게 분양하는 단계에서의 취득세 과세문제로 구분할 수 있다.

이하에서는 이러한 취득세의 과세문제에 대하여 살펴보기로 한다.

241) 임재근, “지방세법상 조합과세 현황과 그 개선방향”, 「조세연구」 제6집, 한국조세연구포럼, 2006.10, p.33.



### 가. 현물출자단계에 있어서의 취득세 과세문제

#### (1) 문제의 소재

주택재건축사업의 경우에는 재개발사업과 달리 조합원이 조합에 현물출자시에 일반적으로 신탁등기의 방법에 의하여 이루어지고 있다. 즉, 조합원이 조합의 업무를 위해서 조합에게 그의 재산을 이전하는 것은 일반적인 이전일 수도 있고, 신탁에 의한 이전일 수도 있지만, 실무에서는 대부분 신탁을 전제로 하는 규약을 사용하는 관계로 신탁의 형태를 띄게 된다<sup>242)</sup>. 일반적으로 신탁이란 신탁설정자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)와 특별한 신탁관계에 기하여 위탁자가 특정의 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하는 법률관계를 말한다<sup>243)</sup>.

재건축 사업에 있어서는 일반적으로 조합원들은 자신들의 토지를 조합에 신탁하는 방법을 이용한다. 이처럼, 주택재건축사업에 있어서 조합원이 조합에 현물출자하는 경우 신탁등기를 하는 이유는 신탁등기를 하지 않으면 조합원의 대지지분 변동에 따른 배분과 일반분양자들에 대한 대지지분 배분절차가 복잡해지고, 일반분양자에게 분양계약을 작성할 때 조합원 모두의 날인이 필요하며, 일반분양자에게 소유권이전등기를 해줄 때 모든 조합원의 매도용 인감증명서를 첨부해야 하는 등 번거로운 점이 많기 때문이다<sup>244)</sup>.

242) 임채웅, 「신탁법연구」, 박영사, 2009, p.348.

243) 신탁법 제1조 제2항.

244) 이중교, “주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구”, 「공법연구」 제37집 제1-2호, 한국공법학회, 2008.10, p.374; 김명섭, “주택재건축 관련 취득세 논의”, 「사법논집」 제42집, 법원도서관, 2006.12, p.264.

이와 같이 재건축 사업과정에서는 일반적으로 조합원들은 조합에 신탁하는데, 이와 같은 신탁행위를 지방세법상 취득세의 과세 대상으로 할 것인지의 여부가 문제이다.

이하에서는 이에 대하여 현행 지방세법상의 규정과 학설 및 판례의 입장을 살펴보고, 신탁행위가 지방세법상 취득세의 과세대상이 되는지의 여부에 대하여 결론을 맺고자 한다.

## (2) 현행 지방세법의 규정

주택의 재건축 사업과정에서 조합원들이 조합에 신탁하는 경우, 신탁행위를 취득세의 과세대상으로 볼 것인지의 여부에 대한 지방세법상 규정은 지방세법 제105조 제10항과 지방세법 제110조 제1호이다.

먼저, 지방세법 제105조 제10항에서는 주택법 제32조에 따른 주택조합과 도시및주거환경정비법 제16조 제2항에 따른 주택재건축조합이 당해 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산은 그 조합원이 취득한 것으로 본다고 규정하고 있다. 그리고, 지방세법 제110조 제1호에서는 신탁(신탁법에 의한 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것에 한한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 취득에 대하여는 취득세를 과세하지 아니한다. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택조합등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다<sup>245)</sup>.

- ① 위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우의 취득
- ② 신탁의 종료 또는 해지로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우의 취득

245) 지방세법 제110조 제1호.

③ 수탁자의 경질로 인하여 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우의 취득

### (3) 학설

1) 조합원용과 비조합원용 모두 취득세의 과세대상이라는 견해  
신탁재산의 취득 중 주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 비과세대상에서 제외하였는데, 이는 주택조합 등과 조합원간 신탁이 종료되면 조합원에게 귀속하지 아니한 일반분양용 부동산(비조합원에게 분양되는 주택, 상가 등)은 조합의 수익사업용으로 과세를 하여야 함에도 과세할 수 없는 문제점이 있기 때문에 이를 과세대상으로 한다는 의미라고 한다<sup>246)</sup>. 즉, 이 견해는 조합원용이든 또는 비조합원용이든간에 신탁등기는 그 전부가 취득세의 과세대상에 해당한다고 한다.

2) 비조합원용만 취득세의 과세대상이라는 견해  
주택재건축사업에 있어서 신탁등기의 경우에 그 전부가 취득세의 과세대상이 아니라, 비조합원용만 취득세의 과세대상이라는 견해로서 그 근거는 다음과 같다.

첫째, 지방세법 제110조 제1호 단서에서는 신탁재산의 취득 중 주택조합등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 취득세의 비과세 대상에서 제외한다고 규정하고 있지만, 조합원분의 경우에는 제105조 제10호에 의하여 이미 과세대상이 아닌 것으로 되기 때문에 지방세법 제110조 제1호가 적용될 여지가 없고, 이에 따라 위 단서규정은 일반분양분에 대해

246) 권강웅·권태형, 「축조 지방세법해설」, (주)광교이텍스, 2009, p.588.

서만 적용되며, 따라서 조합이 일반분양분을 신탁으로 취득하는 경우 취득세의 과세대상이 된다는 견해가 있다<sup>247)</sup>.

둘째, 주택재건축 사업 중에서 일반분양과 관련된 사업은 그에 의하여 발생하는 이익이 일단 재건축조합에 귀속되는 것으로서, 조합의 독자적인 사업자성이 두드러진다. 그렇다면 재건축 시행과 정에서 조합원이 그 소유인 토지에 관하여 조합의 명의로 신탁등기를 한다고 하더라도 그 실질은 출자자로서 출자의무를 이행한 것이라고 보아야 할 것이며, 이렇게 본다면 취득세의 과세대상에 해당한다고 한다.

한편, 비조합원용분에 대한 신탁등기만 취득세의 과세대상이 된다는 견해인데, 취득시기로서 신탁등기시에는 조합원용과 일반분양분이 구분되지 않기 때문에 일반분양분에 대하여도 취득세를 과세할 수 없다고 한다. 결국, 조합의 일반분양용 취득은 애초의 신탁등기시가 아니라 그것이 조합 고유재산으로 전환되는 시점에서 일어난다고 보아야 한다고 한다. 즉, 등기시점이나 등기의 유무효로 판단할 것이 아니고, 일반분양분에 대한 조합원들의 실질적인 이해관계가 사라지고, 조합이 실질적으로 이것을 지배·처분할 수 있는 시점, 환언하면 신탁관계가 실질적으로 종료한 때라고 한다<sup>248)</sup>.

### 3) 모두 취득세의 과세대상이 아니라는 견해

주택건축사업에 있어서 신탁등기의 경우에는 조합원용이든 조합원용이 아니든 구분하지 않고, 그 전부가 취득세의 과세대상이 아니라는 견해로서 그 근거는 다음과 같다. 즉, 지방세법 제110조 제1호 단서규정은 지방세법 제105조 제10항 규정의 신설로 주택

247) 최원삼, “조합주택 과세방법에 대한 검토”, 「2005년 지방세포럼」, 서울시립대학교 지방세연구소, 2005.12, p.241.

248) 임채웅, 「신탁법연구」, 박영사, 2009, p.368.

조합의 신탁을 구태여 비과세대상으로 삼을 필요가 없다는 취지로 신설된 것인데, 지방세법 제110조 제1호 단서를 재건축조합의 신탁재산 취득을 과세하기 위한 것으로 해석할 경우에는 다른 신탁, 특히 신탁업법 제3조 제1항에 의하여 금융감독위원회의 인가를 받아 설립된 영업신탁회사인 부동산신탁회사의 신탁재산 취득과 달리 취급하여야 할 근거가 불분명하여 헌법상 평등의 원칙에 위반될 가능성이 크다고 한다. 부연하면, 과세설에 의할 경우에는 재건축조합의 일반분양용 토지의 신탁에 대해서만 여타 신탁과 달리 취득세를 과세하게 되는데, 신탁업법 제3조 제1항에 의하여 금융감독위원회의 인가를 받아 영업신탁을 영위하는 부동산신탁회사의 경우 지방세법 제110조 제1호에 의하여 취득세 과세대상에 제외되는 점과 비교할 때 민사신탁으로서 비영업신탁의 일종인 재건축조합의 일반분양용 토지의 신탁취득을 과세대상으로 삼는 것은 헌법상 평등원칙에 위반된다고 한다<sup>249)</sup>. 따라서 조합원용과 일반분양용을 구분하고 취득세의 과세대상에 해당하지 아니한다고 한다.

#### (4) 판례의 입장

판례는 취득세 비과세 대상에 관한 구 지방세법(1997. 8. 30. 법률 제5406호로 개정되기 전의 것) 제110조 제1호의 개정 취지 및 내용, 위 개정으로 인해 신설된 같은 법 제105조 제10항의 내용, 신탁의 법리 등에 비추어 볼 때, 개정 후 지방세법 제110조 제1호 단서는 수탁자인 주택조합과 위탁자인 조합원 사이에 이루어지는 신탁재산에 관한 형식적인 소유권 이전을 종래 취득세의 비과세

249) 최철환, “재건축주택조합의 일반분양용 토지에 관한 신탁재산취득의 취득세 과세 여부”, 「저스티스」 통권 제103호, 한국법학원, 2008.4, pp.274-276.

대상으로부터 과세대상으로 전환할 목적으로 신설된 것이 아니라, 그와 함께 신설된 제105조 제10항에 의하여 주택조합이 당해 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산은 신탁의 방법에 의해 취득하는 경우에도 그 조합원이 취득한 것으로 간주되기 때문에 그 부분에 대하여는 더 이상 제110조 제1호 본문이 적용될 여지가 없게 되어 그러한 취지를 나타내기 위해 신설된 것으로 보이므로, 그 단서 규정의 ‘주택조합과 조합원 간의 신탁재산의 취득’이라 함은 주택조합과 조합원 간의 ‘모든’ 신탁재산의 이전을 의미하는 것이 아니라 ‘제105조 제10항에 의해 조합원이 취득하는 것으로 간주되는 신탁재산의 이전’만을 의미하는 것으로 해석하여야 한다. 따라서 주택조합이 조합원 소유의 토지를 조합주택용 부동산으로 신탁에 의해 취득하면서 신탁등기를 병행하는 경우, 그 중 조합원용에 해당하는 부분은 개정 후 지방세법 제105조 제10항에 의해 그 조합원이 취득하는 것으로 간주되므로 주택조합에 대하여는 취득세를 부과할 수 없고, 조합원용이 아닌 부분은 제105조 제10항 및 제110조 제1호 단서에 해당하지 않아 제110조 제1호 본문이 적용되므로 취득세 부과대상이 되지 않는다<sup>250)</sup>고 판시하여 조합원으로부터 신탁으로 취득하는 토지 중에서 일반분양용 토지도 취득세의 과세대상에 해당하지 않음을 명백히 하고 있다.

#### (5) 결어

위의 지방세법 규정에서 살펴보았듯이 신탁등기에 의한 신탁재산의 취득은 형식적인 취득으로 보아 취득세를 과세하지 아니하지만, 지방세법 제110조 제1호 단서의 규정 때문에 주택재건축조

250) 대법원 2008.2.14. 선고 2006두9320 판결.

합과 조합원간 또는 비조합원간의 신탁재산이 취득세의 과세대상이 되는 것이 아닌가 하는 의문이 제기되는 것이다.

이 경우 조합원용은 지방세법 제105조 제10항에 의하여 주택조합이 당해 조합원으로 취득하는 주택조합용 부동산은 신탁의 방법에 의해 이를 취득하는 경우에도 그 조합원이 취득한 것으로 간주되기 때문에 그 부분에 대해서는 더 이상 제110조 제1호가 적용될 여지가 없다. 따라서 여기서 문제되는 것은 비조합원용 재산을 조합이 신탁등기하는 경우 취득세 납세의무가 있는지의 여부가 문제된다고 할 것이다.

그런데, 다음과 같은 근거로 신탁등기에 대하여는 조합원에 대한 분양분인지 또는 일반분양분인지에 대한 구분 없이 취득세를 과세하지 않는 것이 타당하다고 할 것이다.

첫째, 주택재개발 및 재건축사업을 실질적으로 조합원들의 공동사업과 동일한 것으로 보고 조합은 단지 그 기구로서 법인격을 형식적 개념으로 이해한다면 조합의 취득으로서 과세할 이유가 없으며, 세법 전체의 취지를 고려할 때 조합과 조합원의 거래는 일종의 자기거래로 보아야 하기 때문에 취득세의 과세대상에 해당하지 아니한다고 보아야 할 것이다.

둘째, 조합원이 신탁한 토지에 대하여 취득세를 과세한다는 견해를 취하게 되면, 신탁을 통하지 않는 경우와 과세상 불공평이 발생하게 되어 부당하다고 할 것이다. 즉, 예외적인 경우이지만 조합원들이 그 소유의 토지를 조합에게 신탁이 아닌 일반적인 소유권 이전의 형태로 넘기게 될 경우에는 지방세법 제110조 제1호가 적용될 여지가 없고, 지방세법 제105조 제10항이 적용되기 때문에 조합은 취득세 납세의무를 부담하지 않는데 반하여, 신탁의 형식을 취하는 경우에는 취득세를 부담하게 되기 때문에 조세평등주의에 위배되는 것이다.

셋째, 신탁등기에 의한 토지의 취득 단계에서는 조합원 분양분과 일반분양분을 구분하는 것은 사실상 불가능하다는 점이다. 즉, 일반적으로 조합의 사업을 위해서 조합 명의로 신탁등기가 이루어지는 시점에서는 조합원용과 일반분양용이 구분되지 않는 것이다. 조합이 취득하는 단계에서는 일반분양자들이 반드시 존재한다고 할 수 없고, 존재한다고 하더라도 조합과 그들의 관계는 일반적인 채권채무관계에 지나지 않는다. 따라서 조합의 토지 취득 단계에서 그 토지를 구분하여 조합원용과 일반분양용을 구분하여 파악하는 것은 불가능한 것이다. 부연하면, 신탁관계는 조합원분과 일반분양분 모두에 대해 구분 없이 성립되는 것이지, 그 단계에서 조합원분과 일반분양분이 나뉘는 것은 아니다. 이 단계에서 조합은 일반분양분과 조합원분 전체를 그 구분 없이 수탁자의 지위에서 취득하며, 일반분양분으로 구분하여 독자적으로 취득하는 것이라 할 수 없는 것이다<sup>251)</sup>.

넷째, 주택재건축사업에서의 신탁등기는 사업을 원활하게 수행하기 위한 하나의 방면으로 이루어지는 것에 불과하다<sup>252)</sup>. 즉, 조합원이 조합의 업무를 위하여 조합에게 그의 재산을 이전하는 것은 일반적인 이전일 수도 있고, 신탁에 의한 이전일 수도 있는 것이며, 이러한 이전이 반드시 신탁의 형태이어야 할 필연성이 있는 것은 아니지만, 사업을 원활하게 수행하기 위해서 신탁의 형태로 이루어지는 것이다.

다섯째, 일반분양용 토지만이 취득세의 과세대상이 된다고 할 경우 취득시기를 언제로 할 것인지가 문제이다. 즉, 일반분양용 토지만이 취득세 과세대상이 된다고 할 경우 신탁계약일이나 토

251) 同旨; 임채웅, “재건축주택조합과 신탁에 대한 취득세의 부과에 관한 연구”, 「저스티스」 통권 제102호, 한국법학원, 2008.2, pp.200-201.

252) 이종교, “주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구”, 「공법연구」 제37집 제1-2호, 한국공법학회, 2008.10, p.375.



지에 대한 신탁등기 경료일에는 조합원의 변동으로 인하여 조합원용과 일반분양용 토지 지분이 확정되지 아니하므로 취득세 납세의무가 성립되었다고 볼 수 없고, 신탁토지 중 조합원용과 일반분양용의 지분이 확정되는 시점에 일반분양용 토지를 신탁재산으로 취득하였다고 보아야 할 것이다. 그런데, 취득세 납세의무의 성립시기, 즉 신탁에 의한 취득시기를 신탁계약시나 신탁등기시가 아니라 아파트를 건축하기 위한 상당한 시일이 경과된 후 아파트 완공시점에 이르러 비로소 취득이 있다고 의제함으로써 장기간 동안 취득세와 관련한 법률관계, 과세표준, 적용법령, 부과제척기간 등을 유동적인 상태에 두게 되는 문제점이 발생하게 되는 것이다<sup>253)</sup>.

여섯째, 지방세법 제110조 단서의 규정에 때문에 신탁에 의한 취득에 대하여 취득세를 과세하게 되면 결과적으로 부동산신탁회사에 비하여 재건축조합을 합리적인 이유 없이 차별과세하는 결과를 초래하기 때문에 위헌을 면하기 어렵다고 할 것이다. 즉, 주택재건축을 위한 조합원들의 주택조합에의 토지신탁과 다른 신탁등기가 병행되는 신탁법에 의한 신탁은 모두 신탁으로 인한 신탁재산의 취득으로서 법적으로 서로 동일한 사실관계에 해당하고 양자를 서로 다르게 취급할 만한 본질적인 차이점은 없다. 오히려 국민의 주거생활의 안정을 도모하고 모든 국민의 주거수준의 향상을 기한다는 관점에서 주택조합의 신탁에 의한 토지취득에 대하여 세제상의 혜택을 주는 등의 지원을 하는 것이 바람직하다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고 지방세법 제110조 제1호 단서는 아무런 합리적인 이유 없이 다른 신탁등기가 병행되는 신탁법에 의한 신탁에 비하여 불리하게 차별하고 있는 것으로서 위헌의 소지

253) 최철환, “재건축주택조합의 일반분양용 토지에 관한 신탁재산취득의 취득세 과세 여부”, 「저스티스」 통권 제103호, 한국법학원, 2008.4, p.276.

가 매우 크다고 할 것이다<sup>254)</sup>. 부연하면, 조합의 사업은 오로지 조합원들을 위해 집합건물을 짓는 것이며, 일반분양분은 그 사업의 일환으로 수행하는 것으로 보아야 하기 때문에 일반 부동산신탁회사의 사업에 비하여 조합의 사업에는 준공인가단계에서 조합원들의 이해관계를 상실한다는 점이 있다고 하더라도 그 이후의 단계에서 조합이 취득세를 납부하는 것은 타당성이 없다고 할 것이다<sup>255)</sup>.

일곱 번째, 조합원이 현물출자의무에 의하여 기존 대지에 관하여 조합에 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기를 경료한 경우도 취득세 과세객체가 되고, 지방세법 제110조 제1호 단서에 해당되어 일응 재건축조합에 취득세 납세의무가 발생할 수 있다. 그런데, 재건축조합이 신탁등기를 하는 당해 조합원용으로 그 토지를 취득함으로써 장차 조합원용 신축 건물의 대지 지분에 해당할 부분이든 일반분양용 신축 건물의 대지 지분에 해당할 부분이든 무관하게 전체 토지가 지방세법 제105조 제10항에 의하여 그 조합원이 취득한 것이 되어 재건축조합이나 당해 조합원 모두 취득세 납세의무가 없다고 할 것이다<sup>256)</sup>.

여덟 번째, 일반분양분에 대하여는 취득세의 과세대상이 된다고 하면서 그 취득시기를 신탁관계가 사실상 종료하는 때로 하여야 한다는 견해가 있는데, 이 경우 신탁관계가 사실상 종료하는 때가 언제인지 명확하지 않기 때문에 그 의견은 타당성에 있어서 의문이다.

아홉 번째, 주택재건축 사업의 경우에는 다수의 조합원들이 주체가 되어 건축허가를 받고 공사도급계약을 체결하여 준공인가를

254) 이종혁, “재건축조합이 조합원들로부터 신탁받은 토지에 대한 취득세 과세 여부”, 「조세연구」 제7집, 한국조세연구포럼, 2007.10, p.155.

255) 임채웅, 「신탁법연구」, 박영사, 2009, p.379.

256) 김명섭, “주택재건축 관련 취득세 논의”, 「사법논집」 제42집, 법원도서관, 2006.12, pp.289-290.

받는 법률관계를 단체적으로 간명하게 처리하기 위하여 조합이라는 도구를 사용한다. 즉, 조합은 다수의 조합원들로부터 그 소유의 부동산을 신탁받아 조합 명의로 건축허가를 받고 공사도급계약을 체결하여 준공인가를 받은 후 신축한 건물을 조합원들에게 이전하는 것이다<sup>257)</sup>. 이는 결과적으로, 실질적으로는 조합원들이 주택재건축 사업을 시행하는 것이라고 할 것이므로, 조합에 대한 신탁행위는 실질적인 취득이 있다고 보는 것은 부당하다고 할 것이다. 즉, 주택재건축조합은 주택재건축 절차를 간명하게 처리하기 위한 도구개념에 불과한 것인데, 조합이 그 조합원으로부터 애초에 신탁한 재산을 대지권 등기시에 새로 취득하였다고 하여 취득세를 부과하는 것은 권리취득에 관한 법적 실질을 무시하고 이중, 삼중의 과세를 허용하는 것으로서 부당하다고 할 것이다.

결과적으로 지방세법 제110조 제1호의 단서 규정은 의미가 없고, 위헌성이 농후할 뿐만 아니라, 해석상 논란만 초래하고 있으므로 당해 규정은 삭제하는 것이 타당하다고 할 것이다.

#### 나. 조합이 신축한 공동주택을 분양하는 단계에 있어서의 취득세 과세문제

##### (1) 조합원에게 분양하는 경우

1) 주택조합의 취득의 경우 취득세 납세의무자에 대한 지방세법상 규정의 변천

257) 同旨; 이종혁, “재건축조합이 조합원들로부터 신탁받은 토지에 대한 취득세 과세 여부”, 「조세연구」 제7집, 한국조세연구포럼, 2007.10, p.143.

## ① 구 지방세법상의 규정

과세관청은 주택조합이 가사용승인 또는 준공검사를 받았을 때 구 지방세법 제105조 제2항(1997.8.30. 법률 제5406호의 개정 전)에 의하여 등기 또는 등록을 이행하지 아니한 경우라도 사실상으로 취득한 경우에 해당한다고 보아 주택조합에게 사실상 취득한 것에 대한 취득세를 부과하고, 조합원이 주택을 배정받아 자기의 주택부분에 대한 소유권 보존등기를 하는 때에 다시 이를 취득으로 보아 주택조합원들에게 취득에 납세의무를 부가하였다. 즉, 신축 건물에 대한 사용검사 또는 임시사용승인이 있게 되면, 재건축조합에 신축 건물의 원시취득으로 인한 취득세 납세의무가 성립함과 동시에 재건축조합으로부터 이를 분양받아 청산금을 모두 지급한 조합원에게도 신축 건물의 승계취득으로 인한 취득세 납세의무가 성립한다고 보아 재건축조합과 조합원에게 각각 취득세를 부과하였다<sup>258)</sup>. 그러나, 실질적으로는 조합의 취득에 대하여는 시도세감면조례에 의하여 취득세와 등록세를 면제하고 그 이후 조합원에게 분양될 때 과세하였다. 결과적으로 주택조합은 취득세 납세의무자로 보지 아니한 것이다.

## ② 개정 후 지방세법상의 규정

개정 전 지방세법상의 규정은 동일한 취득물건에 대하여 하나의 취득은 등기·등록은 없었지만 사실상의 취득에 해당하는 것이라고 하여 과세하였고, 또 하나의 취득은 등기·등록이라는 행위가 있기 때문에 취득이 된다고 과세하여 결국 하나의 취득과정이 형식적인 면과 실질적인 면으로 분리되어 주택조합과 조합원이 모두 취득세를 부담하게 되어 이중과세가 되어 불합리하였다.

258) 김명섭, “주택재건축 관련 취득세 논의”, 「사법논집」 제42집, 법원도서관, 2006.12, p.229.

이에 지방세법에서는 1997년 8월 30일 법률 제5406호로 신설하여 주택조합이 조합주택용으로 취득하는 부동산은 그 조합원이 취득하는 것으로 본다고 하여 이중과세의 문제를 해결하였다. 즉 주택조합의 부동산 중 조합원 지분에 대하여는 조합원이 취득한 것으로 보고, 일반분양분 및 상가 기타 지분에 대하여는 주택조합이 취득한 것으로 본다.

## 2) 판례의 견해

판례는 지방세법상의 개정 여부에 상관없이 일관되게 주택조합의 취득에 대하여는 취득세 납세의무가 없다고 보았다. 즉 “주택조합은 그 소유의 자금으로 조합원의 건물을 신축 분양하는 것이 아니라 공정에 따라 조합원으로부터 각자 부담할 건축자금을 제공받아 조합원의 자금으로 이를 건축하는 것이므로, 건축절차의 편의상 조합명의로 그 건축허가와 준공검사를 받았다고 하더라도 그 건물의 소유권은 조합원이 아닌 일반인에게 분양된 주택부분 및 복리시설 등을 제외하고는 특단의 사정이 없는 한 건축 자금의 제공자인 조합원들이 원시취득한 것으로 보아야 한다”고 판시<sup>259)</sup>하여 주택조합에게는 취득세 납세의무가 없고, 조합원이 취득할 때에 취득세 납세의무가 있다고 하였다.

## 3) 결어

주택조합의 취득은 자기의 명의로 준공검사 또는 사용승인서를 교부받는다고 하더라도 주택조합 명의의 보존등기를 할 수 없으며, 주택건축에 대한 건축대금은 공정에 따라 조합원으로부터 제공받아 편의상 다수인 조합원을 대신하여 주택조합이 일괄적으로

259) 대법원 1996.4.12선고, 96다3807판결; 대법원 1995.1.24선고, 94다47797판결; 대법원 1994.9.9선고, 93누16369판결; 대법원 1994.6.24선고, 93누18839판결.

건축회사에 지급하기 때문에 실질적으로 자기의 계산으로 대금을 청산하는 것이 아니므로 주택조합은 취득세 납세의무가 없다. 그런데, 구 지방세법에서는 취득세를 형식적인 입장에서 판단하여 주택조합의 취득과 조합원의 취득에 대하여 취득세를 부과하여 결과적으로 이중과세가 되는 결과를 초래하게 된 것이다. 이에 대하여 판례가 실질설의 입장에서 주택조합의 취득은 취득세의 과세대상이 되지 아니한다고 판시하여 법의 개정에 이르게 된 것이다.

즉 취득의 개념을 실질설에 입각하여 주택조합의 취득에 대하여 취득세의 과세대상이 되는 취득에 해당하지 아니한다는 것을 지방세법에 명시한 것으로서 그 의의가 크다고 할 것이다.

## (2) 조합원 이외의 자에게 분양하는 경우

조합원 이외의 자, 즉 일반분양하는 경우 당해 조합에게 취득세 납세의무가 있는지의 여부에 대하여는 긍정설과 부정설의 대립을 상정할 수 있다. 이하에서는 이러한 내용에 대한 지방세법상 규정에 대하여 살펴보고, 바람직한 입법방향을 제시하기로 한다.

### 1) 현행 지방세법상 규정

지방세법 제105조 제10항에서는 주택법 제32조에 따른 주택조합과 도시및주거환경정비법 제16조 제2항에 따른 주택재건축조합이 당해 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산(공동주택과 부대·복리시설 및 그 부속토지를 말한다)은 그 조합원이 취득한 것으로 본다. 다만, 조합원에게 귀속되지 아니하는 부동산은 제외한다라고 규정하고 있다. 따라서 조합원 이외의 자에게 분양하는 경우에는 당해 조합은 주택을 원시취득한 것으로 보아 취득세를

과세하고, 분양받은 조합원 이외의 자는 당해 주택을 승계취득한 것으로 보아 취득세의 납세의무가 있다고 규정한 것으로 보인다.

## 2) 학설

주택재건축조합이 건축한 주택을 일반분양하는 경우 당해 조합에 대하여 취득세를 과세할 것인지의 여부에 대하여는 긍정설과 부정설의 대립이 있다. 이하에서는 이러한 긍정설과 부정설의 입장과 그 근거에 대하여 살펴보기로 한다.

### ① 긍정설

조합원 이외의 자에게 분양하는 경우에는 조합에게 취득세 납세의무가 있다는 의견으로서, 그 근거는 다음과 같다.

첫째, 법인세와 부가가치세의 경우에는 조합원 분양과 조합원 이외의 자에 대한 분양으로 구분하여 비영리적인 성격이 강한 조합원 분양에 대하여는 비과세하고, 영리적인 성격이 강한 조합원 이외의 자에 대한 분양은 과세하고 있다. 이러한 논리대로 비영리적인 성격이 강한 조합원에 대한 분양분에 대하여는 취득세를 과세하지 않고, 영리적인 성격이 강한 조합원 이외의 자에 대한 분양에 대하여는 취득세를 과세하는 것이 타당하다고 한다. 즉, 이와 같이 하는 것이 일반 건설회사와의 형평 측면에서 타당하고, 법인세와 부가가치세 등 다른 조세와의 체계적합성에도 부합하는 것이다<sup>260)</sup>.

둘째, 조합원용 주택건설사업은 조합원들이 재건축조합을 통하여 하는 조합원들의 공동사업이고, 일반분양용 주택건설사업은 재건축조합의 부동산공급업으로 보아야 한다고 한다. 이와 같이 볼

260) 이종교, “주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구”, 「공법연구」 제37집 제1-2호, 한국공법학회, 2008.10, p.380.

경우에는 조합원용 주택건설사업과 관련된 부동산의 취득에 대한 취득세는 조합원이 납세의무자가 되고, 일반분양용 주택건설사업과 관련된 부동산의 취득에 대한 취득세는 조합이 납세의무자가 된다고 한다<sup>261)</sup>.

셋째, 재건축조합이 일반분양한 건물을 신축한 경우는 지방세법이나 조례가 비과세 규정이 없기 때문에 당해 조합은 원시취득으로 보아 취득세 납세의무가 있다고 한다<sup>262)</sup>.

## ② 부정설

부정설의 입장은 조합원에 대한 분양뿐만 아니라 조합원 이외의 자에게 분양하는 경우에도 취득세의 과세대상에 해당하지 아니한다고 한다.

## 3) 판례의 입장

대법원은 주택조합은 그 소유자금으로 조합원의 건물을 신축·분양하는 것이 아니라 공정에 따라 조합원으로부터 각자 부담할 건축자금을 제공받아 조합원의 자금으로 건축하는 것이므로 특단의 사정이 없는 한 건축절차의 편의상 조합명의로 그 건축허가와 준공검사를 받았다고 하더라도 이때부터 건물의 소유권은 건축자금의 제공자인 조합원들이 원시취득한 것으로 보아야 하므로, 조합주택 신축주택으로 인한 취득세의 납세의무자는 조합원들이라고 판시하고 있다<sup>263)</sup>. 이는 결과적으로 주택조합 명의로 신축한 주택 중에서 조합원용은 조합원이 원시취득하여 조합원이 취득세 납세의무가 있고, 일반인에게 분양되는 주택은 주택조합이 원시취

261) 김명섭, “주택재건축 관련 취득세 논의”, 「사법논집」 제42집, 법원도서관, 2006.12, p.258.

262) 홍성욱, “주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 2006.2, p.89.

263) 대법원 1994.9.9선고, 93누16369판결.



득하여 주택조합이 취득세 납세의무가 있다고 보는 것이라고 할 수 있다. 즉, 대법원은 긍정설의 입장을 취하고 있다고 보아야 할 것이다<sup>264)</sup>.

#### 4) 결어

다음과 같은 근거로 조합원 이외의 자에게 분양하는 경우에도 당해 조합에게는 취득세의 납세의무가 없다고 보아야 할 것이다.

첫째, 도시및주거환경정비법의 시행으로 인하여 주택재개발 사업과 재건축 사업은 동일한 절차로 이루어지게 되었다. 다만, 주택재건축사업의 경우에는 재개발사업과 달리 일반적으로 신탁등기에 의해서 이루어지지만, 이는 조합원의 현물출자의무를 이행하는 하나의 방식에 불과하기 때문에 당해 차이가 과세여부를 달리 할 정도의 것으로 평가하기는 힘들다고 할 것이다. 즉, 취득세의 과세에 있어서 주택재개발사업과 재건축사업에 있어서 차별을 두는 것은 두 사업을 통일적으로 규율하는 도시및주거환경정비법의 제정 취지를 반영하지 못하는 것으로서 타당하지 않다고 할 것이다.

둘째, 토지상에 집합건물이 존재하고 구분소유자가 당해 토지를 사용할 수 있는 권리가 있으며 건물과 분리하여 처분할 수 없다는 일체분가분성을 갖추면 토지소유권 등이 대지권으로서 성립하는 것이지, 대지권 등기에 의하여 종전의 토지 소유권 등과는 별개의 권리로서 대지권이 창설된 것이 아니므로 집합건물에 대하여 대지권 등기를 한 것이 종전의 토지 소유권과는 별개의 권리를 취득한 것으로서 지방세법 제105조 제1항의 부동산의 취득에 해당한다고 할 수 없다. 또한 정비사업조합이 재건축사업을 종료

264) 同旨; 김명섭, “주택재건축 관련 취득세 논의”, 「사법논집」 제42집, 법원도서관, 2006.12, p.258.

하고 정비사업조합의 명의로 일반분양용 토지에 관한 대지권 등기를 마쳤다고 하여 이로써 종래 신탁에 기한 소유권과 다른 별개의 권리를 새로이 취득한 것이라고 볼 수도 없다고 할 것이다<sup>265)</sup>.

셋째, 조합원 이외의 자에게 분양하는 것에 대하여 조합이 취득세 납세의무를 부담한다는 주장의 근거는 지방세법 제105조 제10항을 든다. 즉, 지방세법 제105조 제10항에서는 주택법 제32조에 따른 주택조합과 도시및주거환경정비법 제16조 제2항에 따른 주택재건축조합이 당해 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산(공동주택과 부대·복리시설 및 그 부속토지를 말한다)은 그 조합원이 취득한 것으로 본다라고 규정하고 있는 점을 그 근거로 하는 것이다. 그러나, 문리해석상 당해 조합원용이란 의미는 당해 조합원에게 분양할 목적으로, 당해 조합원의 사용에 공하기 위하여, 당해 조합원을 위하여로 해석될 수 있을 뿐, 그것이 장차 당해 조합원의 소유가 될 것까지 요구하고 있는 것으로 해석하기 어렵기 때문에 조세법률주의의 엄격해석에 반한다고 할 것이다<sup>266)</sup>.

## 제2절 재산세의 과세에 있어서 문제점과 개선방안

### 1. 재산세의 일반론

과거에는 부동산에 대한 지방세는 건축물은 재산세로 과세되었으며, 토지는 종합토지세로 과세되었다. 그런데, 2005년 부동산 보

265) 同旨; 김완석, “재건축에 대한 조세법적 검토”, 「토지공법연구」 제33집, 한국토지공법학회, 2006.11, pp.52-53.

266) 김명섭, “주택재건축 관련 취득세 논의”, 「사법논집」 제42집, 법원도서관, 2006.12, p.285.

유세의 강화정책의 일환으로 국세인 종합부동산세를 신설함과 동시에 지방세인 재산세와 종합토지세를 통합하였다. 즉, 2005년 지방세법의 개정으로 인하여 주택의 경우에는 토지와 건물을 통합하여 주택분 재산세를 과세하고 있으며, 나대지와 일반건축물의 부속토지 등에 대해서는 토지분 재산세를 과세하고 있는 것이다.

한편, 과세표준의 현실화를 위해서 재산세의 과세표준 산정방법을 토지의 경우에는 개별공시지가를 적용하고, 주택의 경우에는 개별주택가격을 적용하도록 하였다. 그런데, 이와 같이 함으로 인하여 세부담이 급격하게 증가하는 문제점이 발생하게 되었다. 이러한 문제점을 해소하기 위해서 세부담 상한제도를 도입하였다.

## 2. 재개발·재건축 관련 재산세 과세상의 문제점과 개선 방안

### 가. 과세대상에 있어서의 문제점과 개선방안

재개발 또는 재건축 등이 시행되는 경우에는 주거용 건축물이 멸실되기 때문에 재산세의 과세에 있어서 과세대상이 변경된다. 즉, 기존 주거용 건축물은 그 과세대상이 주택과 건축물을 통합한 주택분 재산세로 과세되지만, 재개발 또는 재건축 등을 실시하는 경우에는 주거용 건축물이 멸실되어 그 과세대상은 나대지에 해당되어 토지분 재산세로 과세된다. 이와 같이 일시적으로 주택에서 토지로 과세대상이 변경되는 경우에는 평가기준의 차이에 따른 시가표준액·과세표준 적용비율·세부담상한율·기존에 받아오던 세부담상한에 따른 부담분의 차이가 발생하여 급격한 세부담의 증가가 발생하게 되는 문제점이 발생한다<sup>267)</sup>.

267) 각각의 세부담 증가의 원인에 대한 구체적인 내용은 서울시립대학교 지방세연

이와 같은 문제점을 개선하기 위한 방안을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 과세대상의 변경에 따른 세부담 완화규정에 있어서 재개발 또는 재건축 등에 의한 일시적 과세대상의 변경이 발생하는 경우에는 그 대상요건을 규정하여야 한다.

둘째, 과세표준 적용비율의 차이를 조정하기 위해서는 과세표준 적용비율이 100%가 될 때까지 한시적으로 과세대상 변경에 따른 차이를 조정할 필요가 있다. 즉, 과세대상이 주택에서 토지로 변경되었을 경우 기존의 주택분 재산세의 과세표준 적용비율을 동일하게 적용하여 과세표준 적용비율의 동일성을 유지하는 방향으로 조정하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

셋째, 주택분 재산세와 토지분 재산세의 세부담상한 적용율은 원칙적으로 동일하지만, 일정 구간에서의 차이 때문에 세부담이 급격하게 증가할 수 있는 문제점이 있다. 과세대상의 변경으로 그 상한율에 변동이 일어나는 구간 즉, 변경전 주택분 재산세의 과세대상 6억원 이하에 해당되어 세부담상한율을 5%나 10%를 적용 받은 주택분 재산세의 과세대상이 조정대상이 된다. 이 경우 종전의 세부담상한율을 감안하여 토지분 재산세의 세부담상한율 50%까지 바로 적용되지 않도록 일정기간을 두고 일정비율을 가산하여 완만하게 증가하도록 하는 것이 바람직할 것이다.

#### 나. 체비지 또는 보류지에 대한 재산세 납세의무 규정의 문제점과 개선방안

신탁법에 의하여 수탁자의 명의로 등기 또는 등록된 신탁재산

---

구소, 「주택분재산세 직전년도 세부담상한 상당액 적용기준 및 토지분재산세 합리적 대응방안」, 2008.12, pp.50-58의 내용을 참조하기 바란다.

의 경우에는 위탁자가 납세의무자가 된다<sup>268)</sup>. 따라서 정비사업조합이 토지를 이전등기하면서 위탁자인 조합원의 신탁재산임을 등기한 경우에는 당해 토지에 대한 납세의무자는 위탁자인 조합원이 되는 것이다.

주택재개발 등의 경우 재산세 납세의무자에 있어서 문제가 되는 것은 체비지 또는 보류지의 경우에 누가 납세의무자가 되는지의 여부이다. 이에 대하여 지방세법 제183조 제2항 제6호에서는 도시개발법에 의하여 시행하는 환지방식에 의한 도시개발사업 및 도시및주거환경정비법에 의한 정비사업(주택재개발사업 및 도시환경정비사업에 한한다)의 시행으로 그 사업에 필요한 비용으로 충당하거나 사업계획 등이 정하는 목적을 위하여 환지계획에서 일정한 토지를 환지로 정하지 아니하고, 체비지 또는 보류지로 정한 경우에는 사업시행자가 재산세를 납부하여야 한다고 규정하고 있다. 이 경우 체비지 또는 보류지란 주택재개발사업 또는 도시환경정비사업 등의 주요 대상이 되는 조합원용 부동산의 공급 이후에 잔여분이 있을 경우 조합원 이외의 제3자에게 공급하거나 당해 사업의 비용에 충당하기 위해서 조합의 명의로 취득하는 부동산을 말한다.

지방세법상 명문의 규정이 있기 전에도 체비지 또는 보류지에 대하여는 당해 사업시행자를 사실상 소유자로 보아 재산세를 부과하였다<sup>269)</sup>. 그러나, 대법원 판례에서 시행자가 체비지예정지에 대하여 가지는 관리권의 내용 및 그 한시적·공익적 성격에 비추어 볼 때 토지를 사실상 소유하고 있는 자에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하여<sup>270)</sup> 사업시행자가 체비지를 제3자에게 처분하기 전까지는 재산세를 부과할 수 없게 되었다. 이에 1997년 8월 30일

268) 지방세법 제183조 제2항 제5호.

269) 당시에는 종합토지세를 부과하였다.

270) 대법원 1996.4.18선고, 93누1022판결.

에 지방세법에서 명시적으로 사업시행자를 납세의무자로 하도록 입법하여 현재에 이르고 있다.

이와 같이 입법한 것이 실질과세의 원칙에 위배되는지의 여부가 문제되는데, 이에 대하여 헌법재판소는 토지구획정리사업의 사업시행자는 체비지에 대하여 비록 사업목적에 의한 제한은 있지만 경제적 소유권의 객관적 징표인 사용수익권과 처분권을 갖추어 그에 대한 배타적인 사실상의 경제적 지배를 함으로써 담세력을 지니고 있으므로 사업시행자에게 종합토지세의 납세의무를 부과한 것은 실질과세의 원칙에 위배되지 않는다고 보고 있다<sup>271)</sup>. 또한 입법자로서는 환지처분의 공고가 있을 때까지 체비지에 대한 재산세에 관하여, 체비지의 법률적 특성과 사업시행자의 체비지에 대한 권리가 한시적, 공익적인 점을 고려하여 비과세나 면세로 할 것인지 아니면 다른 환지예정지와 동일하게 취급하여 과세할 것인지 선택할 수 있으므로 이는 입법정책의 문제라고 할 것이다. 만일 과세하기로 하는 정책을 선택한다면 원칙적으로 당해 사업지구 내의 토지소유자(조합원)이 전원이 체비지에 대한 재산세 전액의 납세의무를 부담하여야 하겠지만, 한편 조합원은 조합에 대하여 사업비용 또는 조합비를 지급하는 것에 갈음하여 체비지의 관리와 처분을 조합에게 위임하였으므로 결국 체비지에 수반되는 재산세의 납세의무도 함께 위임한 것으로 보아야 할 것이므로 이러한 의미에서도 실질과세의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다고 보고 있다<sup>272)</sup>.

그러나, 체비지로 정한 토지를 일시 관리하는 공법상의 관리권자에 불과한 토지구획정리사업의 사업시행자에게 재산세의 납부의무를 부과하는 것은 실질적 조세법률주의와 조세평등주의에 어

271) 헌법재판소 2001.7.19결정, 2000헌바40·41·42(병합).

272) 헌법재판소 2001.7.19결정, 2000헌바40·41·42(병합).

긋나는 것으로 타당하지 않다고 할 것이다. 따라서 입법적인 개선이 이루어져야 할 것이다<sup>273)</sup>.

---

273) 임주영·정지선, “지방세법상 재산세의 문제점과 개선방안”, 「조세법연구」 XIII-3, 한국세법학회, 2007.12, pp.173

## 제8장 요약 및 결론

우리나라는 1970년대 이후부터 산업화와 도시화에 따라서 대량으로 공급된 주택이 시간의 경과로 인하여 노후화되었으며, 국민들의 생활수준의 향상에 따라서 주거에 대한 개선의 욕구가 커짐으로 인하여 주택의 재개발 및 재건축이 활발하게 이루어지고 있는 실정이다. 이러한 주택에 대한 재개발 및 재건축사업은 필연적으로 조세법상의 여러 가지 문제점을 불러 일으키고 있다. 즉, 정비사업조합이 영리법인에 해당하는지 또는 비영리법인에 해당하는지에 따라서 과세상의 차이가 발생하며, 조합원의 당해 조합에 대한 현물출자 등으로 인한 양도소득세의 과세문제가 발생하고, 조합원의 조합입주권 및 분양받은 주택의 양도 등과 관련해서는 법인세와 부가가치세 등과 같은 조세문제가 발생하게 된다.

그러나, 이러한 조세문제에 대한 명확한 규정이 존재하지 않아서 해석상 논란이 끊이지 않게 발생하고 있다. 이러한 조세문제에 대한 개선방안과 그 해석론을 제시하면 다음과 같이 정리할 수 있을 것이다.

첫째, 정비사업조합을 영리법인으로 볼 것인지 또는 비영리법인으로 볼 것인지의 여부가 문제인데, 현행법의 해석상 영리법인으로 보아야 할 것이다.

둘째, 정비사업조합의 조합원이 정비사업조합에 건축물 및 그 부속토지를 현물출자하고 관리처분계획에 따라 취득하는 대지 또는 건축물 등은 소득세법 제88조 제2항의 도시개발법 기타 법률에 의한 환지처분으로 지목 또는 지번이 변경되거나 체비지로 충당되는 경우에 해당하여 양도에 해당하지 않는다고 보는 것이 타



당할 것이다.

셋째, 조합원입주권은 양도소득세의 과세대상에 해당한다. 여기서 문제되는 것은 조합원입주권을 부동산으로 볼 것인지 또는 부동산을 취득할 수 있는 권리로 볼 것인지의 여부이다. 왜냐하면, 부동산인지 또는 부동산을 취득할 수 있는 권리인지에 따라서 장기보유특별공제의 적용대상 및 세율의 적용 등이 서로 상이하여, 결과적으로 양도소득세의 부담이 달라지기 때문이다. 이 경우 조합원입주권으로 변환되는 때는 관리처분계획의 인가가 있을 때로 보아야 하며, 이러한 조합원입주권은 이전고시에 의하여 부동산을 취득할 수 있는 권리에서 부동산으로 변환된다고 보는 것이 타당하다.

넷째, 재개발조합의 조합원이 재개발조합에 주택 및 그 부수토지를 제공하고 관리처분계획에 따라 취득한 아파트분양권을 양도하는 경우에는 당해 아파트분양권은 1세대 1주택과 그 부수토지를 양도한 것으로 간주하여 보유기간의 요건을 갖추면 당해 양도는 1세대 1주택의 양도로서 양도소득세를 비과세하는 것이 타당하다.

다섯째, 재건축부담금과 양도소득세의 이중과세의 문제가 있기 때문에 이를 합리적으로 조정하여야 하는데, 단기적으로는 세액공제를 하고, 장기적으로는 재건축부담금을 폐지하는 것이 바람직할 것이다.

여섯째, 조합원입주권이 주택으로 의제되는 경우에 장기보유특별공제의 적용에 있어서도 주택으로 보아 장기보유특별공제를 적

용할 수 있는지의 여부가 문제인데, 장기보유특별공제를 허용하는 것이 바람직할 것이다.

일곱 번째, 현행 양도소득세 세율구조는 기본적으로 너무 높게 설정되어 있다. 즉, 다주택 보유자 등에 대한 중과세제도는 여러 가지 면에서 위헌의 소지를 안고 있기 때문에 이러한 자산에 대한 중과세율제도는 폐지하는 방향으로 개선이 이루어져야 할 것이다. 부연하면, 양도소득세의 경우에는 기본적으로 중과세율제도는 폐지하고, 모든 자산에 대하여 초과누진세율구조로 변경하는 것이 타당할 것이다.

여덟 번째, 주택재건축정비사업조합이 일반분양 수입금액에서 당해 공사원가 등을 제외한 개발이익금 상당액을 각 조합원들에게 지분비율에 따라서 배분하여 각 조합원이 부담하여야 할 건축비에 충당하는 경우에 각 조합원이 획득한 것이 소득세의 과세대상에 해당하는지의 여부가 문제인데, 이에 대하여 판례는 배당소득에 해당한다고 보고 있다. 그러나, 이와 같이 배당소득으로 해석하게 되면, 양도소득세와 중복과세되는 결과를 초래하게 되어 불합리하게 된다. 따라서 소득세를 과세하지 않는 방향으로 개정되어야 할 것이다.

아홉 번째, 정비사업조합은 실질적으로 조합원들의 공동사업과 동일하기 때문에 세법에서 조합으로 의제하여 법인세를 과세하지 않고, 소득세법상 양도소득세로 과세하는 것이 타당할 것이다. 이와 같이 법인세를 과세하지 않으면 정비사업조합에 대한 조세특례제한법상 규정도 불필요하기 때문에 조세법을 단순하게 할 뿐만 아니라 해석상 논란도 발생하지 않을 것이다.

열 번째, 현행 부가가치세법의 해석상 정비사업조합이 조합원에게 주택을 공급하는 것은 재화의 공급에 해당한다고 해석할 수 밖에 없다. 즉, 현행 부가가치세는 법에 면세대상으로 규정되어 있지 않는 경우에는 과세되는 일반소비세이기 때문에 정비사업조합이 조합원에게 공급하는 것도 재화의 공급에 해당한다고 보아야 할 것이다. 그러나, 실질적으로는 재화의 공급으로 보기에 는 무리가 있기 때문에 재개발조합 등이 조합원에 공급하는 것을 부가가치세법상 면세대상으로 규정하는 입법적인 보완이 필요하다.

열 한 번째, 주택재개발사업에 있어서 주택재개발조합이 조합원의 종전 부동산을 사업목적에 사용하는 것은 조합원 분양용이든, 일반분양용이든 관계없이 취득세의 과세대상에 해당하지 않는다고 할 것이다.

열 두 번째, 주택재개발조합이 조합원에게 신축한 주택을 분양하는 경우 그 분양분에 대하여 조합에게 취득세를 과세할 수 없다고 보아야 할 것이다. 또한, 조합원 이외의 자에게 분양하는 경우에도 당해 조합에게는 취득세 납세의무가 없다고 보아야 할 것이다. 한편, 조합으로부터 분양받은 조합원 이외의 자는 신축주택을 승계취득하는 것이므로 당연히 취득세 납세의무가 있다고 보아야 할 것이다.

열 세 번째, 주택재건축사업의 경우 현물출자단계에 있어서 신탁등기에 대하여는 조합원에 대한 분양분인지 또는 일반분양분인지에 대한 구분 없이 취득세를 과세하지 않는 것이 타당하다고 할 것이다.

열 네 번째, 주택재건축사업에 있어서 조합이 공동주택을 분양하는 경우는 두 가지로 구분할 수 있는데, 조합원에게 분양하는 경우뿐만 아니라 조합원 이외의 자에게 분양하는 경우에도 조합에게는 취득세 납세의무가 없다고 보아야 할 것이다.

열 다섯 번째, 주택건설업자가 분양용으로 취득한 공동주택에 대하여 취득세 납세의무가 있는지의 여부가 문제인데, 주택건설업자의 주택의 신축에 따른 원시취득은 취득에 대하여는 취득세 납세의무가 없고, 분양자가 분양받을 때에 취득세 납세의무를 부담하는 것으로 보아야 한다.

열 여섯 번째, 재개발 또는 재건축 등이 시행되는 경우에는 주거용 건축물이 멸실되기 때문에 재산세의 과세에 있어서 과세대상이 변경되는데, 이와 같이 일시적으로 주택에서 토지로 과세대상이 변경되는 경우에는 평가기준의 차이에 따른 시가표준액·과세표준 적용비율·세부담상한율·기준에 받아오던 세부담 상한에 따른 부담분의 차이가 발생하여 급격한 세부담의 증가가 발생하게 되는 문제점이 발생한다. 이러한 문제점을 개선하기 위해서 일정한 개선이 이루어져야 할 것이다.

열 일곱 번째, 주택재개발 등의 경우 재산세 납세의무자에 있어서 문제가 되는 것은 체비지 또는 보류지의 경우에 누가 납세의무자가 되는지의 여부인데, 체비지로 정한 토지를 일시 관리하는 공법상의 관리권자에 불과한 토지구획정리사업의 사업시행자에게 재산세의 납부의무를 부과하는 것은 실질적 조세법률주의와 조세평등주의에 어긋나는 것으로 타당하지 않기 때문에 입법적인 개선이 이루어져야 할 것이다.

## □ 참 고 문 헌 □

### 1. 단행본

- 강인애, 「신소득세법」, 한일조세연구소, 2006.
- 강인애, 「조세법 VII」, 조세통람사, 1994.
- 고성춘, 「조세법」 하, 도서출판 청보, 2008.
- 권강웅·권태형, 「축조 지방세법해설」, (주)광교이텍스, 2009.
- 김남진·김연태, 「행정법」 II, 법문사, 2007.
- 김백영, 「조세판례연구」 III, 법률정보센타, 1998.
- 김완석, 「소득세법론」, (주)광교이텍스, 2009.
- 김백영, 「조세판례연구」 II, 법률정보센타, 1993.
- 김태호, 「지방세개론」, 세연T&A, 2009.
- 국세청, 「부동산과 세금」, 2009.
- 류지태, 「행정법신론」, 신영사, 2007.
- 서울지방국세청, 「재개발·재건축 세금가이드」, 2008.
- 안수남·김동백·김강영, 「양도소득세 2009」, (주)광교이텍스, 2009.
- 유창용, 「재개발·재건축·공동주택 리모델링 회계와 세무실무」, 어울림, 2009.
- 이전오·김완일·이강오, 「납세협력비용 감축방안에 관한 연구」, 한국조세연구포럼, 2008.11.
- 임승순, 「조세법」, 박영사, 2006.
- 임채웅, 「신탁법연구」, 박영사, 2009.
- 전동훈, 「지방세감면조례해설」, (주)영화조세통람, 2004.
- 전동훈, 「지방세실무해설」, (주)영화조세통람, 2003.
- 임재근, 「부동산세법론」, 법률서원, 2005.

서울시립대학교 지방세연구소, 「주택분재산세 직전년도 세부담상  
한 상당액 적용기준 및 도지분재산세 합리적 대응방안」,  
2008.12.

## 2. 논 문

고영구, “주택개발재개발조합에게 토지를 제공하고 아파트와 상  
가를 분양받은 경우 상가부분을 청산금의 대가로 취득한  
것으로 보아 종전 토지 중 상가분양가액에 상응하는 토  
지 부분에 대하여 양도소득세를 부과할 수 있는지 여부” ,  
「대법원 판례해설」, 법원도서관, 2004.12, pp.337-354.

고재풍·문영기, “재건축사업이 재산세입에 미치는 영향 분석 :  
강남구 재건축 사례를 중심으로” , 「국토연구」 제52권,  
국토연구원, pp.95-112.

김명섭, “도시및주거환경정비법상 주택재건축사업의 완료에 따른  
취득세 문제” , 「재판자료」 제114집, 법원도서관, 2007.1,  
pp.251-285

김명섭, “주택재건축 관련 취득세 논의” , 「사법논집」 제42집, 법  
원도서관, 2006.12, pp.221-341.

김선희·장찬, “재건축·재개발 관련 소송” , 「행정소송의 이론  
과 실무」, 사법연구지원재단, 2008.1, pp.583-607.

김성수, “재건축부담금에 대한 헌법적 검토” , 「토지공법연구」  
제31집, 한국토지공법학회, 2006.5, pp.29-57.

김완석, “재건축에 대한 조세법적 검토” , 「토지공법연구」 제33집,  
한국토지공법학회, 2006.11, pp.41-74.

김완석, “주택세제 관련 법제, 정책·입법 평가” , 「토지공법연  
구」 제35집. 한국토지공법학회, 2007.2, pp.91-120

- 김중곤, “비법인사단의 세법상 제문제”, 「사법논집」 제33집, 법원도서관, 2001.12, pp.601-723.
- 김청식, “주택재건축사업 관련 세제의 문제점과 개선방안”, 서울시립대학교 세무전문대학원, 2009.2.
- 김홍균, “지방세법상 취득세에 관한 연구 - 취득의 의의를 중심으로 -”, 영남대학교 대학원, 1998.12
- 민태욱, “주택재개발·재건축조합의 조세법적 성격과 조세문제”, 「토지공법연구」 제20집, 한국토지공법학회, 2003.11, pp.425-442.
- 박훈, “재개발조합의 과세문제”, 「조세와 법」 제1권 제2호, 서울시립대학교 법학연구소·지방세연구소, 2008.12, pp.209-233.
- 박훈·정지선, “주택에 대한 양도소득세 비과세 및 감면제도의 문제점과 개선방안에 관한 연구”, 「세무학연구」 제26권 제4호, 한국세무학회, 2009.12, pp.149-175.
- 성소미, “부동산 법제의 새로운 체계구성과 최근의 입법동향”, 「토지공법연구」 제38집, 한국토지공법학회, 2007.11, pp.1-37.
- 성소미, “재건축 개발이익환수에 관한 법적 쟁점”, 「토지공법연구」 제31집, 한국토지공법학회, 2006.5, pp.1-27.
- 송승찬, “도시재개발사업에서 조합원이 관리처분계획에 의하여 취득하는 분양예정지 대지 또는 건축시설 양도의 성격”, 「대법원 판례해설」, 법원행정처, 1994.5, pp.301-310.
- 송승찬, “도시재개발사업으로 취득한 아파트분양권의 양도와 양도소득세가 비과세되는 1세대 1주택”, 「대법원 판례해설」 제21호, 법원도서관, 1994.3, pp.453-460
- 송진영·정지선, “양도소득세 과세표준 산정방법과 세율구조에

- 관한 연구”, 「세무학연구」 제25권 제4호, 한국세무학회, 2008.12, pp.81-108.
- 안성포, “주택조합의 납세의무자성 -부가가치세를 중심으로-”, 「상사판례연구」 제16권, 한국상사판례연구회, 2004.4, pp.201-224.
- 양은열, “재개발·재건축 규제와 재산권 보장에 관한 법적 연구”, 서울시립대학교 대학원 박사학위논문, 2009.2.
- 오윤, “경기부양을 위한 양도소득세 감면제도에 관한 연구”, 「사단법인 한국세법학회 제98과 정기학술회의」, 2009.6, 한국세법학회, pp.69-98.
- 윤병철, “조합과세에 관한 판례연구”, 「조세법연구」 VIII-1, 한국세법연구회, 2002.7, pp.84-117.
- 이동수, “재건축 개발이익환수제의 내용과 문제점”, 「부동산세제의 현안과 과제」, 한국토지공법학회, 2004.12, pp.99-126.
- 이종혁, “재건축조합이 조합원들로부터 신탁받은 토지에 대한 취득세 과세 여부”, 「조세연구」 제7집, 한국조세연구포럼, 2007.10, pp.139-165.
- 이주희, “재건축사업의 초과이익 환수제도의 부적정성에 관한 연구”, 「토지공법연구」 제40집, 한국토지공법학회, 2008.5, pp.1-19.
- 이중교, “주택재개발사업과 재건축사업의 취득세 과세에 대한 연구”, 「공법연구」 제37집 제1-2호, 한국공법학회, 2008.10, pp.359-387.
- 임규진·정승영, “정비사업조합의 법적 성격과 과세문제”, 「조세연구」 제9-3집, 한국조세연구포럼, 2009.112, pp.310-333.



- 임재근, “지방세법상 조합과세 현황과 그 개선방향”, 「조세연구」 제6집, 한국조세연구포럼, 2006.10, pp.7-38.
- 임주영·정지선, “지방세법상 재산세의 문제점과 개선방안”, 「조세법연구」 XⅢ-3, 한국세법학회, 2007.12, pp.152-188.
- 임채웅, “재건축주택조합과 신탁에 대한 취득세의 부과에 관한 연구”, 「저스티스」 통권 제102호, 한국법학원, 2008.2, pp.190-215.
- 정지선, “취득세의 합리적 개선방안에 관한 연구 -입법론을 중심으로-”, 서울시립대학교 세무대학원 박사학위 논문, 2006.8.
- 조성권, “재건축조합의 조합원이 1세대 1주택 비과세 요건을 갖춘 고가주택에 해당하는 분양권을 양도함에 있어 기존주택과 분양주택의 면적이 서로 상이한 경우, 양도소득세액을 산정함에 있어 장기보유특별공제액은 주택면적과 보유기간을 분양주택을 기준으로 할 것인지 여부”, 「대법원 판례해설」 제69호, 법원도서관, 2007.12, pp.233-249.
- 조성권, “재건축아파트 분양권과 관련된 1세대 1주택 비과세 문제”, 「재판자료」 제108집, 법원도서관, 2005.12, pp.313-374.
- 조일영, “구 주택건설촉진법에 의한 재건축조합의 조합원이 기존의 주택이나 대지를 제공하고 그 사업계획에 따라 취득하는 주택 등을 분양받을 권리의 취득시기”, 「대법원 판례해설」 제69호, 2007.12, 법원도서관, pp.333-358.
- 조철호, “부동산신탁에 있어서 신탁부동산의 처분에 대한 부가가치세 납세의무자”, 「재판자료」 제108집, 법원도서관, 2005.12, pp.375-401.
- 최원, “취득세에 있어서의 취득개념에 관한 연구”, 경희대학교 대

- 학원, 2000.8.
- 최원삼, “조합주택 과세방법에 대한 검토”, 「2005년 지방세포럼」, 서울시립대학교 지방세연구소, 2005.12, pp.237-260.
- 최철환, “재건축주택조합의 일반분양용 토지에 관한 신탁재산취득의 취득세 과세 여부”, 「저스티스」통권 제103호, 한국법학원, 2008.4, pp.253-283.
- 한병식, “분양주택의 원시취득에 대한 취득세 과세문제의 재검토”, 「지방세」통권68호, 한국지방재정공제회, 2001, pp.21-35.
- 한정훈, “재개발·재건축사업에 있어 양도소득세와 관련된 쟁점에 관한 연구”, 「재관자료」제115집, 법원도서관, 2008.6, pp.529-549.
- 홍성욱, “주택재개발·재건축사업 관련 제반 세법 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 2006.2.